

DIGESTO

ACTO JURÍDICO

MANUAL DE ESTUDIO · NIVEL EXAMEN DE GRADO

Elaborado por **Laura Schultz Solano**

Texto refundido a partir de los apuntes de Cristián Boetsch Gillet, jurisprudencia seleccionada y comparaciones doctrinales · Borrador completo, pendiente de revisión

Índice

I. Teoría general del acto jurídico

1. Introducción
2. La teoría del acto jurídico en el Código Civil chileno
3. Los hechos jurídicos: concepto y clasificación
4. Concepto de acto jurídico
5. El principio de la autonomía de la voluntad
 - a. Conceptos generales
 - b. Consecuencias de la autonomía de la voluntad
 - c. Limitaciones a la autonomía de la voluntad
6. Estructura y elementos constitutivos del acto jurídico
 - a. Elementos o cosas esenciales
 - b. Elementos o cosas de la naturaleza
 - c. Elementos o cosas accidentales
7. Requisitos o condiciones de los actos jurídicos
 - a. Doctrina que distingue existencia y validez
 - b. Doctrina que solo reconoce requisitos de eficacia
8. Clasificaciones de los actos jurídicos
 - a. Unilaterales, bilaterales y plurilaterales
 - b. Patrimoniales y de familia
 - c. A título gratuito y a título oneroso
 - d. De administración y de disposición
 - e. Entre vivos y por causa de muerte
 - f. Solemnes y no solemnes
 - g. Consensuales y reales
 - h. Puros y simples y sujetos a modalidades
 - i. Causales y abstractos
 - j. Principales y accesorios
 - k. Constitutivos, declarativos y traslaticios
 - l. De ejecución instantánea, diferida y de tracto sucesivo
 - m. Típicos o nominados y atípicos o innominados

II. Requisitos de los actos jurídicos

A. La voluntad

1. Conceptos generales
2. Requisitos de la voluntad
 - a. Seriedad de la voluntad
 - b. Manifestación de la voluntad
3. La voluntad en las diversas clases de actos jurídicos
 - a. La voluntad en los actos jurídicos unilaterales
 - b. La voluntad en los actos jurídicos bilaterales: el consentimiento
 - c. Casos especiales de formación del consentimiento
4. Vicios de la voluntad
5. El error
 - a. Concepto
 - b. Error de derecho y error de hecho
 - c. Diversas clases de error de hecho y sus efectos
 - d. El error en los actos bilaterales
 - e. El error en los actos unilaterales
 - f. Error común
6. El dolo
 - a. Concepto
 - b. Clases de dolo
 - c. Cuándo el dolo vicia el consentimiento
 - d. Prueba del dolo
 - e. Condonación o renuncia del dolo
 - f. Sanción del dolo
 - g. Acción de dolo
7. La fuerza
 - a. Concepto
 - b. Clases
 - c. Cuándo la fuerza vicia el consentimiento
 - d. Indiferencia de la persona que ejerce la fuerza
 - e. Prueba de la fuerza
 - f. Efectos de la fuerza
 - g. Prescripción de la acción de nulidad
 - h. Temor reverencial

8. Lesión y simulación: remisión

B. La capacidad

1. Concepto
2. Clases de capacidad
 - a. Capacidad de goce
 - b. Capacidad de ejercicio
3. Las incapacidades de ejercicio
 - a. Incapacidad absoluta
 - b. Incapacidad relativa
 - c. Incapacidades particulares o especiales

C. El objeto

1. Concepto
2. Requisitos que debe reunir el objeto que recae sobre una cosa
 - a. Cosa real
 - b. Cosa comerciable
 - c. Cosa determinada
3. Requisitos del objeto que recae sobre un hecho
 - a. Hecho determinado
 - b. Hecho físicamente posible
 - c. Hecho moralmente posible
4. El objeto ilícito
 - a. Actos que contravienen el derecho público chileno
 - b. Pactos sobre sucesiones futuras
 - c. Enajenación de las cosas enumeradas en el art. 1464
 - d. Condonación del dolo futuro
 - e. Deudas contraídas en juego de azar
 - f. Venta de libros prohibidos, objetos inmorales e impresos abusivos de la libertad de prensa
 - g. Actos prohibidos por la ley

D. La causa

1. Generalidades
2. Evolución histórica de la noción de causa
3. Doctrinas elaboradas en relación con la causa
 - a. Doctrina tradicional o clásica
 - b. Doctrina italiana
 - c. Doctrina del móvil o motivo determinante
 - d. Doctrina anticausalista
4. La teoría de la causa en el Código Civil chileno
 - a. ¿Qué es lo que debe tener causa: el acto o la obligación?
 - b. ¿Criterio objetivo o subjetivo?
 - c. Doctrina dual de la causa
 - d. Doctrina unitaria de la causa
5. Causa real
6. Licitud de la causa
7. Actos causales y actos abstractos
 - a. Conceptos
 - b. La relación fundamental y subyacente del acto abstracto
 - c. Razón de ser de los actos abstractos
 - d. Solo la ley puede establecer actos abstractos
 - e. Actos abstractos en la legislación chilena
8. Relación de la causa con el error y con la fuerza o el dolo

E. Las formalidades

1. Concepto
2. Clases de formalidades
 - a. Las solemnidades (formalidades propiamente tales)
 - b. Formalidades habilitantes
 - c. Las formalidades de prueba
 - d. Las medidas de publicidad

III. Los efectos de los actos jurídicos

1. Generalidades
2. Personas respecto de las cuales se producen los efectos de los actos jurídicos
 - a. Concepto de parte
 - b. Concepto de tercero
3. El efecto relativo de los actos jurídicos y sus excepciones
 - a. Generalidades
 - b. Excepciones al efecto relativo de los contratos
 - c. El efecto absoluto, indirecto o erga omnes

IV. Ineficacia de los actos jurídicos

A. La inexistencia jurídica

1. Conceptos generales
2. Origen de la teoría de la inexistencia jurídica
3. Diferencias entre la inexistencia y la nulidad
4. ¿Distingue el Código Civil chileno la inexistencia y la nulidad absoluta?
 - a. Doctrina que afirma que sí distingue
 - b. Doctrina que niega la distinción
 - c. Análisis desde la historia fidedigna del establecimiento del Código
 - d. Jurisprudencia sobre la materia

B. La nulidad: aspectos generales

1. Reglas del Código Civil sobre la nulidad
2. Concepto general de nulidad
3. Especies de nulidad: absoluta y relativa
4. Terminología
5. Especie de nulidad que constituye la regla general
6. Diferencias entre la nulidad absoluta y la relativa
7. Principios aplicables a ambas clases de nulidad
8. Nulidad total y nulidad parcial del acto jurídico
9. La nulidad refleja

C. La nulidad absoluta

1. Concepto
2. Causales
3. Fundamento y caracteres
4. Declaración de nulidad absoluta
5. La nulidad absoluta no puede sanearse por la ratificación de las partes
6. Saneamiento de la nulidad absoluta por el transcurso del tiempo
7. La nulidad absoluta no se produce de pleno derecho

D. La nulidad relativa

1. Definición y fundamento
2. Causales
3. Características
4. Personas legitimadas para alegar la nulidad relativa
 - a. Regla general
 - b. Situación excepcional del incapaz que no puede demandar la rescisión
5. La nulidad relativa puede sanearse por el transcurso del tiempo
6. La nulidad relativa puede sanearse por la ratificación o confirmación de las partes
 - a. Concepto
 - b. Clases
 - c. Características de la ratificación
 - d. Requisitos de la ratificación

E. Los efectos de la nulidad

1. Conceptos generales
2. Efectos de la nulidad respecto de las partes
3. Efectos de la nulidad respecto de terceros
4. Acciones a que da origen la nulidad
 - a. La acción de nulidad
 - b. La acción reivindicatoria
 - c. La acción de indemnización de perjuicios
5. La conversión

F. La lesión

1. Concepto doctrinal
2. La lesión en el Código Civil chileno: ¿constituye un vicio del consentimiento?
3. Casos de lesión regulados en el Código Civil chileno
4. Sanción de la lesión

G. La simulación

1. Concepto
2. La simulación en el ordenamiento jurídico chileno
3. Simulación lícita
4. La simulación ilícita
 - a. Requisitos
 - b. Clases de simulación: absoluta y relativa
 - c. Sanción civil a la simulación ilícita
 - d. Consideraciones probatorias

H. La inoponibilidad

1. Concepto
2. Inoponibilidades de un derecho nacido de un acto jurídico válido
 - a. Inoponibilidades de forma
 - b. Inoponibilidades de fondo
3. Inoponibilidades de un derecho nacido de la nulidad o resolución de un acto jurídico
4. Maneras de hacer valer la inoponibilidad
5. Diferencias entre la nulidad y la inoponibilidad

I. El fraude a la ley

1. Concepto
2. El fraude a la ley en el ordenamiento jurídico nacional
3. Requisitos para que un obrar sea en fraude a la ley
4. Fraude a la ley y figuras afines
 - a. Fraude a la ley y simulación
 - b. Fraude a la ley y abuso del derecho (en su variante de abuso de formas jurídicas)
5. Sanción al fraude a la ley

J. Otras causales de ineficacia

- 1. La suspensión**
- 2. La resolución**
- 3. La resciliación**
- 4. La revocación**
- 5. El desistimiento unilateral**
- 6. La caducidad**
- 7. La terminación**
- 8. La renuncia**
- 9. La muerte**

V. La representación

1. Concepto
2. Utilidad y ámbito de aplicación de la representación
3. Poder de representación
 - a. Conceptos generales
 - b. Clases de representación
 - c. Mandato y representación voluntaria
4. Naturaleza jurídica de la representación
 - a. Teoría de la ficción
 - b. Teoría del nuntius o mensajero
 - c. Teoría de la cooperación de voluntades
 - d. Teoría de la representación modalidad del acto jurídico
5. Influencia de las circunstancias personales del representante o del representado
 - a. En relación a la capacidad
 - b. En relación con las formalidades habilitantes
 - c. En relación con los vicios del consentimiento
 - d. En relación a la buena o mala fe
 - e. En relación al principio *nemo auditur propiam turpitudinem allegans*
6. Requisitos necesarios para que exista representación y produzca plenamente sus efectos
 - a. Declaración de voluntad del representante
 - b. Existencia al contratar de la *contemplatio domini*
 - c. Existencia de poder, y obrar dentro de sus límites
7. Efectos de la representación
8. Sanción de los actos ejecutados sin poder o con extralimitación
9. La ratificación
10. Otras hipótesis en que los efectos de los actos jurídicos alcanzan a los terceros
 - a. Estipulación para otro
 - b. Promesa de hecho ajeno

VI. Modalidades de los actos jurídicos

A. La condición

1. Concepto
2. Clasificaciones
 - a. Positivas y negativas
 - b. Posibles e imposibles
 - c. Suspensiva y resolutoria
 - d. Potestativa, casual o mixta
3. Estados en que pueden hallarse las condiciones
 - a. Efectos de la condición suspensiva
 - b. Efectos de la condición resolutoria

B. El plazo

1. Concepto
2. Semejanzas y diferencias del plazo y la condición
3. Clasificaciones
 - a. Plazo expreso y tácito
 - b. Plazo determinado e indeterminado
 - c. Plazo convencional, legal y judicial
 - d. Plazo suspensivo y extintivo
4. Efectos del plazo
 - a. Efectos del plazo suspensivo
 - b. Efectos del plazo extintivo

C. El modo

1. Concepto
2. Efectos del modo
3. Cumplimiento del modo

A. TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO

1. INTRODUCCIÓN

Como señala el profesor **VIAL**, desde antiguo los estudiosos del derecho han procurado encontrar el elemento común o vinculante de las diversas instituciones del derecho privado, labor ardua si se considera que las diferencias entre ellas parecen ser, a simple vista, más notorias que una eventual semejanza. ¿Qué podrían tener en común un testamento con una compraventa? A primera vista, lo único que relaciona a esos actos es que surgen como consecuencia de la voluntad del hombre, conclusión tan amplia y vaga que mal podría justificar por sí sola una construcción jurídica.

Sin embargo, partiendo de ese elemento común es posible encontrar otros dos. Primero, esos actos surgen de una manifestación de voluntad hecha con un propósito determinado (disponer de bienes en el testamento, intercambiar bienes en la compraventa), propósito que inspira a quienes intervienen en su celebración. Segundo, dichos actos producen efectos jurídicos, pues crean, modifican o extinguen una relación jurídica.

A los actos voluntarios que el hombre realiza con un propósito definido y que producen efectos de derecho, la doctrina los denomina **actos jurídicos**: todas las instituciones de derecho privado mencionadas como ejemplo (el testamento, la compraventa) presentan esa circunstancia común. Sobre esa base, los juristas han tratado de establecer las reglas o principios aplicables a todos los actos jurídicos, sea cual fuere su especie, surgiendo así la **Teoría General del Acto Jurídico**, cuyo fundamento descansa en el principio de la autonomía de la voluntad: la facultad de los sujetos de derecho para celebrar actos jurídicos a través de los cuales pueden crear, modificar o extinguir derechos subjetivos.

2. LA TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

Al igual que el Derecho Romano, la mayoría de los códigos civiles de nuestra época no consagra en sus preceptos la teoría general de los actos jurídicos. Entre los pocos que sí la tratan en forma general y sistemática pueden citarse los de Argentina, Alemania, Brasil, el de Derecho Canónico, el de Portugal y el de Perú de 1984.

Nuestro Código Civil no consagra ni regula expresamente esta teoría. Sin embargo, la doctrina chilena, siguiendo a la francesa y a la italiana, la ha construido derivándola de los principios que informan las normas relativas a los contratos y, en parte, al acto testamentario. Dentro del Código de **BELLO** tienen especial importancia el título *De los actos y declaraciones de voluntad* (**arts. 1445 a 1469**) y el dedicado a la nulidad y rescisión de los actos y contratos (**arts. 1681 a 1697**).

Hay consenso, tanto en doctrina como en jurisprudencia, en que todos los actos jurídicos se rigen por esas normas, a menos que el tenor de la disposición o la naturaleza de las cosas las limite sola-

mente a las convenciones o contratos.

3. LOS HECHOS JURÍDICOS: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Por **hecho** se entiende todo suceso o acontecimiento generado por la naturaleza o por la acción del hombre: en el primer caso se habla de hechos *naturales*, y en el segundo, de hechos *humanos*. Ambos pueden tener o no consecuencias jurídicas. Los que las producen se llaman **hechos jurídicos**; los que no, **hechos materiales** o jurídicamente irrelevantes.

EJEMPLO

Hechos jurídicos de la naturaleza

(i) La fructificación de las plantas, cuyo efecto jurídico es la adquisición por el propietario del dominio de los frutos. (ii) Un terremoto que, como caso fortuito, libera de culpa y responsabilidad al deudor por el atraso causado por el fenómeno. (iii) El cambio de curso de un río, que trae como efecto la accesión a los propietarios contiguos de la parte del cauce que quedó permanentemente en seco (**art. 654**). (iv) El nacimiento, que erige al recién nacido en titular de derechos de la personalidad. (v) La muerte, que traspasa a los herederos los derechos y obligaciones transmisibles del difunto.

Frente a los hechos jurídicos naturales, que cobran existencia sin el concurso del hombre, están los **hechos jurídicos humanos**: en sentido amplio, los realizados por el hombre, por lo general en forma voluntaria, a los cuales el ordenamiento atribuye consecuencias jurídicas. Estos se clasifican en *lícitos* (admitidos y protegidos por el ordenamiento) e *ilícitos* (prohibidos por el ordenamiento o que lesionan injustamente un interés ajeno: delitos, cuasidelitos). En definitiva, son actos jurídicos los hechos jurídicos humanos lícitos.

NO CONFUNDIR

Negocio jurídico vs. acto jurídico

La doctrina alemana e italiana distingue, dentro de los hechos jurídicos humanos lícitos, el **negocio jurídico** del **acto jurídico** en sentido estricto. En el negocio jurídico los efectos producidos son los queridos por su autor o las partes, surgiendo como consecuencia inmediata y directa de la voluntad (una compraventa). En el simple acto jurídico, en cambio, los efectos no van necesariamente adheridos a la voluntad de los autores y muchas veces son independientes de ella: quien construye un edificio en terreno ajeno sin conocimiento del dueño ejecuta un acto voluntario cuyo efecto (que el dueño del terreno se haga dueño del edificio) no es el querido por el constructor. Esta clasificación es ajena a nuestra legislación y a la doctrina tradicional: en Chile se habla indistintamente de acto jurídico y de negocio jurídico.

4. CONCEPTO DE ACTO JURÍDICO

Tradicionalmente el acto jurídico se define como una *declaración de voluntad o un conjunto de declaraciones de voluntad dirigidas a la producción de determinados efectos jurídicos, que el derecho objetivo reconoce y garantiza*. Esos efectos pueden consistir en la creación, modificación o extinción de una relación jurídica o de una situación o estado jurídicos; también puede ser efecto de un acto jurídico la confirmación o declaración de certeza de una relación preexistente dudosa o incierta.

Otra definición señala que el acto jurídico es la *manifestación unilateral o bilateral de voluntad ejecutada con arreglo a la ley y destinada a producir un efecto jurídico* que puede consistir en la adquisición, conservación, modificación, transmisión, transferencia o extinción de un derecho. Finalmente, **VIAL** lo define como la *manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que produce los efectos queridos por su autor o las partes porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad*.

De esta última definición es posible extraer tres elementos:

a. El acto jurídico es una manifestación de voluntad.

No basta la existencia de la voluntad interna o psicológica, por esencia variable: es necesario que la voluntad del autor o las partes se exteriorice por medio de una declaración o comportamiento que permita conocerla. La sola intención que no se exterioriza no produce consecuencia alguna para el derecho, como tampoco la produce la mera manifestación que no obedece a una intención real y seria.

b. La manifestación de voluntad debe perseguir un propósito específico y determinado.

Para la doctrina tradicional ese propósito debe ser necesariamente jurídico: el autor o las partes deben buscar producir efectos de derecho. La doctrina moderna, en cambio, estima que el propósito debe perseguir un fin práctico o empírico. **VIAL** concilia ambas posturas: dicen lo mismo con distinto enfoque, uno mira cómo el derecho ve el propósito perseguido, y el otro, cómo las partes se lo representan. **ROUBIER** defiende que es sobre la producción de efectos jurídicos que reposa toda la teoría del acto jurídico, y que es justamente lo que distingue al contrato del delito: en el acto jurídico la voluntad privada está guiada por las consecuencias jurídicas que se esperan de él, mínimo que debe concurrir siempre, o no hay acto jurídico.

EJEMPLO

Ladrón y comprador persiguen el mismo fin práctico, pero solo uno celebra un acto jurídico

Como ejemplifica **STOLFI**, tanto el comprador como el ladrón quieren hacer suya la cosa para disfrutarla, administrarla o transmitirla: persiguen el mismo fin práctico. Pero solo en el caso del comprador ese efecto práctico coincide con el efecto jurídico, porque el ordenamiento lo reconoce y lo protege; el ladrón, en cambio, no puede reclamar tutela legal para su pretensión, y el robo le acarrea consecuencias jurídicas distintas de las queridas, como la obligación de indemnizar los daños causados. De ahí que no deba confundirse el efecto práctico, que prescinde de la norma, con el efecto jurídico, que es el protegido por ella.

c. La manifestación de voluntad produce los efectos queridos porque el derecho la sanciona.

La causa eficiente de los efectos del acto jurídico proviene de la voluntad y de la ley: los efectos derivan en forma inmediata de la voluntad del autor o de las partes, y en forma mediata de la ley, que permite la libertad jurídica cuya expresión es el poder jurídico, es decir, la facultad de los particulares para crear relaciones jurídicas.

5. EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

5.1. Conceptos generales

La Teoría General del Acto Jurídico descansa sobre dos soportes fundamentales: libertad y voluntad. El hombre es libre para vincularse con otros o no, y si decide obligarse lo hace por su propia voluntad. De la coincidencia entre libertad y voluntad, propia de los filósofos y juristas del siglo XVIII, nace el **principio de la autonomía de la voluntad**, piedra angular del Derecho Civil reconocido por el Código Civil francés y por todos los que, como el nuestro, lo toman de modelo, y que se caracterizan por crear un sistema de derecho privado fundado en la libertad de los particulares, colocando al centro de ese sistema al acto jurídico, concebido como el paradigma típico de la manifestación de voluntad de la que deriva el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación personal o patrimonial.

En el Código Civil chileno el principio está reconocido en varias disposiciones. La principal consagra la libertad de contratar, dándole al contrato, respecto de las partes, una fuerza obligatoria como la de la ley (**art. 1545**), subordinando la eficacia de la voluntad al respeto de las leyes, las buenas costumbres y el orden público (**arts. 1445, 1461 y 1467**). Conforme a la doctrina más moderna, se denomina *autonomía privada* al principio en estudio: la facultad que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento, sean ventajosas u onerosas.

5.2. Consecuencias de la autonomía de la voluntad

El principio de la autonomía de la voluntad tiene las siguientes consecuencias esenciales:

(i) Libertad para obligarse o no.

El hombre es libre para obligarse o no, y si lo hace es por su propia voluntad. Así lo reconoce el Código al utilizar expresiones como *acepta* (**art. 1386**) o *concurso real de voluntades de dos o más personas* (**art. 1437**).

(ii) Libertad para renunciar.

El hombre es libre para renunciar por su sola voluntad a un derecho establecido en su beneficio, con tal que solo mire al interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia (**art. 12**).

(iii) Libertad para determinar el contenido o fondo.

El hombre es libre para determinar el contenido de los actos jurídicos que celebre, y por ello, siempre que respete las leyes, el orden público y las buenas costumbres, puede establecer las cláusulas que le plazcan, las cuales pasan a ser ley para los contratantes (**art. 1545**).

(iv) Libertad para determinar la forma.

El hombre es libre para elegir la forma escrita, oral o cualquiera otra, salvo que la ley imponga una determinada. Hoy la ley tiende a exigir cada vez menos formalismo, y cuando el legislador lo prescribe es para precaver a las partes de ligerezas o para resguardar derechos de terceros.

(v) Prevalencia de la intención sobre la voluntad declarada.

Como consecuencia de que tanto el acto jurídico como su contenido son fruto de la voluntad del hombre, la primera regla para interpretar adecuadamente los contratos consiste en recurrir a la clara intención de los contratantes, la que prima sobre la voluntad declarada.

5.3. Limitaciones a la autonomía de la voluntad

Las principales limitaciones a las que se encuentra afectada la autonomía privada son las siguientes:

(i) Solo puede disponerse de intereses propios.

La autonomía privada faculta a los particulares para disponer de sus propios intereses y no de los ajenos. Por regla general, todo acto en que se disponga de un bien ajeno le será inoponible a su verdadero dueño (por ejemplo, **art. 1815**, sobre compraventa de cosa ajena).

(ii) Sujeción a los requisitos legales.

Para que el acto o contrato produzca los efectos queridos por su autor o las partes, es necesario que se ajuste a los requisitos o condiciones establecidos por la ley para su valor jurídico.

(iii) Tipicidad en ciertas materias.

Hay materias respecto de las cuales los particulares no pueden crear actos jurídicos que no correspondan exactamente al tipo establecido por el legislador, como ocurre en el derecho de familia.

(iv) El orden público.

La autonomía privada está limitada por el orden público, concepto habitualmente utilizado por el legislador (por ejemplo, **art. 1461**) pero no definido en el Código Civil. La jurisprudencia lo ha entendido como *la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad*, o como *el conjunto de disposiciones establecidas por el legislador para resguardar los intereses superiores de la colectividad y de la moral social*.

(v) Las buenas costumbres.

La autonomía privada está limitada también por las buenas costumbres, concepto igualmente sin definición legal. La doctrina señala que constituye un aspecto particular del orden público de contornos imprecisos: comprende la moral sexual en sentido estricto, pero también las ideas morales admitidas en una época determinada, es decir, los principios moralmente predominantes en un momento dado.

6. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ACTO JURÍDICO

En lo relativo a la estructura del acto jurídico es tradicional la distinción entre elementos de la esencia (o esenciales), elementos de la naturaleza (o naturales) y elementos accidentales.

6.1. Elementos o cosas esenciales

En doctrina, los elementos esenciales son aquellos *necesarios y suficientes*: necesarios, porque la falta de uno de ellos excluye la eficacia (y para algunos la existencia) del acto jurídico; y suficientes, porque se bastan para darle esa eficacia y, por consiguiente, su concurrencia constituye el contenido mínimo del acto. El Código Civil establece que los elementos o cosas esenciales de un acto son todos aquellos sin los cuales no produce efecto alguno o degenera en otro acto diferente (**art. 1444**).

Es posible distinguir entre elementos esenciales **generales o comunes**, que no pueden faltar en ningún acto jurídico cualquiera sea su especie, y elementos esenciales **especiales o específicos**, requeridos para cada acto jurídico en particular. El **art. 1445** enumera los requisitos necesarios para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad sin mencionar cuáles son esenciales, pero la doctrina tradicional estima que estos son la **voluntad**, el **objeto** y la **causa**. No tienen esa calidad los restantes requisitos del **art. 1445** (la capacidad, la voluntad sin vicios, el ob-

jeto lícito y la causa lícita), pues el acto en que incide la incapacidad, la voluntad viciada, el objeto ilícito o la causa ilícita produce los efectos que le son propios, pero con un vicio que autoriza su declaración de nulidad.

EJEMPLO

Un elemento esencial específico que falta hace degenerar el acto

El precio en dinero es un requisito esencial en la compraventa, pero no existe en otros actos. Si las partes estipulan que el precio se pagará en una especie distinta del dinero, no hay compraventa, sino permuta. Del mismo modo, es de la esencia del comodato (préstamo de uso) ser gratuito: si el comodatario paga un precio por el uso de la cosa, el acto deja de ser comodato y degenera en arrendamiento.

6.2. Elementos o cosas de la naturaleza

Son las que, no siendo esenciales, se entienden pertenecer al acto sin necesidad de una declaración o cláusula especial (**art. 1444**): las partes nada necesitan declarar para que formen parte del acto, ya que la ley dispone en su lugar; la voluntad de las partes solo es necesaria para modificarlos o excluirlos. Más que *elementos*, se trata de *efectos* que la ley subentiende o incorpora cuando las partes han guardado silencio. Ejemplo de elemento de la naturaleza en la compraventa es la obligación del vendedor de sanear la evicción y los vicios redhibitorios: se entiende incorporada sin cláusula especial, pero por no ser esencial, las partes pueden eliminarla.

6.3. Elementos o cosas accidentales

Son aquellas que ni esencial ni naturalmente pertenecen al acto, y que se le agregan mediante declaraciones o cláusulas especiales: la ley no las subentiende ni son necesarias para la eficacia del acto, pero las partes, en virtud de la autonomía privada, pueden agregarlas mediante estipulación expresa. Pueden referirse a la *existencia* del acto (por ejemplo, que una compraventa de un bien mueble no se repunte perfecta sino hasta que se otorgue escritura pública, **art. 1802**) o, más frecuentemente, a su *eficacia* (la estipulación de una condición, plazo o modo).

De los tres tipos, los únicos verdaderos elementos o requisitos constitutivos del acto son los esenciales. Los naturales no forman parte de su estructura sino que dicen relación con sus efectos, y los accidentales no son requisitos constitutivos, por lo que la ley no los exige para que el acto produzca sus efectos.

7. REQUISITOS O CONDICIONES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Existe discrepancia doctrinal, desde antiguo y hasta hoy, acerca de las condiciones o requisitos de los actos jurídicos, cuestión con importantes consecuencias prácticas. Parte de la doctrina distingue

entre requisitos de existencia y de validez, de modo que la ausencia de los primeros implica la inexistencia del acto y la omisión de los segundos se sanciona con la nulidad. Para otros autores, esa distinción es artificial, porque el Código únicamente se refiere a requisitos de eficacia, y su ausencia siempre da lugar a la nulidad.

7.1. Doctrina que distingue existencia y validez

Esta doctrina afirma que el acto que nace a la vida del derecho debe cumplir ciertas condiciones para tener existencia sana (requisitos de existencia) y producir sus efectos en forma estable (requisitos de validez).

Son **condiciones de existencia** aquellas necesarias para que el acto nazca a la vida del derecho: si faltan, el acto es jurídicamente *inexistente* y no produce efecto alguno. Tienen esa calidad: (1) la voluntad; (2) el objeto; (3) la causa; y (4) las solemnidades que la ley exige para la existencia del acto (aunque hay quienes no las consideran un requisito aparte, pues estiman que en los actos solemnes la voluntad debe manifestarse a través de la solemnidad).

Son **condiciones de validez** aquellas que, si bien pueden faltar sin atentar contra la existencia del acto, son necesarias para su vida sana y para que produzca sus efectos en forma estable. La omisión de un requisito de validez no impide que el acto nazca y produzca sus efectos, pero nace enfermo, expuesto a morir si es invalidado: cuando no concurre una condición de validez el acto queda viciado y puede solicitarse su nulidad, mientras que la falta de una condición de existencia no permite vivir al acto. Son condiciones de validez: (1) voluntad no viciada; (2) objeto lícito; (3) causa lícita; (4) la capacidad; y, cuando corresponda, las solemnidades para la validez del acto.

7.2. Doctrina que solo reconoce requisitos de eficacia

Otros autores sostienen que la distinción entre existencia y validez es artificial, por no encontrarse recogida en el Código Civil. El **art. 1444** únicamente indica que la ausencia de un elemento esencial implica que el acto *no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente*, lo que solo manifiesta que el acto será ineficaz, sin aludir en parte alguna a requisitos de *existencia*. A su turno, el **art. 1445** se refiere a los requisitos para que una persona *se obligue* a otra por un acto o declaración de voluntad, es decir, para que el acto surta efectos y sea eficaz, sin distinguir tampoco entre existencia y validez.

Por lo expuesto, todos los requisitos (voluntad exenta de vicios, objeto lícito, causa lícita, ciertas solemnidades y la capacidad) serían condiciones de eficacia del acto jurídico, y su ausencia acarrearía siempre la nulidad, absoluta o relativa según el caso, pero nunca la inexistencia.

DATO DE GRADO**¿Existe la inexistencia como sanción distinta de la nulidad?**

Pregunta clásica de cédula. La respuesta no es un simple sí o no: hay que exponer las dos tesis. Para la doctrina que distingue existencia y validez, la falta de voluntad, objeto, causa o de las solemnidades exigidas para la existencia del acto produce **inexistencia jurídica** (el acto es la nada misma), mientras que la falta de un requisito de validez (voluntad no viciada, objeto o causa lícitos, capacidad) produce **nulidad**. Para la doctrina que solo admite requisitos de eficacia, como el Código nunca habla de existencia, toda ausencia de requisito se sanciona siempre con nulidad, absoluta o relativa según el caso.

8. CLASIFICACIONES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Según el punto de vista o criterio que se considere, pueden hacerse numerosas clasificaciones de los actos o negocios jurídicos.

8.1. Unilaterales, bilaterales y plurilaterales

Esta clasificación atiende al número de *partes* cuya voluntad es necesaria para que el acto jurídico se forme, y no al número de personas: una sola parte puede estar constituida por una o más personas, como reconoce expresamente el **art. 1438** al referirse a las partes del contrato. Por *parte* se entiende la persona o personas que constituyen un solo centro de intereses y concurren con su voluntad a formar el acto.

EJEMPLO**Centro de intereses, no número de personas**

Si cuatro personas son copropietarias de un fundo y lo venden conjuntamente a otro sujeto, los cuatro comuneros constituyen un solo centro de intereses y el comprador constituye otro. Aunque intervienen cinco personas, solo hay dos partes, y el acto es bilateral, no plurilateral.

a. Acto jurídico unilateral

Es aquel que se perfecciona con la voluntad de una sola parte: el testamento, la oferta, la aceptación, la renuncia de un derecho, la concesión o revocación de un poder, la ratificación de un acto nulo. Se llama *autor* a la parte cuya voluntad se requiere para darle nacimiento. Se distingue, a su vez, entre actos unilaterales *simples* (emanan de una sola persona, como el testamento) y *complejos* (proceden de varias personas que manifiestan una voluntad común, como la oferta que varias personas hacen para vender una casa); y entre actos *no recepticios* (producen sus efectos de inme-

diato, sin necesidad de ser puestos en conocimiento del destinatario) y *recepticios*, que son, como afirma **ALESSANDRI**, aquellos en que la declaración de voluntad que encierran, para lograr eficacia, ha de dirigirse a un destinatario determinado, o sea, debe comunicarse o notificarse a este.

DATO DE GRADO

Los actos recepticios son irrevocables desde que el destinatario los conoce

La importancia de la distinción recepticio/no recepticio radica en que todo acto jurídico unilateral y recepticio (como lo es el ejercicio de una opción *put*) es esencialmente irrevocable, sin quedar sujeto a modificación alguna una vez puesto en conocimiento del destinatario. Antes de que el destinatario tome conocimiento, el acto recepticio puede ser revocado por quien emitió la declaración; pero desde que este tomó conocimiento, el acto adquiere carácter irrevocable.

No altera el carácter unilateral de un acto jurídico que, para producir la plenitud de sus efectos, requiera la manifestación de voluntad de una persona distinta del autor: en el testamento la sola voluntad del testador basta para darle vida, aunque para que produzca la plenitud de sus efectos el heredero deba luego manifestar su voluntad de aceptar la herencia.

b. Acto jurídico bilateral

Es aquel que, para nacer a la vida jurídica, requiere la manifestación de voluntad de dos partes: los contratos, la tradición, el pago efectivo, el matrimonio. De acuerdo con la doctrina nacional, todo acto jurídico bilateral es una *convención*, sea que esté dirigida a crear, modificar o extinguir obligaciones; si el fin es crearlas, la convención toma el nombre específico de *contrato*. Por lo tanto, todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato: no lo es cuando modifica o extingue una obligación ya establecida. La compraventa, por ejemplo, es un contrato porque crea la obligación del vendedor de dar una cosa y la del comprador de pagarla en dinero; pero la tradición de esa cosa y el pago del precio son solo convenciones, porque extinguen las respectivas obligaciones ya creadas por el contrato de compraventa. El Código Civil hace sinónimos el contrato y la convención (**arts. 1437 y 1438**), lo que la doctrina considera un error.

NO CONFUNDIR**Unilateral/bilateral del acto vs. unilateral/bilateral del contrato**

No debe confundirse la distinción entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales (según el *número de partes* necesario para que el acto se forme) con la que el **art. 1439** hace entre los contratos, que ya son actos bilaterales, de carácter unilateral y bilateral: el contrato es unilateral cuando una parte se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Esta segunda distinción atiende al *número de obligados*, no al número de partes.

c. Acto jurídico plurilateral

Es aquel que, para nacer a la vida jurídica, requiere la manifestación de voluntad de más de dos partes. Por ejemplo, en la novación por cambio de acreedor se requiere la voluntad del deudor, del tercero que acepta la nueva obligación en su favor y del acreedor que consiente en liberar al deudor de la obligación primitiva (**art. 1631 N° 2**).

8.2. Patrimoniales y de familia

Según el contenido de los actos, se distingue entre actos de derecho de familia y actos de derecho patrimonial. Los actos de **familia** regulan intereses ideales concernientes al estado de las personas dentro del núcleo familiar, sobre los cuales prevalecen los intereses superiores de ese núcleo por sobre los de los particulares: el rol de la voluntad se reduce a constituir el acto que se quiere celebrar, encargándose la ley de fijar sus efectos, como ocurre en el matrimonio. Los actos **patrimoniales** son los que tienen por objeto crear, modificar o extinguir relaciones de carácter pecuniario, apreciables en dinero, como la compraventa.

8.3. A título gratuito y a título oneroso

Según la utilidad que reporta el acto para quienes lo ejecutan, se distingue entre actos onerosos y gratuitos. En los actos a título **oneroso** cada parte recibe una ventaja a cambio de la que procura a la otra, gravándose cada una en beneficio de la otra. Estos se subclasifican en *conmutativos* (cada parte se obliga a dar o hacer algo que se mira como equivalente a lo que la otra debe, como la compraventa o el arrendamiento) y *aleatorios* (el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, como la renta vitalicia).

En los actos a título **gratuito** (o *lucrativo*, **art. 1962 N° 1**), una parte procura a la otra o a un tercero una ventaja sin recibir ninguna equivalente: la donación, el testamento, el préstamo sin interés, el comodato. Nuestro Código establece esta división tratándose de los contratos: *el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro* (**art. 1440**).

8.4. De administración y de disposición

Los actos de **disposición** importan una pérdida o disminución del patrimonio; los de **administración** tienden a su conservación. Es frecuente que las leyes permitan a ciertas personas realizar actos de administración, pero no de disposición, y que cuando permiten estos últimos les impongan requisitos más rigurosos. La distinción es esencial respecto de quienes obran en interés de otro: el tutor o curador puede y debe administrar los bienes del pupilo (**art. 391**), pero no puede, sin previo decreto judicial, enajenar sus bienes raíces ni gravarlos con hipoteca, censo o servidumbre, ni enajenar o empeñar los muebles preciosos o de valor de afección (**art. 393**).

8.5. Entre vivos y por causa de muerte

Esta distinción atiende a si el acto, para producir sus efectos, requiere o no la muerte del autor o de una de las partes. El acto **mortis causa** requiere, como presupuesto necesario e indispensable, de esa muerte para producir la plenitud de sus efectos: el testamento (**art. 999**), el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante. El acto **entre vivos** no requiere de esa muerte para producir los efectos que le son propios.

8.6. Solemnes y no solemnes

Esta distinción atiende a si la ley exige o no formalidades para la celebración del acto. Los actos **solemnes o formales** son aquellos para cuyo perfeccionamiento la ley o la voluntad de las partes exige que la declaración de voluntad se haga en una forma determinada, como la compraventa de bienes raíces, que debe otorgarse por escritura pública. Si un acto solemne se celebra sin cumplir la formalidad prescrita adolece de inexistencia o de nulidad absoluta (**art. 1682**), según la solemnidad se requiera para la existencia o para la validez del acto. Los actos **no solemnes** son aquellos en que la ley no exige forma determinada.

También existen actos solemnes por determinación de las partes: aunque la ley es la que da a un acto el carácter de solemne o no, las partes pueden hacer solemne un acto que por exigencia legal no lo es, como sucede con la compraventa de cosas muebles (**art. 1802**). La diferencia es relevante: si en un acto solemne por mandato de la ley faltan las solemnidades, el acto es nulo absolutamente; en cambio, si es solemne por voluntad de las partes, puede producir efectos aun sin cumplirse las formalidades, si se ejecutan hechos que importen renuncia a ellas.

8.7. Consensuales y reales

Esta distinción atiende a la forma en que se perfecciona el acto. Los actos **consensuales** son aquellos para cuya perfección basta la manifestación de voluntad o el consentimiento de las partes, cualquiera sea su forma (oral, escrita o por señas): la compraventa de cosas muebles, el arrendamiento, el mandato. El consentimiento es la concordancia de dos declaraciones de voluntad emitidas por sujetos diversos que persiguen fines de interés común o de conveniencia recíproca. Los actos **reales** son los que, para perfeccionarse, requieren, junto a la declaración de voluntad, la entrega

de una cosa: el comodato, el mutuo, el depósito, la prenda ordinaria. En materia de contratos, esta distinción está recogida en el **art. 1443**.

8.8. Puros y simples y sujetos a modalidades

Atendiendo a si los efectos del acto se producen o no de inmediato, sin limitación y para siempre, se distingue entre actos **puros y simples** y actos **sujetos a modalidades**. Por *modalidad* se entiende la estipulación consignada en un acto y dirigida a retardar o modificar los efectos que habría producido de ser puro y simple, o a extinguirlos en un momento dado. Las modalidades más importantes son la condición, el plazo y el modo (la carga impuesta al beneficiario de un acto a título gratuito); la doctrina agrega también la representación y la solidaridad, por alterar los efectos normales del acto en que inciden.

EJEMPLO

El modo como modalidad

El testador lega una casa imponiéndole al legatario el deber de hacer construir una capilla en el jardín: esa carga es un modo, una modalidad del acto a título gratuito.

Acto **puro y simple** es, entonces, el que en cuanto se perfecciona da nacimiento a un derecho cuyo ejercicio puede ser inmediato y de duración indefinida, sin alteración por circunstancia o cláusula particular alguna: el no sujeto a modalidades. Acto **sujeto a modalidades** es aquel cuyos efectos están subordinados a circunstancias o cláusulas restrictivas.

8.9. Causales y abstractos

Esta clasificación se profundiza al estudiar la causa como elemento del acto jurídico. Los actos **causales** son aquellos en cuyo perfeccionamiento debe concurrir, como elemento esencial, la causa: si ella falta o es ilícita, el acto adolece de nulidad absoluta y no produce efecto alguno (la compraventa, el arrendamiento, el mutuo, el comodato). Los actos **abstractos** son aquellos en cuyo perfeccionamiento la causa no aparece como elemento constitutivo, funcionando abstraídos de ella: si falta o es ilícita, el acto queda válido y produce sus efectos.

8.10. Principales y accesorios

Esta distinción atiende a si el acto subsiste o no por sí mismo. El acto es **principal** cuando subsiste sin necesidad de otro, como la compraventa. Es **accesorio** cuando, para subsistir, necesita de un acto principal que le sirva de sustento. Los actos accesorios se dividen en de *garantía* (llamados *cauciones* por el **art. 46**, cuando tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de modo que no pueden subsistir sin ella: fianza, hipoteca, prenda) y *dependientes* (los que, para existir o producir sus efectos, están subordinados a la existencia de otros, pero no para

asegurar su cumplimiento, como las convenciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio, que no valen si este no se efectúa, **art. 1716**).

Los actos accesorios pueden existir antes que el acto principal, como ocurre con las capitulaciones matrimoniales o con la hipoteca constituida para caucionar obligaciones futuras (**art. 2413**). Esta clasificación tiene importancia sobre todo para determinar la extinción de unos y otros, conforme al aforismo según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no lo principal la suerte de lo accesorio.

8.11. Constitutivos, declarativos y traslaticios

Los actos **constitutivos** crean un derecho nuevo o una situación jurídica nueva: el matrimonio, que crea el estado civil de casado; los contratos, que hacen nacer obligaciones y crean la calidad de acreedor y deudor. Los actos **declarativos** no hacen nacer un derecho nuevo, sino que se limitan a reconocer una situación o derecho preexistente: el ejemplo típico es la partición, que pone fin a la comunidad sustituyendo las partes indivisas de los comuneros por partes divididas, sin que haya transferencia entre ellos, pues se reputa que cada uno ha tenido siempre, desde el nacimiento de la comunidad, la parte que se le adjudicó. La retroactividad, aunque no esencial, es una consecuencia natural de los actos declarativos, que tienden a producir sus efectos desde que se originó la relación jurídica, no solo desde que se constató o reconoció.

Los actos **traslaticios o traslativos** son los que transfieren a un nuevo titular un derecho ya existente: la cesión de un crédito, la tradición de un derecho real.

8.12. De ejecución instantánea, diferida y de tracto sucesivo

Esta clasificación atiende a la permanencia en el tiempo de los actos jurídicos. Los actos de **ejecución instantánea** producen sus efectos inmediatamente de celebrados, de manera que, realizada la prestación debida, desaparece el vínculo contractual y las obligaciones recíprocas. Los de **ejecución diferida** son aquellos cuyos efectos se van cumpliendo progresivamente, en el plazo estipulado por las partes. Los de **tracto sucesivo** son aquellos cuyas obligaciones van naciendo y extinguiéndose sucesiva y periódicamente mientras dure su vigencia, es decir, la relación contractual se agota y se renueva por períodos continuos, como en el arrendamiento.

8.13. Típicos o nominados y atípicos o innominados

Los actos **nominados o típicos** son los configurados por la ley con caracteres peculiares: el matrimonio, la adopción, el testamento, la compraventa, el arrendamiento, el mandato, la hipoteca. Los **innominados o atípicos** son los que la ley no ha configurado ni les ha trazado su figura propia, y surgen como creación de los particulares cuando sus necesidades e intereses no encuentran adecuado medio de expresión en los actos típicos.

Para calificar a un acto como nominado o innominado no se atiende a si tiene o no un nombre, ni basta que la ley lo mencione para determinados efectos sin disciplinarlo como figura jurídica especial. Un acto puede ser nominado en el ordenamiento de un país e innominado en el de otro, y un contrato innominado puede pasar a ser nominado si el legislador llega después a disciplinarlo especialmente, como ocurrió con el *leasing habitacional*, arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, figura nueva creada de la amalgama de esos dos contratos.

Los actos innominados, conforme al principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de las convenciones, tienen pleno valor siempre que se ajusten a las normas generales que regulan los actos y declaraciones de voluntad, al orden público y a las buenas costumbres.

B. LA VOLUNTAD

1. CONCEPTOS GENERALES

La voluntad es el libre querer interno de hacer o no hacer alguna cosa, y es el elemento base de todo acto jurídico. Así, la voluntad es, en los términos del **art. 1444**, una cosa esencial sin la cual el acto no produce efecto alguno, lo que algunos autores interpretan como inexistencia y otros como nulidad absoluta, como se ahondará más adelante.

Para generar un acto jurídico unilateral basta con la sola voluntad de su autor; en cambio, en los actos jurídicos bilaterales es esencial la presencia de dos voluntades, y más de dos para los actos plurilaterales. En este caso las voluntades concordantes toman el nombre de **consentimiento**. Pero es de advertir que a menudo la palabra consentimiento es tomada, de una manera general, como sinónimo de voluntad, o sea, se habla de consentimiento tanto para referirse a la única voluntad de los actos unilaterales como a las dos o más de los actos bilaterales y plurilaterales.

2. REQUISITOS DE LA VOLUNTAD

Para que la voluntad sea considerada por el Derecho es preciso que sea seria y que se manifieste o exteriorice.

2.1. Seriedad de la voluntad

La voluntad es seria cuando se emite con el propósito de producir efectos jurídicos, esto es, de producir un efecto práctico sancionado por el derecho. Por ende, no es seria la voluntad que se manifiesta solo por cortesía, con el propósito de bromear, o similares, cuestión que deberá determinar el juez en cada caso. Así, carece de seriedad la oferta de celebrar un contrato que, contenida en el libreto de una obra teatral, es manifestada al público asistente a la representación de la obra.

2.2. Manifestación de la voluntad

La voluntad, mientras permanece en el fuero interno del individuo, es indiferente al Derecho. Para que este la considere es preciso que se proyecte externamente, que se declare, que se manifieste. Puede manifestarse en diversas formas: expresa, tácita y, a veces, por el silencio.

(i) Manifestación de voluntad expresa.

Es expresa cuando se emplea, consciente y deliberadamente, un modo dirigido a hacer conocer la propia voluntad, sin necesidad de ninguna circunstancia concurrente: se exterioriza a través de una declaración en palabras, habladas o escritas, o incluso gestos (por ejemplo, la celebración de un contrato por escritura pública, o alzar la mano en una votación). Se afirma en doctrina que sobre el declarante pesa la obligación de hablar claro, sin ambigüedades: la claridad es un deber que le im-

pone el principio de la buena fe contractual (**art. 1546**), y por ello tiene que soportar las consecuencias de su falta de claridad. Por eso, conforme al **art. 1566**, las cláusulas ambiguas dictadas por una parte se interpretan en su contra, siempre que la ambigüedad provenga de una falta de explicación que le sea imputable.

(ii) Manifestación de voluntad tácita.

Es tácita cuando se infiere del comportamiento del sujeto, esto es, de un hecho positivo concluyente (de significado irrefutable) e inequívoco (que no se presta a diversas interpretaciones). Por ejemplo, si en una tienda una persona coge un objeto y pide al empleado que se lo envuelva, su voluntad de comprar la cosa no admite duda, aunque no haya abierto la boca.

(iii) La manifestación de voluntad en el Código Civil chileno.

Por regla general, la manifestación expresa y la tácita tienen el mismo valor, como reconocen las normas sobre aceptación de una herencia (**art. 1241**) o de un mandato (**art. 2124**); el Código de Comercio les atribuye igual valor (**art. 103**). Por excepción, en ciertos casos el legislador exige que la voluntad se declare expresamente, sin que baste la tácita: así ocurre en el testamento (**arts. 1060 y 1023**) y en la solidaridad (**art. 1511**). Las partes, además, pueden convenir en virtud de la autonomía privada que la voluntad siempre se declare explícita y directamente.

(iv) El silencio como manifestación de voluntad.

Por silencio se entiende no solo la ausencia total del habla, sino también la de todo gesto o movimiento corporal significativo de una aceptación o negación. Por regla general el silencio, así entendido, jamás puede por sí mismo constituir una manifestación de voluntad: en el campo del Derecho no rige el adagio de que el que calla otorga, sino el dicho romano de que *el que calla es cierto que no confiesa, pero también es verdad que no niega*. El que calla, pues, en el ámbito jurídico no dice sí ni no.

Sin embargo, por excepción el silencio puede tener el valor de manifestación de voluntad en los siguientes casos:

NO CONFUNDIR**Las tres excepciones en que el silencio sí vale como voluntad**

a. **La ley** puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad. Por ejemplo, dispone que *las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace; y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación (art. 2125)*. Igual cosa ocurre con el **art. 1233**, que establece que el asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia una herencia se presume por la ley que repudia.

b. **Las partes** mismas pueden acordar que el silencio envuelva una manifestación de voluntad. Es corriente que en los contratos de arrendamiento, de trabajo o de sociedad se estipule que se entenderán prorrogados por períodos sucesivos si ninguno de los contratantes, antes de su vencimiento, manifestare su voluntad de ponerle término. Si bien es admisible que las partes estipulen el silencio como declaración de voluntad, ninguna puede unilateralmente atribuir un determinado significado al silencio ajeno: así, carece de validez la propuesta de celebrar un contrato en que el proponente advierte al destinatario que su silencio se mirará como aceptación.

c. **El juez** puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad. Aunque el silencio por sí mismo y por sí solo no puede constituirlo, sí puede hacerlo el silencio *circunstanciado*, es decir, acompañado de determinadas circunstancias que le presten elocuencia.

3. LA VOLUNTAD EN LAS DIVERSAS CLASES DE ACTOS JURÍDICOS

3.1. La voluntad en los actos jurídicos unilaterales

En los actos unilaterales únicamente se requiere la voluntad de su autor. Sin embargo, en esta clase de actos se suele distinguir si para su perfección se exige o no que sean conocidos por el destinatario de la voluntad del autor. Así, los actos jurídicos unilaterales **no recepticios** se perfeccionan en el momento en que la voluntad se declara o manifiesta en la forma prescrita por la ley (el testamento). En cambio, los actos jurídicos unilaterales **recepticios** se perfeccionan cuando llegan a conocimiento de la persona a la cual están dirigidos (el desahucio del arrendamiento de una cosa sin plazo fijo), y a partir de ese momento son de carácter irrevocable.

3.2. La voluntad en los actos jurídicos bilaterales: el consentimiento

La voluntad en los actos bilaterales toma el nombre de **consentimiento**, que basta por sí solo para la formación de los contratos consensuales. Ha sido definido como el encuentro de dos declaraciones de voluntad que, emitidas por dos sujetos diversos, se dirigen a un fin común y se funden.

Regulación legal de la formación del consentimiento

El Código Civil no regula el proceso de formación del consentimiento, sino los caracteres que debe tener para su existencia y validez. Es el Código de Comercio el que dedica sus **arts. 97 a 108** a normar ese proceso. Sus reglas, aunque contenidas en un código especial, son por su naturaleza generales y deben, por tanto, tener aplicación general, conforme al principio según el cual el alcance de las disposiciones lo fija su propia naturaleza y no la ubicación que tienen en un determinado Código o ley: las reglas sobre formación del consentimiento del Código de Comercio son de naturaleza general, no especial ni excepcional. Así lo entendió también el Mensaje con que el Presidente de la República presentó el proyecto de Código de Comercio al Congreso Nacional, documento que forma parte de la historia de la ley y que expresa que, en esta materia, el Código de Comercio viene a llenar un *sensible vacío de nuestra legislación comercial y civil*.

De las disposiciones del Código de Comercio se desprende que la formación del consentimiento requiere la concurrencia de dos actos sucesivos: la **oferta** y la **aceptación**.

a) La oferta

Se llama **oferta, policitud o propuesta** al acto jurídico unilateral por el cual una parte propone a otra celebrar una convención determinada. La parte que hace la oferta recibe el nombre de *oferente*, proponente o policitante.

En cuanto acto jurídico, la oferta debe cumplir los correspondientes requisitos de existencia y de validez. Por ende, se requiere que la voluntad del oferente sea seria, esto es, con la intención de obligarse. Adicionalmente, se requiere que la oferta sea **completa**, entendiéndose por tal aquella que se formula en términos tales que basta la simple aquiescencia o aprobación de la persona a quien se ha dirigido, para que la convención propuesta se perfeccione (*te vendo tal cosa a tal precio*). La propuesta que no indica los elementos esenciales de la convención es una **oferta incompleta** (*te vendo tal cosa a un precio módico*), en la que el oferente pretende establecer una negociación o conversación preliminar, de la cual puede derivar una oferta completa; la respuesta del destinatario, formulando a su vez una oferta, se llama **contraoferta**. Si la oferta incompleta se responde con una contraoferta completa que es aceptada por el primitivo oferente, se forma el consentimiento.

(i) Oferta expresa.

Es la que revela directa y explícitamente la voluntad de contratar. Puede ser verbal (por palabras o gestos) o escrita.

(ii) Oferta tácita.

Es la que se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la proposición de celebrar una convención. Son ejemplos de oferta tácita la circulación de vehículos de servicio público (ofrecen celebrar el contrato de transporte), los restaurantes automáticos, la exhibición en vitrinas

comerciales de mercaderías con el precio fijado, y los aparatos que mediante la introducción de monedas proporcionan mercaderías.

(iii) Oferta hecha a persona determinada.

Es aquella que va dirigida a un sujeto debidamente individualizado, sea o no conocido del oferente. El **art. 105** inciso 2° establece que las ofertas por anuncios dirigidas a personas determinadas llevan siempre la condición implícita de que, al tiempo de la demanda: (1) no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos; (2) no hayan sufrido alteración en su precio; y (3) existan en el domicilio del oferente.

(iv) Oferta hecha a persona indeterminada.

Tiene lugar cuando se dirige al público en general, y no a una persona en particular, en términos tales que cualquiera puede aceptarla, y quien la acepte tendrá derecho a exigir el cumplimiento del contrato. Son ejemplos los avisos en los diarios, los carteles, los prospectos, las circulares y los gritos de los vendedores ambulantes invitando a comprar sus mercaderías; en general, todos los establecimientos comerciales que ofrecen sus mercancías o servicios mediante un precio señalado de antemano hacen una oferta a personas indeterminadas.

NO CONFUNDIR

Oferta a persona indeterminada por anuncios: no obliga, salvo consumidor

El **art. 105** del Código de Comercio establece que las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, o en cualquiera otra especie de anuncios impresos, *no son obligatorias para el que las hace*. Ciertos autores estiman que esta norma se entiende derogada respecto de los contratos celebrados al amparo de la Ley N° 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores, que obliga a todo proveedor a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio (**art. 12**). Desde luego, tal derogación solo se extiende a los actos a los que le son aplicables esta ley.

b) La aceptación

Es el acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su total conformidad con esta. El destinatario que acepta la oferta se llama *aceptante*.

(i) Aceptación expresa.

Es expresa cuando la voluntad de aceptar se declara en términos explícitos, sea verbalmente o por escrito, según lo requiera la ley. Puede ser, entonces, verbal (por palabras o gestos) o escrita.

(ii) Aceptación tácita.

Es la que se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la aquiescencia o asentimiento a la oferta. Conforme al **art. 103 C. de Comercio**, la aceptación tácita produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa.

EJEMPLO

Aceptación tácita: subir a un taxi estacionado

Quien abre la puerta de un taxi estacionado en un paradero y sube, sin decir palabra, acepta inequívocamente la oferta de celebrar el contrato de transporte: es un caso de aceptación tácita de una oferta a personas indeterminadas.

(iii) Aceptación pura y simple.

La aceptación es pura y simple cuando implica adhesión a la oferta en los mismos términos en que esta ha sido formulada, es decir, cuando es congruente con la oferta. Si alguien me ofrece venderme, por determinado precio, cien libros colocados en mi casa, y yo respondo *conforme*, quiere decir que he aceptado expresa, pura y simplemente.

(iv) Aceptación condicionada.

La aceptación es condicional cuando contiene reservas o modificaciones que alteran los términos de la oferta, cuando entre esta y aquella no hay concordancia absoluta. Conforme al **art. 102 C. de Comercio**, la aceptación condicionada importa una contraoferta: si el oferente acepta las modificaciones, pasa a ser aceptante de la oferta modificada, y quien aceptó condicionalmente queda como nuevo oferente.

Puede ocurrir que la oferta comprenda varias cosas y que el destinatario se pronuncie solo respecto de alguna de ellas. En tal caso, para determinar los efectos de la aceptación parcial hay que distinguir dos situaciones: si la intención del proponente era formular una oferta divisible, se entiende que hizo varias ofertas y el consentimiento se forma respecto de aquellas que el destinatario aceptó; si su intención era formular una oferta indivisible, la aceptación parcial no es idónea para formar el consentimiento y tiene solo el alcance de una contraoferta.

EJEMPLO

Aceptación parcial de una oferta divisible o indivisible

A ofrece a B vender una mesa de comedor con doce sillas y B acepta comprar la mesa, pero no las sillas. Si la intención de A era formular una oferta divisible, se entiende que hizo varias ofertas y el consentimiento se forma respecto de la que B aceptó. Si su intención era una oferta indivisible, la aceptación parcial de B no forma consentimiento y vale solo como contraoferta.

Para que se forme el consentimiento, la aceptación debe ser pura y simple, darse en tiempo oportuno, y darse mientras se encuentre vigente la oferta.

(i) La aceptación debe ser pura y simple.

Así lo dispone el **art. 101 C. de Comercio**: dada la contestación, si en ella se aprueba pura y simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos legales, a no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente. El **art. 102** agrega que la aceptación condicional será considerada como una propuesta.

(ii) La aceptación debe darse en tiempo oportuno.

Se da en tiempo oportuno cuando se manifiesta dentro del plazo legal, o dentro del plazo señalado por el oferente en su caso; si el oferente no hubiere señalado un plazo para el pronunciamiento del destinatario, este debe aceptar dentro del término establecido por la ley. Los **arts. 97 y 98 C. de Comercio** regulan el plazo legal en que debe pronunciarse el destinatario, distinguiendo lo siguiente. Si es **verbal**, la aceptación debe darse en el acto de ser conocida, es decir, comprendida (**art. 97**): si se hace una oferta verbal y esta no es comprendida, no rige la regla. Se considera aplicable esta misma regla cuando la oferta se hace por teléfono, radio u otro medio que permita comunicación verbal inmediata, pues aun sin estar oferente y destinatario físicamente frente a frente, y pudiendo encontrarse en lugares muy distantes, esos medios permiten al destinatario pronunciarse sobre la oferta en el acto mismo de ser conocida.

Si la oferta se hizo por **escrito (art. 98 C. de Comercio)**, debe aceptarse o rechazarse dentro de veinticuatro horas si el aceptante reside en el mismo lugar que el proponente (cuestión de hecho que corresponde determinar al juez), o *a vuelta de correo* si reside en un lugar distinto, expresión que la ley no define, ni contiene elementos para determinar su naturaleza y extensión: la Corte Suprema la ha entregado a la prudente apreciación de los jueces de la instancia, y el diccionario de la RAE la define como *por correo inmediato, sin perder día*. Vencidos esos plazos, la propuesta se tiene por no hecha aun cuando hubiese sido aceptada: se produce la caducidad de la oferta, y la aceptación que se emite después es una aceptación extemporánea, que no da nacimiento al contrato. Con todo, aun en estas hipótesis el proponente está obligado a dar pronto aviso de su retractación, de lo contrario deberá responder de los daños y perjuicios que su silencio ocasionare al aceptante extemporáneo (**art. 98** incisos 2° y 3°).

DATO DE GRADO

La aceptación no se presume

La aceptación no se presume: en caso de controversia sobre su existencia, corresponde probarla a quien quiera prevalecerse de ella. Pero una vez probada la aceptación, se presume que esta se ha dado dentro de plazo, a menos que se acredite lo contrario.

(iii) La aceptación debe darse mientras la oferta esté vigente.

Hay ciertos hechos que traen como consecuencia que la oferta deje de estar vigente, de modo que la aceptación dada con posterioridad a ellos no es idónea para formar el consentimiento: la **retractación** del proponente, su **muerte** o su **incapacidad legal sobreviniente**. Tanto la muerte como la incapacidad legal sobreviniente obstan a la formación del contrato si se producen antes de que se manifieste la aceptación (**art. 101 C. de Comercio**).

Hay retractación cuando el proponente, arrepentido de haber hecho la oferta, la revoca, la deja sin efecto, se desdice de ella. Conforme al **art. 99 C. de Comercio**, el oferente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que se hubiere comprometido a esperar contestación, o a no disponer del objeto del contrato sino después de desechada la oferta o de transcurrido un determinado plazo. La retractación es *tempestiva* cuando se hace antes de que la oferta sea aceptada: produce plenos efectos (la oferta no subsiste y no se forma el consentimiento), pero obliga al proponente a indemnizar los gastos hechos por el destinatario y los daños y perjuicios que hubiere sufrido, pues de lo contrario el destinatario permanecería siempre en estado de inseguridad y jamás podría tomar medida alguna para aceptar la oferta sin correr el riesgo de sacrificios pecuniarios inútiles y no indemnizables: si tal ocurriera, difícil se haría la vida de los negocios. El proponente puede, con todo, exonerarse de esta obligación cumpliendo el contrato propuesto, es decir, dejando sin efecto su retractación (**art. 100**).

La retractación es *intempestiva* cuando se hace después de aceptada la oferta, o antes pero habiéndose comprometido el oferente a esperar contestación o a no disponer del objeto: en ese caso no produce efecto alguno, la oferta subsiste y, si la aceptación es oportuna, el contrato se forma, quedando obligado el proponente a cumplirlo.

b) Momento y lugar en que se forma el consentimiento

El momento en que se forma el consentimiento tiene importancia práctica para diversos efectos, entre otros:

(i) Para establecer si las partes eran o no capaces de concluir el contrato

, atendido que las partes deben ser capaces al momento de contratar.

(ii) Para determinar la norma aplicable en caso de modificación de las leyes

, pues conforme al **art. 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes**, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración.

(iii) En cuanto al objeto

, este debe ser lícito al momento de contratar.

(iv) En cuanto a los efectos del contrato

, este los produce, por regla general, desde que se perfecciona.

Se han formulado diversas teorías principales para determinar ese momento:

a. Teoría de la declaración.

El contrato se perfecciona en el momento en que se acepta la oferta, aunque el proponente todavía la ignore.

b. Teoría de la expedición.

El contrato se perfecciona cuando el aceptante se desprende de su voluntad de aceptar, por ejemplo al depositar en el correo la carta con su aceptación, sin que sea necesario que el oferente la haya recibido.

c. Teoría de la recepción.

El consentimiento se forma cuando la aceptación llega al domicilio del oferente, aunque este todavía la ignore.

d. Teoría de la información o del conocimiento.

El contrato se perfecciona cuando el proponente tiene conocimiento real y efectivo de la aceptación.

Nuestro ordenamiento se inclina por la **teoría de la declaración**: el **art. 101 del Código de Comercio** señala que dada la contestación que aprueba pura y simplemente la propuesta, el contrato queda perfeccionado, y el **art. 99** permite la retractación solo hasta antes de la aceptación, es decir, el contrato queda firme aun antes de que el proponente conozca esa aceptación. Por excepción, no se forma el consentimiento al darse la aceptación cuando las partes han estipulado que se estime concluido en otro momento: esto pueden hacerlo porque la regla legal relativa al momento en que se perfecciona el contrato consensual no es de orden público, y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad las partes pueden establecer que ese momento sea otro. También constituye excepción la donación entre vivos, que se perfecciona cuando la aceptación del donatario ha sido notificada al donante (**art. 1412**), siguiendo ahí la teoría del conocimiento.

En cuanto al **lugar**, nuestra legislación dispone que, residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá celebrado el contrato, para todos sus efectos legales, en el de la residencia de quien hubiere aceptado la propuesta primitiva o la propuesta modificada (**art. 104 C. de Comercio**). Tiene importancia determinar el lugar en que se celebra el contrato para diversos efectos: (a) para la fijación de la competencia del tribunal, en caso de que en el mismo contrato no se establezca un domicilio convencional; y (b) para determinar el país en que se ha celebrado el contrato, pues es de gran interés saber qué ley se le debe aplicar, ciñéndose al principio según el cual los actos jurídicos se rigen por la ley del país en que se celebran (*lex loci rei sitae*).

c) Etapas de la formación del consentimiento según la teoría moderna: la responsabilidad precontractual

La doctrina advierte que la regulación legal de la formación del consentimiento no recoge adecuadamente la realidad práctica, en cuanto, previo a la oferta, suele existir un período previo de negociación o tratativas preliminares. Se denomina *etapa de negociación preliminar* al período en que las partes desarrollan una multiplicidad de conductas tendientes a conocer sus puntos de vista respecto de un negocio que se proyecta, sin que por ello entiendan quedar obligadas.

El tema ha sido objeto de un detallado análisis, a fin de establecer si en esta etapa previa a la formación del contrato podría o no surgir una responsabilidad para los partícipes de la negociación, responsabilidad que suele denominarse **precontractual**. Sobre la materia, es necesario considerar que durante el período precontractual aún no hay intención de obligarse, sino que existe libertad para negociar, debatir distintas posturas, y así explorar si es o no bueno contratar, intercambiando información.

La doctrina tradicional sostiene que, en esta etapa, rige el principio de la libertad de contratar: hay ausencia de obligaciones y, por tanto, ningún reproche si hay un desistimiento unilateral, pues se ejerce el libre derecho de desistirse del eventual contrato, aunque haya daños. La doctrina moderna, en cambio, cree que sí puede surgir responsabilidad precontractual.

DATO DE GRADO

¿Cuándo hay responsabilidad por retirarse de una negociación?

FAGUELLA sostiene que habrá responsabilidad cuando una de las partes se retira arbitrariamente de las negociaciones, y es arbitrario cuando hay una violación de la confianza que se genera al consentir, al tratar, o bien cuando se viola el *pacto de garantía* al negociar, que tiende a resguardar que las negociaciones seguirán su curso normal hasta llegar a la celebración de un contrato o hasta el fracaso de las negociaciones, por existir intereses económicos irreconciliables. Se le critica por ser muy rígido lo que plantea: nadie negociaría en esas condiciones. Por lo mismo, otros autores, como **SALEIYES**, afirman que no puede haber responsabilidad sin culpa, y que hay culpa cuando se infringen los usos impuestos y la equidad comercial.

En la doctrina nacional, **ROSENDE** exige tres requisitos. (i) Que haya existido consentimiento en las tratativas preliminares o acuerdo en negociar. Siempre se debe respetar el principio de la libertad para negociar (decidir si se contrata o no), pero cuidando de respetar el patrimonio ajeno: las partes deben ejercer su libertad dentro del marco de la buena fe, que morigeró lo anterior. Si se viola la buena fe negociando y se causa un daño con culpa, cabe la indemnización, pues se está cometiendo un ilícito civil (un delito civil, si el hecho además es ilícito); si el hecho es lícito, también podría haber responsabilidad precontractual, pues puede tratarse de un caso de enriquecimiento sin causa.

(ii) Que se hayan efectuado gastos por una de las partes en vías del contrato. Hay que distinguir: si las partes han estipulado la forma en que se han de solventar los gastos, regirá ese acuerdo y habrá, consecuentemente, responsabilidad contractual; si no se ha estipulado nada al respecto, hay que determinar quién los paga en la etapa de negociación, según si se realizaron antes de la negociación o durante ella. Los gastos incurridos *antes* de la negociación (por ejemplo, publicidad) son de cargo de quien los realiza, porque van en su propio beneficio, salvo que otro se haya aprovechado también de ellos, caso en que habría enriquecimiento sin causa, en la medida en que no sea motivo de lucro para quien se empobreció. Respecto de los gastos incurridos *durante* las tratativas, hay que distinguir quién hizo el gasto y quién se beneficia: no hay derecho a reembolso respecto de los que se hacen por iniciativa propia y van en beneficio propio; en cambio, respecto de los que se hacen por iniciativa propia pero benefician a ambas partes, habrá derecho a repetir cuando existe enriquecimiento sin causa.

(iii) Que exista un retiro unilateral de las negociaciones contrario a la buena fe, sin que el solo hecho del retiro genere responsabilidad, pues de lo contrario nadie negociaría: hay que buscar un equilibrio entre la libertad para negociar y el respeto al patrimonio ajeno, y ese equilibrio es la buena fe.

3.3. Casos especiales de formación del consentimiento

Consentimiento en las licitaciones

En la práctica es sumamente usual que los contratos sean precedidos de un procedimiento previo denominado **licitación**, cuya finalidad es seleccionar la persona del co-contratante. La licitación es un proceso, es decir, un conjunto de fases y etapas ordenadas según un orden consecutivo para la obtención de un objetivo: se inicia con el llamado a licitación y finaliza con la suscripción del contrato definitivo, una sucesión de actos ordenados con el propósito de, previo conocimiento y evaluación, constatar a quién debe adjudicarse el contrato licitado.

En el mismo sentido, la doctrina la define como un procedimiento de preparación de la voluntad contractual por el que un ente público o privado, en ejercicio de la función administrativa o de su autonomía de voluntad, invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales se seleccionará la más conveniente; también se la ha definido como *un procedimiento relativo a la forma de celebración de ciertos contratos cuya finalidad es determinar la persona que ofrece condiciones más ventajosas*, y como *una serie de actos que constituyen un procedimiento tendiente a seleccionar la persona de co-contratante y al final del cual nace un vínculo contractual*.

De lo anterior se concluye que el llamado a licitación no constituye en sí mismo una oferta, porque no propone a una persona determinada celebrar una convención determinada, sino que tiene por finalidad que terceros presenten ofertas: *el llamado a licitación o a concurso no es una oferta de contrato, sino una invitación a ofertar, o pedido de propuestas a los eventuales interesados*. En consecuencia, son los receptores del llamado quienes jurídicamente realizan las ofertas de contrato: es de ellos de quienes emana la oferta, para los efectos de las reglas de formación del consentimiento del Código de Comercio. Recibidas las ofertas por el licitante, procede que este adjudique la licitación. La **adjudicación** es el acto por el cual se pone término al proceso precontractual de licitación, esto es, un acto jurídico por el cual el licitante determina, reconoce, declara y acepta la propuesta más ventajosa, poniendo fin al procedimiento precontractual.

Consentimiento en los contratos de adhesión

El **contrato de adhesión** es aquel en que uno solo de los contratantes preestablece las cláusulas, de modo que el otro no puede modificarlas, sino solo aceptarlas o no celebrar el contrato (transporte, empresas que proporcionan gas, energía eléctrica, servicio telefónico, servicio de correo, las asociaciones encargadas de prestaciones de salud, las que administran fondos previsionales, seguros). Se ha cuestionado su carácter de verdaderos contratos: algunos autores han sostenido que se trata de un acto unilateral de voluntad. Pero ha prevalecido la opinión de que sí son contratos, porque para calificar un acto de contrato civil basta el encuentro de dos voluntades exentas de vicios sobre un objeto de interés jurídico, cualquiera sea la forma en que se fijó.

La particularidad esencial de estos contratos, la de no ir precedidos de una libre discusión de las cláusulas, que se encuentran definitivamente establecidas con antelación por uno solo de los posi-

bles contratantes, da margen a abusos de este, que son generalmente grandes empresas dedicadas a satisfacer necesidades primordiales. De ahí que el legislador se vea en la necesidad de regularlos, en mayor o menor grado, para evitar al menos los excesos de los redactores de los contratos de adhesión: así ocurre, en particular, en el **art. 16** de la Ley del Consumidor, que precisamente establece, por razones de equidad, las cláusulas que no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión.

Consentimiento en la autocontratación

El **autocontrato** o contrato consigo mismo es aquel en que la actividad y declaración de una sola parte, en dos calidades diversas, basta para formar el contrato: en este caso, una misma persona asume simultáneamente, en una misma relación, las calidades de oferente y aceptante. El Código Civil alemán prohíbe la autocontratación, salvo autorización en contrario (**art. 181**). Nuestro Código Civil no contiene en esta materia ninguna regla general expresa, pero contempla casos en que admite la posibilidad del autoconsentimiento y casos en que no lo permite o lo permite con restricciones.

Al respecto, regulando el contrato de mandato, dispone que *no podrá el mandatario, por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender; ni vender de lo suyo al mandante lo que este le ha ordenado comprar; si no fuere con aprobación expresa del mandante* (**art. 2144**). Por su lado, otra disposición establece que el mandatario encargado de tomar dinero prestado podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación, al interés corriente; pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante (**art. 2145**). Resulta claro que en estas normas el consentimiento puede ser prestado por una misma persona, actuando al mismo tiempo como vendedor y comprador, o como mutuante y mutuario: hay, pues, un contrato consigo mismo o autocontrato, en que el consentimiento se forma por la declaración de una sola parte que asume las calidades de ambas.

En otras disposiciones se prohíbe el contrato consigo mismo o se lo somete a restricciones (**arts. 410, 412 y 1800**). Así, por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, su cónyuge, cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio (**art. 412**). El autocontrato es viable a través de la representación, porque el representante puede actuar, por un lado, como parte por sí mismo, por sus propios intereses, y, por otro lado, en nombre y por cuenta del representado, por los intereses de este: se habla de *autoconsentimiento* del representante en razón de que las dos voluntades que forman el consentimiento las declara por sí solo.

Consentimiento en los contratos electrónicos

En términos generales, el **contrato electrónico** puede definirse como aquel en que la oferta y la aceptación, y por tanto el consentimiento, se verifican mediante impulsos electrónicos o mensajes (estandarizados o no) contenidos en soportes magnéticos o digitales, entre personas que deben o prefieren comunicarse por ese medio, sin recurrir al lenguaje verbal o escrito. En Chile la regulación legal de la contratación electrónica es bastante precaria. Las principales normas son: (i) el Decreto Supremo N° 81 de 1999, que regula el uso de la firma digital y los documentos electrónicos en la Administración del Estado; (ii) la Ley N° 19.799 de 2002, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; (iii) la Ley N° 19.955 de 2004, que modificó la Ley del Consumidor introduciendo el **art. 12 A** con normas sobre la formación del consentimiento; y (iv) la Ley N° 20.217 de 2007, que modificó el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Firma Electrónica para regular la producción de prueba documental digital. Atendido que esta regulación es bastante incompleta, para analizar la formación del consentimiento en la contratación electrónica es necesario recurrir a las normas del derecho común.

a) En cuanto a la oferta, la práctica usual es realizarla a través de medios electrónicos a persona indeterminada (por ejemplo, mediante catálogos en línea), la que en principio se rige por el **art. 105** del Código de Comercio, conforme al cual no obliga a quien la hace. Sin embargo, el **art. 12** de la Ley del Consumidor dispone que todo proveedor está obligado a respetar las condiciones y modalidades conforme a las cuales hubiere ofrecido la entrega del bien o la prestación del servicio; con todo, esta ley tiene un alcance limitado, porque solo rige para los actos que son comerciales para el proveedor y civiles para el consumidor, y su sanción no consiste en la obligatoriedad de acceder al contrato ofrecido, sino solo en una multa. Para las ofertas que se rigen por la Ley del Consumidor existe una exigencia especial: el **art. 12 A** dispone que, en los contratos celebrados por medios electrónicos o en que se acepta una oferta hecha por catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, el consentimiento no se entiende formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco a las condiciones generales del contrato, con la posibilidad de almacenarlas o imprimirlas.

b) En cuanto a la aceptación, esta puede revestir variadas formas: llenar un formulario en línea, presionar la tecla correspondiente, o enviarla por fax, carta o correo electrónico después de recibida la oferta. La Ley del Consumidor establece que la sola visita del sitio de internet en que se ofrece el acceso a determinados servicios no impone al consumidor obligación alguna, a menos que haya aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas; lo importante es que haya un procedimiento en que la manifestación de voluntad de aceptar sea indubitable e inequívoca. Una vez perfeccionado el contrato, la Ley del Consumidor impone al proveedor una obligación adicional: enviar al consumidor una confirmación escrita, por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que garantice su debido y oportuno conocimiento (previamente indicado al consumidor), que contenga una copia íntegra, clara y legible del contrato.

c) En cuanto al momento de formación del contrato, rigen las normas generales del Código de Comercio: la aceptación manifestada electrónicamente determina la perfección del contrato, aun-

que el mensaje de datos o el impulso electrónico que la contiene no haya llegado aún a conocimiento del oferente.

d) En cuanto al lugar de formación, se aplican las reglas de la legislación común: si los contratantes residen en lugares distintos, el contrato se reputa perfeccionado en el lugar en que reside el aceptante (**art. 104 C. de Comercio**), y no en el lugar donde se encuentra el computador desde el cual dio su aceptación.

4. VICIOS DE LA VOLUNTAD

Para la doctrina que distingue existencia y validez, la ausencia total de voluntad hace al acto inexistente, mientras que la voluntad viciada (pero existente) expone al acto a la nulidad; se sostiene que esta distinción estaría implícita en el **art. 1445 N° 2**, que exige primero consentimiento y luego que ese consentimiento no adolezca de vicios. Para otro sector, la voluntad exenta de vicios es siempre un requisito de eficacia, de modo que tanto la ausencia de voluntad como la voluntad viciada dan lugar siempre a la nulidad.

Existe consenso, en cambio, en que los vicios pueden afectar la voluntad o el consentimiento y producir, por esa vía, la invalidez o ineficacia del acto: estos vicios son el **error**, la **fuerza** y el **dolo** (algunos agregan la lesión en ciertos casos, cuestión discutida). El Código habla de vicios *del consentimiento*, pero esas mismas reglas se aplican también a la voluntad de los actos unilaterales, ya que el consentimiento no es sino el acuerdo de voluntades.

5. EL ERROR

5.1. Concepto

El error es la falsa representación de la realidad, la disconformidad del pensamiento con la realidad: consiste en creer verdadero lo falso y, a la inversa, falso lo verdadero. Por eso varios autores lo consideran un vicio del *conocimiento*, más que del consentimiento.

La realidad, para estos efectos, se refiere a hechos presentes o pasados, pero no futuros: lo que todavía no existe no la constituye. Por eso los **errores de previsión** (una equivocación en la proyección del futuro) no vician el consentimiento. Quien compra un campo esperando que producirá de cierto modo no sufre un error que vicie el consentimiento cuando, tiempo después, el campo produce menos de lo esperado.

El error tampoco debe confundirse con la **ignorancia** (ausencia de todo conocimiento sobre un objeto: quien yerra afirma algo, aunque equivocado, y el ignorante nada puede sostener), aunque en el campo jurídico esta distinción carece de importancia porque el legislador equipara al ignorante con el que yerra. Sí se distingue de la **duda**: quien emite una declaración a sabiendas de que no conoce con exactitud su contenido y efectos ha preferido conscientemente correr un riesgo y no pue-

de invocar después su propio error, porque en el error no hay conciencia de que la representación de la realidad sea falsa, sino la creencia de que es acertada.

5.2. Error de derecho y error de hecho

El **error de derecho** es la ignorancia o el concepto equivocado sobre una norma jurídica, en su existencia, alcance, inteligencia o vigencia. En nuestro ordenamiento, *el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento* (**art. 1452**), consecuencia de que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ha entrado en vigencia (**art. 8**); concuerda con esto que el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario (**art. 706 inc. 4º**). Otras legislaciones siguen un criterio distinto: el Código Civil italiano de 1942 declara que el error de derecho vicia el consentimiento solo cuando ha sido la razón única, o al menos la principal, del contrato (**art. 1429 N° 4**).

Que el error sobre un punto de derecho no vicie el consentimiento quiere decir que quien ha contratado con una persona teniendo un concepto equivocado de la ley, o ignorando una disposición legal que rige el contrato, no puede alegar después ese error para excusarse de cumplir sus obligaciones ni para pedir la nulidad del contrato. No obstante, la regla general del **art. 1452** admite dos excepciones, contempladas en los **arts. 2297 y 2299**, ambas ubicadas en las disposiciones que reglamentan el cuasicontrato del pago de lo no debido, y cuyo fundamento se encuentra en el repudio del enriquecimiento sin causa.

NO CONFUNDIR**Las dos excepciones del pago de lo no debido**

El **art. 2297** establece que se podrá repetir aun lo que se ha pagado por un error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural. El efecto normal del pago es que autoriza a quien lo recibe a retenerlo, sin que esté afecto a devolución; pero ese efecto supone la existencia de una obligación civil o natural que el pago está destinado a extinguir. Por ende, si no existe obligación alguna que sirva de causa o legítimo fundamento al pago, quien lo efectuó podrá repetir, es decir, obligar a quien lo recibió indebidamente a restituirlo. La estricta aplicación del **art. 1452** impediría a quien pagó indebidamente exigir su devolución, problema que soluciona expresamente el **art. 2297** que, como norma especial, prima sobre la general.

El **art. 2299**, corolario del anterior, dispone que del que da lo que no debe no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Normalmente, cuando una persona da a otra lo que no le debe lo hace con intención de efectuar una liberalidad, y es lógico suponer que quien recibe lo que no se le debe lo hace en el sentido de que se le está donando; pero ese efecto solo tiene lugar en la medida en que quien da lo que no debe haya tenido perfecto conocimiento de lo que hacía, en el hecho y en el derecho. Así, el error de derecho impide presumir esa intención de liberalidad, de modo que quien pagó lo no debido tiene derecho a que se le restituya lo pagado.

El **error de hecho** es la ignorancia o el concepto equivocado sobre una persona, una cosa, un acto o cualquier circunstancia material. El Código lo regula en tres artículos (**arts. 1453, 1454 y 1455**), que describen sus distintas hipótesis.

5.3. Diversas clases de error de hecho y sus efectos

El error de hecho puede ser de cuatro clases: esencial, sustancial, sobre las cualidades accidentales y acerca de las personas.

(i) Error esencial u obstáculo

Hay error esencial cuando la diferencia entre la voluntad y su manifestación es de tanta importancia que la parte no habría concluido el acto de haber conocido el verdadero estado de las cosas. El **art. 1453** contempla dos supuestos: que el error recaiga sobre la **especie de acto o contrato** que se ejecuta (una parte entiende préstamo y la otra donación), o sobre la **identidad de la cosa específica** de que se trata (el vendedor entiende vender un caballo y el comprador entiende comprar una vaca).

DATO DE GRADO**¿Cuál es la sanción del error esencial?**

La doctrina nacional está dividida en tres posturas. Para algunos, el error esencial impide que se forme el acuerdo de voluntades, por lo que el acto es **inexistente**. Otros aceptan que falta un requisito de existencia, pero como estiman que la inexistencia no está recogida como sanción en el Código, concluyen que el acto adolece de **nulidad absoluta**. Un tercer grupo, fundado en una interpretación literal, sostiene que la sanción es la **nulidad relativa**: el **art. 1453** dice que el error *vicia el consentimiento*, y el artículo siguiente dice que el error de hecho *vicia asimismo el consentimiento* al referirse al error sustancial, que según el **art. 1682** inciso final está sancionado con nulidad relativa; el empleo de la expresión *asimismo* mostraría que el error esencial del art. 1453 vicia el acto de la misma manera que el error sustancial del art. 1454. Agregan que, si la nulidad absoluta protege el interés general y la moral, el error esencial, que solo perjudica el interés privado de los individuos, debería caer, desde ese punto de vista, dentro de la nulidad relativa.

(ii) Error sustancial

El **art. 1454** dispone que el error de hecho vicia también el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato es diversa de lo que se cree, como cuando una parte supone que el objeto es una barra de plata y en realidad es una masa de otro metal semejante.

La doctrina discute si *sustancia* y *calidad esencial* son sinónimos (postura que los entiende, ambos, en sentido objetivo o material) o si son conceptos distintos, atendido que BELLO se apartó del Código francés (que solo hablaba de *sustancia*) agregando *calidad esencial*, término de naturaleza más bien subjetiva y ligado a la intención de los contratantes, que correspondería determinar al juez según las circunstancias del caso: la paternidad o autoría de una obra de arte, las particularidades jurídicas de una cosa (comprar un fundo ignorando que está en proceso de expropiación), o sus caracteres más apreciados. La fuente toma partido por esta segunda postura, pero precisa que no es necesario agregar un *elemento subjetivo*, esto es, que la esencialidad de la calidad provenga de los motivos personales de las partes, para calificarla como calidad esencial: ese elemento subjetivo solo es relevante para el caso distinto del inciso segundo, cuando una calidad accidental es elevada a esencial por haber sido el principal motivo de una parte, conocido de la otra.

Se discute, además, si constituye o no calidad esencial de la cosa comprada el que esta pertenezca en dominio al vendedor, cuestión relevante porque el **art. 1815** declara válida la compra de cosa ajena, sin que el contrato pueda anularse por el solo hecho de que la cosa vendida no pertenezca al vendedor. La fuente sugiere resolverlo según las circunstancias del caso: si la cosa se adquiere en el comercio establecido, donde el vendedor genera la apariencia de ser el verdadero dueño, es atendible considerar que el dominio de la cosa sí constituye una calidad esencial.

El **art. 1454** inciso segundo agrega que el error sobre *otra cualquiera calidad* de la cosa (es decir, no esencial) no vicia el consentimiento, salvo que esa calidad haya sido el principal motivo para contratar de una de las partes y ese motivo haya sido conocido de la otra. El error sustancial vicia la voluntad y produce **nulidad relativa** (**arts. 1454 y 1682** inciso final).

(iii) Error sobre las cualidades accidentales

Por regla general, el error sobre las cualidades accidentales de la cosa (todas las que no son esenciales) no vicia el consentimiento: si compro cierto libro creyendo que es de papel fino y resulta ser de papel corriente, ese error es irrelevante. Pero si una cualidad accidental fue el principal motivo de una parte para contratar, y ese motivo fue conocido de la otra, el error sobre ella sí vicia el consentimiento (**art. 1454 inc. 2º**), porque esa cualidad accidental fue elevada a la categoría de esencial. La sanción, en ese caso, es la **nulidad relativa** (**art. 1682** inciso final).

(iv) Error acerca de las personas

El **art. 1455** inciso primero dispone que el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esa persona sea la causa principal del contrato. Por regla general este error es irrelevante, porque la persona suele ser indiferente para los fines del acto: al comerciante que vende al contado no le importa quién sea el comprador, solo que pague.

El error en la persona sí es relevante en los actos *intuitu personae*, celebrados en consideración esencial de una o más personas determinadas: los actos de familia (matrimonio, adopción), los contratos gratuitos que se suponen celebrados en consideración de alguien (donación, depósito, comodato) y los onerosos fundados en la confianza en una persona específica (mandato, sociedad civil, arrendamiento de servicios). En el matrimonio, esta relevancia está confirmada por el **art. 8 N° 2** de la Ley de Matrimonio Civil, que considera que falta el consentimiento libre y espontáneo cuando ha habido error acerca de la identidad del otro contrayente (N° 1) o acerca de alguna de sus cualidades personales que, atendida la naturaleza o los fines del matrimonio, deba estimarse determinante para otorgar el consentimiento (N° 2). En estos casos el error vicia el consentimiento con **nulidad relativa**, y quien contrató erradamente con esa persona tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad (**art. 1455**).

5.4. El error en los actos bilaterales

No es necesario que ambas partes padezcan el error para que este vicie el consentimiento: basta que *alguna* de las partes suponga, por ejemplo, que el objeto es una barra de plata cuando es una masa de otro metal (**art. 1454 inc. 1º**). Excepcionalmente se exige que el error sea compartido por ambas partes en el caso del error accidental elevado a la categoría de esencial (**art. 1454 inc. 2º**).

5.5. El error en los actos unilaterales

El error puede invocarse como causa de anulación de todos los actos jurídicos, unilaterales o bilaterales, entre vivos o mortis causa, siempre que sea relevante. Los principales ejemplos están en el testamento: la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de forma que sin ese error no habría tenido lugar, se tiene por no escrita (**art. 1058**); el error en el nombre o calidad del asignatario, en cambio, no vicia la disposición si no hay duda acerca de la persona (**art. 1057**).

5.6. Error común

Es el error compartido por todos los habitantes de una localidad, o por la inmensa mayoría de ellos. Cuando concurren ciertos requisitos, se admite que ese error generalizado no vicia la voluntad y el acto es válido, por tratarse de un error invencible. El ejemplo clásico son los actos autorizados por un funcionario público nombrado con infracción de algún requisito legal, o que ya cesó en sus funciones: las partes no tienen obligación de averiguar esas causas y les basta confiarse en la apariencia de que quien ejerce públicamente un cargo cumple las condiciones legales para hacerlo.

Para que el error común no vicie el consentimiento se requiere: (1) que sea compartido por todos o la inmensa mayoría de los habitantes de una localidad; (2) que tenga un justo motivo, un fundamento lógico que autorice a considerar verdadera una situación falsa; y (3) buena fe de quien lo invoca. Nuestro Código no consagra una regla general al respecto, pero contiene disposiciones inspiradas en este criterio, como la que salva la validez de un testamento por la inhabilidad real de un testigo cuya causal se ignoraba generalmente en el lugar donde se otorgó (**art. 1013**). La doctrina discute si el principio *error communis facit ius* (el error común constituye derecho) se aplica solo a los casos que la ley menciona expresamente o a cualquiera en que concurren sus requisitos. Algunos autores estiman que, salvo cuando lo ordene una norma excepcional y necesariamente expresa, no es aplicable el principio, porque si la ley tuvo necesidad de referirse expresamente en cada caso a la procedencia del error común como excluyente de la invalidez de un acto, es porque no lo acoge en general. A juicio de otros, los preceptos que en diversos casos aplican el principio no hacen sino reflejar la aceptación de una idea general, por lo que la máxima de que el error común no invalida el acto en que concurre debería aplicarse en todos los casos, aunque no estén expresamente contemplados por la ley.

6. EL DOLO

6.1. Concepto

El dolo *consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro* (**art. 44** inciso final): envuelve siempre la voluntad deliberada de perjudicar a otro. Dentro del Derecho Civil actúa en tres campos diversos. En la **celebración** de los actos y contratos, se traduce en el empleo por una persona de trampas, maquinaciones, mentiras u otros artificios dirigidos hacia

otra con el fin de inducirla a otorgar un acto o celebrar un contrato que, sin esas maniobras, no habría celebrado; se le suele definir, en este campo, como *la maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste su consentimiento para la celebración de un acto o contrato*. En el **cumplimiento** de los contratos, no es un vicio del consentimiento sino un hecho que agrava la responsabilidad del deudor, que usa procedimientos ilícitos para burlar al acreedor: en caso de dolo, el contratante incumplidor no solo responde de los perjuicios previstos, que es la regla general, sino también de los imprevistos. Por último, el dolo es un **elemento del delito civil**, la comisión u omisión de un hecho realizada con la intención de dañar a la persona o bienes ajenos. Cualquiera sea el campo en que se aplique, en esencia el dolo siempre envuelve la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Tanto en el dolo como en el error hay una falsa representación de la realidad, pero en el dolo es provocada, mientras que en el error es espontánea.

6.2. Clases de dolo

(i) Dolo bueno y dolo malo.

El *dolo bueno* no tiene fin deshonesto: caben en él las lisonjas, halagos y exageraciones con que una parte busca influir sobre la otra. El *dolo malo* es el que define el Código, la intención positiva de inferir injuria, y es el único que interesa como vicio de la voluntad.

(ii) Dolo positivo y dolo negativo: la reticencia.

El *dolo positivo* consiste en representar como verdaderas circunstancias falsas, o en suprimir o alterar las verdaderas; el *dolo negativo*, en ocultar sagazmente hechos verdaderos. Entre las abstenciones dolosas está la **reticencia**: callar circunstancias que se tiene obligación de hacer saber a otro. Si con ese silencio se induce a alguien a celebrar un acto que no habría celebrado, o lo habría celebrado en otras condiciones, de haber sabido lo callado, su consentimiento queda viciado por dolo negativo, como ocurre con el deber de informar del contrato de seguro (**art. 524 N°s 1 y 2 C. de Comercio**) o con la responsabilidad del vendedor que conocía los vicios de la cosa vendida, o debió conocerlos por su oficio (**art. 1861**).

EJEMPLO

El anticuario que calla que la cómoda es una copia

Un anticuario no advierte al comprador de una cómoda Luis XVI que se trata de una copia y no del original. El consentimiento del comprador queda viciado por dolo negativo: es lógico suponer que en un establecimiento de antigüedades se venden cosas realmente antiguas, y si, por excepción, una no lo es, debe hacerse saber al comprador.

(iii) Dolo principal y dolo incidental.

El *dolo principal, determinante o inductivo* es el que lleva a la persona a celebrar el acto: sin él, no lo habría celebrado. El *dolo incidental* no determina la celebración del acto, pero sí que se concluya en condiciones distintas, generalmente menos onerosas, de las que se habrían pactado sin la maniobra. Hay dolo principal si se pide al vendedor candelabros de plata y este entrega, a sabiendas, unos de cobre plateado; sería solo incidental si, tratándose de los mismos candelabros pedidos, el vendedor asegura falsamente que son de plata para obtener mejor precio.

6.3. Cuándo el dolo vicia el consentimiento

En los actos bilaterales, el dolo vicia el consentimiento cuando es obra de una de las partes y, además, aparece claramente que sin él no se habría contratado (**art. 1458**). En los actos unilaterales el Código no consagra una fórmula general, pero de diversas disposiciones (el testamento, **art. 968 N° 4**; la renuncia a los gananciales, **art. 1782 inc. 2°**; la aceptación o repudiación de una herencia, **arts. 1234 y 1237**) fluye que basta que el dolo sea determinante, sin importar si proviene de quien se beneficia del acto o de un tercero.

6.4. Prueba del dolo

El dolo no se presume, salvo en los casos especialmente previstos por la ley: en los demás debe probarse, por cualquier medio (**art. 1459**), porque lo que se presume por regla general es la buena fe (**art. 707**), norma que aunque está ubicada a propósito de la posesión se entiende de aplicación general: la jurisprudencia ha aplicado esta presunción de buena fe incluso en materia de Derecho de Familia, a propósito del matrimonio putativo. Excepcionalmente existen presunciones legales de dolo, como en la adquisición por terceros de un bien familiar (**art. 143 inc. 2°**), en el error de derecho en materia posesoria (**art. 706 inc. final**), en la indignidad de quien oculta dolosamente un testamento (**art. 968 N° 5**), o en la prescripción adquisitiva extraordinaria pretendida por un mero tenedor (**art. 2510 N° 3**). También la presume la ley contra el albacea que ejecuta una disposición testamentaria contraria a las leyes (**art. 1301**); contra quien supo y ocultó la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia (**art. 94** regla 6ª); contra quien obtuvo una medida prejudicial y no presenta su demanda dentro del plazo legal (**art. 280 C.P.C.**); y contra quien gira un cheque contra una cuenta corriente cerrada o carente de fondos (**art. 22** de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques).

6.5. Condonación o renuncia del dolo

El perdón o renuncia anticipada del dolo no vale, pues adolece de objeto ilícito: la condonación del dolo futuro no vale (**art. 1465**). El dolo solo puede perdonarse una vez cometido y conocido por la otra parte; de lo contrario sería corriente insertar en los contratos una cláusula liberatoria del dolo.

6.6. Sanción del dolo

Cuando el dolo es principal, y en los actos bilaterales además obra de una de las partes, la sanción es la **nulidad relativa** (**arts. 1458 y 1682** inciso final). Cuando es incidental, o principal pero no obra de una de las partes, no vicia el acto, pero da lugar a la **indemnización de perjuicios** contra quien lo fraguó, por el total de los perjuicios, y contra quien se aprovechó de él, hasta el monto del provecho reportado (**art. 1458**). Si el dolo fue fraguado por dos o más personas, sus autores responden solidariamente (**art. 2317**). La ley establece, además, sanciones especiales para el dolo en ciertos casos: el cónyuge que dolosamente oculta o distrae una cosa de la sociedad conyugal pierde su porción en ella y debe restituirla doblada (**art. 1768**).

6.7. Acción de dolo

La acción de dolo corresponde a la parte inocente, víctima del engaño, contra quien lo empleó, y busca la rescisión del acto; puede hacerse valer como acción o como excepción. Quien cometió el dolo no puede alegar la rescisión, porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo. El plazo para la acción rescisoria es de **cuatro años**, contados desde la celebración del acto (**art. 1691 inc. 2º**), y procede no solo en los contratos sino en otros actos jurídicos, como las particiones (**arts. 1351 y 1352**) o la aceptación de una herencia (**art. 1234**).

7. LA FUERZA

7.1. Concepto

La fuerza o violencia consiste en los apremios físicos o morales ejercidos sobre una persona para que preste su consentimiento en la celebración de un acto jurídico. A diferencia del error y el dolo, que se relacionan con el conocimiento, la fuerza es un vicio de la voluntad porque se opone a la **libertad**.

7.2. Clases

(i) Fuerza física.

Llamada también material o absoluta, busca obtener una apariencia de consentimiento mediante procedimientos violentos: el declarante escribe porque a viva fuerza le conducen la mano, o asiente porque otro le mueve la cabeza. Excluye o suprime la voluntad por completo, por lo que no es propiamente un vicio de ella: en el acto no hay voluntad de la víctima, sino solo apariencia de voluntad, de modo que para parte de la doctrina el acto es **inexistente**.

(ii) Fuerza moral.

Llamada también psíquica o compulsiva, sí existe una manifestación de voluntad, pero impuesta por la amenaza actual de un mal futuro relacionado con la vida, integridad física, honor o patrimonio del sujeto, que prefiere someterse como mal menor. La manifestación de voluntad es consciente, pero coartada: el estudio de la fuerza como vicio de la voluntad se restringe a esta fuerza moral.

7.3. Cuándo la fuerza vicia el consentimiento

Conforme a los **arts. 1456 y 1457**, la fuerza debe ser injusta, grave y determinante.

(i) La fuerza debe ser injusta.

El mal con que se amenaza debe ser ilegítimo, contrario a derecho: el acreedor puede amenazar legítimamente al deudor moroso con demandarlo o pedir su quiebra si no paga, y el pago que resulte de ello es plenamente válido. La doctrina moderna agrega que la fuerza también es injusta cuando, sin ser ilícito en sí mismo el mal amenazado, se enlaza a una ventaja desproporcionada e injusta, como amenazar con denunciar un delito del deudor con el único fin de obtener ventaja sobre los demás acreedores.

(ii) La fuerza debe ser grave.

Es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, según su edad, sexo y condición (**art. 1456 inc. 1º**): la violencia, o mejor dicho el temor que ella infunde, es un concepto relativo, cuya intensidad es diversa en el hombre que en la mujer, en el niño que en el adulto, en el culto que en el ignorante, y depende tanto de la persona amenazada como de la que amenaza. Como la fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir esa impresión fuerte, se desprende que la amenaza debe ser verosímil, es decir, ofrecer posibilidades reales de cumplirse. Se mira como grave todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave en su vida, integridad física, honor o patrimonio; la doctrina admite que también puede acreditarse ese justo temor respecto de otras personas muy queridas no mencionadas expresamente por el Código, aunque sin la presunción legal que sí opera para las mencionadas. Algunos autores agregan como requisito adicional que la fuerza sea *actual*, esto es, presente al momento de expresarse el consentimiento aunque el mal amenazado haya de realizarse en el futuro; pero esta condición se supone y va implícita en el requisito de la gravedad.

(iii) La fuerza debe ser determinante.

El consentimiento obtenido debe ser consecuencia inmediata y directa de la amenaza, de modo que sin la fuerza la víctima no habría celebrado el acto: el **art. 1457** exige que se haya empleado con el objeto de obtener el consentimiento.

7.4. Indiferencia de la persona que ejerce la fuerza

A diferencia del dolo, no es necesario que la fuerza la ejerza quien se beneficia con ella: basta que la haya empleado cualquier persona con el fin de obtener el consentimiento (**art. 1457**). Se explica porque es más difícil defenderse de la violencia que del dolo, y porque quien presiona a otro para contratar suele valerse de un tercero.

7.5. Prueba de la fuerza

Incumbe a quien la alega, y puede acreditarse por todos los medios que franquea la ley, incluso testigos, por tratarse de la prueba de un simple hecho.

7.6. Efectos de la fuerza

La fuerza moral injusta, grave y determinante produce **nulidad relativa** del acto (**art. 1682** inciso final). En la fuerza física, en cambio, no hay voluntad, por lo que el acto es **inexistente** para quienes admiten esa sanción, o al menos **nulo absolutamente** para quienes consideran que la inexistencia no está recogida en el Código.

7.7. Prescripción de la acción de nulidad

La acción de nulidad de un acto viciado por la fuerza prescribe en **cuatro años**, contados desde que la violencia hubiere cesado (**art. 1691 inc. 2º**).

7.8. Temor reverencial

El solo temor de desagradar a quienes se debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento (**art. 1456 inc. 2º**). Si a ese respeto se suma una violencia injusta, grave y determinante, el consentimiento sí queda viciado. Por regla general el temor reverencial carece de relevancia jurídica, salvo en materia de indignidad para suceder, donde no puede alegarse contra quien, por temor reverencial, prometió al causante hacer pasar bienes a un incapaz, a menos que haya ejecutado la promesa (**art. 972**).

8. LESIÓN Y SIMULACIÓN: REMISIÓN

La doctrina tradicional suele estudiar la lesión y la simulación a propósito de la voluntad, junto a sus vicios. Este manual se aparta de esa tradición porque, en rigor, ninguna de las dos figuras dice relación con el consentimiento como requisito de la voluntad. La **lesión** consiste en el perjuicio que experimenta una persona por la desigualdad entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla, y se relaciona más propiamente con el *objeto* del acto jurídico; además, la mayoría de la doctrina nacional estima que no constituye un vicio del consentimiento, porque los casos que regu-

la el Código (salvo el del **art. 1234**) se configuran por un desequilibrio objetivo, sin exigir un elemento subjetivo adicional.

La **simulación**, por su parte, tiene lugar cuando existe una divergencia consciente y deliberada entre la voluntad real y la declarada, sea porque las partes no querían celebrar ningún acto (simulación *absoluta*) o porque querían celebrar uno distinto del aparentado (simulación *relativa*). Aunque algunos fallos hablan de falta de consentimiento, eso solo podría predicarse de la simulación absoluta: la generalidad de la doctrina y jurisprudencia la vincula, en cambio, con la *causa* del acto, que faltaría en la simulación absoluta y sería ilícita en la relativa. Por estas particularidades, la lesión y la simulación se estudian en el capítulo de la ineficacia de los actos jurídicos.

C. LA CAPACIDAD

1. CONCEPTO

La capacidad se define como la aptitud para adquirir derechos y ejercitarlos. De ahí se deduce que es de dos clases: de **goce** o capacidad jurídica, y de **ejercicio** o de obrar.

2. CLASES DE CAPACIDAD

2.1. Capacidad de goce

Es la idoneidad o aptitud para adquirir, gozar y ser titular de un derecho, es decir, la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Se adquiere desde el nacimiento y están dotados de ella todos los seres humanos sin excepción, a diferencia de la antigüedad, cuando había hombres (los esclavos) que no eran personas, sino objetos de derecho.

El concepto de personalidad se confunde así con el de capacidad de goce: ser persona es tener capacidad de goce, y por eso no existen seres humanos desprovistos en absoluto de ella. Privar a un ser humano de la capacidad para adquirir todo derecho sería dejar de considerarlo persona.

En nuestra legislación solo hay **incapacidades de goce especiales**, referidas a uno o más derechos determinados, pero nunca una incapacidad de goce absoluta. La ley contempla algunas de estas incapacidades, respecto de derechos determinados, llamadas *incapacidades particulares*: consisten en la prohibición que la ley impone a ciertas personas para ejecutar o celebrar algunos actos o contratos (por ejemplo, **arts. 402, 412, 961, 965, 1065 y 1796 a 1800**). En cambio, sí es posible estar totalmente desprovisto de **capacidad de ejercicio**, porque esta no es un atributo de la personalidad: hay personas que, aunque tienen el goce de un derecho, no tienen su ejercicio. Son, propiamente, los *incapaces*.

2.2. Capacidad de ejercicio

Llamada por el Código *capacidad legal*, es el poder de una persona de obligarse por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra (**art. 1445** inciso final): la idoneidad del sujeto para celebrar actos jurídicos por sí solo. Es la **regla general**: toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces (**art. 1446**), regla general para todos los actos jurídicos aunque el Código la formule a propósito de las obligaciones y los contratos.

3. LAS INCAPACIDADES DE EJERCICIO

Como no existen incapaces de goce en general, no corresponde estudiar quiénes son capaces (la capacidad es la regla), sino quiénes son incapaces de ejercicio. La incapacidad de ejercicio puede ser absoluta, relativa o particular.

3.1. Incapacidad absoluta

El incapaz absoluto está impedido de ejercitar sus derechos bajo cualquier respecto o circunstancia: no puede ejecutar ningún acto jurídico por sí solo. Conforme al **art. 1447**, son absolutamente incapaces:

a. Los dementes.

El legislador usa el término en un sentido amplio: la jurisprudencia lo ha entendido como enfermedad mental, no en su significado científico. Los dementes son incapaces aunque no estén bajo interdicción (privados por resolución judicial de administrar sus bienes), pues basta que tengan perturbadas sus facultades mentales. Los actos posteriores al decreto de interdicción son nulos, aunque se alegue un intervalo lúcido; los anteriores son válidos, salvo que se pruebe que quien los celebró estaba demente (**art. 465**).

b. Los impúberes.

Conforme al **art. 26**, impúber es el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12.

c. Los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

Su incapacidad radica en la falta de medios para expresar cabalmente su voluntad. Desde la reforma de la Ley N° 19.904 (2003), no es incapaz quien puede darse a entender de cualquier modo, incluido el lenguaje de señas: antes, la norma exigía que pudiera hacerlo *por escrito*, lo que dejaba fuera al sordomudo analfabeto capaz de comunicarse por señas.

CORTE DE CONCEPCIÓN, 1896

La demencia designa, dados el motivo y objeto por que se somete a curatela, no solo a quienes por debilidad o desórdenes intelectuales, de carácter habitual, carecen en absoluto de razón, sino también a quienes, por las mismas causas, no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios.

CORTE DE CONCEPCIÓN, 2008

Aplicando la regla de interpretación del **art. 21**, la interpretación que debe darse a la expresión demencia no es en su significado científico o técnico, sino que debe tomarse en un sentido más amplio, más diverso: en el sentido de enfermedad mental.

Los incapaces absolutos solo pueden actuar **representados** por su representante legal (el padre, la madre, el adoptante, el tutor o curador, **art. 43**), que ejecuta el acto en nombre y lugar del incapaz. Sus actos no producen ni siquiera obligaciones naturales, y no admiten caución (**art. 1447** incisos 1° y 2°). El Código sanciona esos actos con **nulidad absoluta** (**art. 1682**), aunque en estricto derecho serían jurídicamente **inexistentes**, por faltar la voluntad, condición de existencia de todo acto jurídico.

3.2. Incapacidad relativa

A diferencia de la absoluta, la incapacidad relativa sí permite ejecutar actos jurídicos en ciertas circunstancias y cumpliendo ciertas formas. Conforme al **art. 1447** inciso 3°, son relativamente incapaces:

a. Los menores adultos.

Comprende al varón mayor de 14 años y a la mujer mayor de 12 que no han cumplido los 18 (**art. 26**). Sus actos son válidos cuando se ejecutan con autorización de su representante legal, o cuando se refieren a su *peculio profesional o industrial*, ámbito en que gozan de amplias facultades (**art. 251**).

b. Los disipadores bajo interdicción de administrar lo suyo.

Pródigo o disipador es quien efectúa repetidos hechos de dilapidación demostrativos de una falta total de prudencia en el manejo de sus bienes: juego habitual con sumas considerables, gasto ruinoso, donaciones cuantiosas sin causa adecuada (**art. 445**). Solo es incapaz si es declarado en interdicción por decreto judicial; declarada esta, se le da un curador que administra sus bienes y actúa como su representante legal.

CORTE DE CONCEPCIÓN, 2008

La interdicción es el estado de una persona que ha sido declarada, por sentencia judicial, incapaz de ejercitar actos jurídicos, privándola de la administración de sus bienes, previo el juicio correspondiente. Esta institución está establecida en interés del propio interdicto, de su familia y de la sociedad, para aquellas personas que, por distintas circunstancias, no pueden actuar por sí mismas en los actos de la vida civil debido a su falta de capacidad intelectual, que los coloca en situación de inferioridad respecto de las demás personas, ya que no pueden proveer eficazmente a la administración de sus intereses.

NO CONFUNDIR**La mujer casada dejó de ser incapaz relativa en 1989**

En su versión original, el **art. 1447** incluía como incapaz relativa a la mujer casada en sociedad conyugal, no por ser mujer ni por estar casada, sino por el régimen de sociedad conyugal mismo, que se entendía exigía esa incapacidad para mantener su unidad. Esa causal fue derogada por la Ley N° 18.802, vigente desde el 8 de septiembre de 1989.

El incapaz relativo actúa **representado** (el representante ejecuta el acto en su nombre) o **autorizado** (el propio incapaz obra, con la anuencia de su representante, manifestada en la forma que prescribe la ley). Las formalidades que la ley exige según el estado o calidad de las personas se llaman *habilitantes*: si se observan, el acto es plenamente válido; si se omiten, es nulo de **nulidad relativa** (**art. 1682**). A diferencia de los incapaces absolutos, los actos de los incapaces relativos sí dan lugar a **obligaciones naturales** (**art. 1470 N° 1**). Se discute, y se profundiza en el curso de Obligaciones, si esta regla también alcanza a los actos de los disipadores interdictos.

3.3. Incapacidades particulares o especiales

Además de la absoluta y la relativa, hay incapacidades particulares que consisten en la prohibición legal impuesta a ciertas personas para ejecutar ciertos actos (**art. 1447** inciso final), por razones de moralidad, de orden público o de orden privado: el tutor o curador no puede comprar los bienes raíces del pupilo ni tomarlos en arriendo (**art. 412 inc. 2°**); los cónyuges no separados judicialmente no pueden celebrar compraventa entre sí, tampoco el padre o madre con el hijo de familia (**art. 1796**); se prohíbe al empleado público comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio; y se prohíbe a jueces, abogados, procuradores o notarios comprar los bienes en cuyo litigio intervinieron, aunque la venta se haga en pública subasta (**art. 1798**). A diferencia de la incapacidad absoluta y la relativa, que son generales (inhabilitan para la generalidad de los actos), estas incapacidades se reducen a ciertos actos según las circunstancias de las partes o del objeto. La palabra *prohibición* que usa el Código para referirse a ellas no está empleada en el senti-

do de ley prohibitiva, sino de impedimento para que una persona realice un acto que, generalmente, puede realizar cualquiera que tenga capacidad general.

La sanción varía según el caso: hay **nulidad absoluta** cuando la incapacidad particular se traduce en una prohibición absoluta de celebrar el acto (la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente); hay **nulidad relativa** cuando se traduce en el impedimento de ejecutarlo sin el ministerio o autorización de otro (los actos entre curador y pupilo sin la autorización exigida, **art. 412 inc. 1º**); y en otros casos la ley establece sanciones distintas de la nulidad, como la posibilidad de ser desheredado que afecta a quien se casa sin el consentimiento de un ascendiente estando obligado a obtenerlo (**art. 114**).

D. EL OBJETO

1. CONCEPTO

El **art. 1445** exige, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, que este recaiga sobre un objeto lícito, y el **art. 1460** agrega que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer (el mero uso o tenencia de la cosa también puede ser objeto de la declaración).

El concepto es controvertido: para quienes definen el acto jurídico como dirigido a crear, modificar o extinguir derechos subjetivos, el objeto son esos mismos *derechos y obligaciones*; para otros, es la *prestación*, la cosa que debe darse o el hecho que debe ejecutarse o no ejecutarse, identificando el objeto del contrato con el objeto de la obligación; la doctrina moderna lo entiende como la materia, utilidades o relaciones que caen bajo la voluntad de las partes. Atendido el tenor del **art. 1460**, en Chile se sigue generalmente la segunda postura: el objeto del acto jurídico es la **prestación**. Para determinar sus requisitos hay que distinguir según recaiga sobre una cosa o sobre un hecho.

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL OBJETO QUE RECAE SOBRE UNA COSA

El objeto que recae sobre una cosa, material o inmaterial, debe ser real, comerciable y determinado.

2.1. Cosa real

La cosa es real cuando existe actualmente o se espera que exista, pues no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino también las que se espera que existan (**art. 1461**). Si la cosa no existe al momento de celebrarse el acto, este carece de objeto: la venta de una cosa que se supone existente y no existe no produce efecto alguno (**art. 1814**), de modo que el acto es inexistente, o al menos nulo absolutamente, según la doctrina que se siga.

Si la cosa no existe pero se espera que exista, el acto vale, pero hay que distinguir. Cuando se vende la **cosa futura misma**, el contrato es condicional, sujeto a la condición de que la cosa llegue a existir: si un agricultor vende el trigo que coseche, y nada cosecha, la venta se reputa no efectuada por haber fallado la condición (salvo que las partes digan expresamente que el acto es puro y simple). Cuando en cambio se vende la **suerte** o la contingencia de que la cosa llegue a existir, el contrato es puro y simple (**art. 1813**) y aleatorio: la prestación de una parte depende de un hecho incierto que impide valuarla mientras no se realice.

EJEMPLO

Venta de la suerte: la red del pescador

Alguien se compromete a pagar a un pescador una suma fija por todos los peces que queden atrapados en su red. Solo al alzarla podrá valuarse la prestación del pescador: si los peces son numerosos, la suma pactada puede resultar inferior a lo que valen; si son escasos, puede ser muy superior a lo que habría correspondido pagar de haberse conocido antes el número exacto.

2.2. Cosa comerciable

Además de real, la cosa debe estar en el comercio, ser **comerciable** (**art. 1461**): susceptible de propiedad o posesión privada. La mayoría de las cosas lo son; por excepción no lo son las excluidas del comercio por su propia naturaleza, como las comunes a todos los hombres (el aire, la alta mar, **art. 585**), y las que por su destinación, mientras la conserven, no admiten dominio o posesión de particulares, como los bienes nacionales de uso público (calles, plazas, puentes, **art. 589**).

2.3. Cosa determinada

La cosa debe estar determinada, a lo menos, en cuanto a su género (**art. 1461** inciso 1º parte final). La determinación puede ser **en especie** (se individualiza un individuo determinado de un género también determinado, como el caballo *Royal*) o **en género** (se indica indeterminadamente un individuo de un género limitado, como *un caballo*): si el género fuera ilimitado (deber *un animal*, sin más), no habría una declaración seria de voluntad.

La determinación genérica debe ir acompañada de una fijación cuantitativa, aunque la cantidad puede ser incierta si el acto fija reglas o contiene datos que permitan determinarla, siempre que esos elementos consten en el mismo acto (**art. 1461** inciso 2º): por ejemplo, vender todo el trigo que produzca cierto fundo. Si en una obligación de género no se determina la calidad de lo que debe entregarse, el acreedor no puede exigir determinadamente ningún individuo, y el deudor queda libre entregando cualquiera del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana (**art. 1509**).

3. REQUISITOS DEL OBJETO QUE RECAE SOBRE UN HECHO

La prestación puede consistir en la ejecución de un hecho, positivo, o en su no ejecución, negativo. En ambos casos el hecho debe ser determinado, físicamente posible y moralmente posible.

3.1. Hecho determinado

Quien se obliga debe saber qué hecho ha de ejecutar o de qué debe abstenerse, y el acreedor debe saber qué puede exigir: de lo contrario no habría una declaración seria de voluntad.

3.2. Hecho físicamente posible

Es físicamente imposible el hecho contrario a la naturaleza (**art. 1461** inciso 3°), y para que exista esa imposibilidad debe ser **absoluta**: irrealizable por cualquier persona, no solo por el deudor. Si la imposibilidad es solo relativa (el deudor que se obligó a pintar un cuadro y no sabe pintar), la obligación es válida y su incumplimiento genera indemnización de perjuicios; si es absoluta, no hay obligación alguna, conforme al adagio *a lo imposible nadie está obligado*. La imposibilidad, además, es un concepto variable en el tiempo: lo imposible hoy puede ser posible mañana.

3.3. Hecho moralmente posible

Es moralmente imposible el hecho prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público (**art. 1461** parte final), lo que se coordina con el **art. 10**: los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo que la ley designe expresamente otro efecto para su contravención.

4. EL OBJETO ILÍCITO

Que el acto tenga objeto es un requisito de **existencia**; que ese objeto sea lícito es un requisito de **validez** (**art. 1445 N° 3**). Si el acto tiene objeto pero este es ilícito, el acto existe, pero nace con un vicio que lo hace susceptible de nulidad absoluta (**art. 1682**). Buena parte de la doctrina entiende por objeto ilícito el que versa sobre hechos, no cosas, prohibidos por las leyes o contrarios a las buenas costumbres o al orden público, aunque el Código no lo define, y los autores discrepan sobre su alcance exacto: para CLARO SOLAR es el conforme a la ley y amparado por ella; para SOMARRIVA, el conforme a la ley, las buenas costumbres y el orden público; para ALESSANDRI, el término *lícito* es sinónimo de comerciable; y para VELASCO LETELIER, el que cumple las cualidades del **art. 1461** (realidad, comerciabilidad, determinación, y posibilidad física y moral si se trata de un hecho), agregando que solo los **arts. 1445, 1468 y 1682** le dan a la expresión *objeto ilícito* su sentido real, mientras que en los **arts. 1462, 1464 y 1466** el legislador la usa impropriamente. El Código, en todo caso, no da una definición general: se limita a señalar los casos siguientes.

4.1. Actos que contravienen el derecho público chileno

Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno (**art. 1462**), esto es, el conjunto de normas que, mirando a un interés colectivo preponderante, regulan la organización y actividad del Estado y demás entes públicos, sus relaciones entre sí o con los particulares, actuan-

do estos con poder soberano. Conviene precisar que la norma no se refiere al *orden público*, sino al *derecho público*, conceptos y normas distintos entre sí; en este sentido, se ha resuelto que adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito el contrato que se funda en un acto administrativo que a su vez adolece de nulidad de derecho público. El Código pone como ejemplo la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por sus leyes, lo que en su momento hizo dudar de la validez de las cláusulas de sometimiento a tribunales extranjeros; hoy se utilizan con normalidad, atendido que el Código de Procedimiento Civil reconoce las jurisdicciones extranjeras, que el Código de Derecho Internacional Privado valida esas cláusulas (**art. 318**) y por el auge de los arbitrajes internacionales, regulados en Chile por la Ley N° 19.971 de 2004. Cuando la contravención al derecho público no proviene de un particular, sino de un órgano del Estado, la sanción aplicable no es esta nulidad civil, sino la **nulidad de derecho público** consagrada en el **art. 7 de la Constitución**.

4.2. Pactos sobre sucesiones futuras

El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de donación ni contrato, aunque intervenga el consentimiento de esa misma persona (**art. 1463**). Son, en cambio, perfectamente válidos los actos sobre el derecho a suceder a una persona ya muerta, al punto de que el Código regula expresamente la cesión de derechos hereditarios (**arts. 1909 y siguientes**).

La prohibición comprende actos unilaterales y bilaterales, pese a que la norma solo menciona los contratos: como las asignaciones hereditarias no pueden aceptarse ni repudiarse antes de la muerte del causante (**arts. 956 y 1226**), aceptar en vida del testador una asignación dejada en su testamento sería nula por objeto ilícito. Y aunque el Código habla de *donación o contrato*, siendo la donación en sí misma un contrato (**art. 1386**), lo que quiso decir es que el derecho a suceder a una persona viva no puede ser objeto de convención alguna, gratuita u onerosa.

La excepción está en el **art. 1204**, el llamado **pacto de no disponer de la cuarta de mejoras**: una persona viva puede prometer a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes no donar ni asignar por testamento parte alguna de esa cuarta. El mismo artículo declara nulas cualesquiera otras estipulaciones sobre sucesión futura entre un legitimario y quien le debe la legítima, aunque parte de la doctrina admite como válidas las donaciones irrevocables hechas en razón de legítimas y mejoras del **art. 1185** (el llamado primer acervo imaginario).

4.3. Enajenación de las cosas enumeradas en el art. 1464

Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, de las cosas embargadas por decreto judicial (salvo autorización del juez o consentimiento del acreedor), y de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio (**art. 1464**).

La palabra **enajenación** puede tomarse en sentido estricto (transferencia del dominio) o amplio (transferencia del dominio o constitución de cualquier otro derecho real, como hipoteca o usufruc-

to); la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia se inclinan por el sentido amplio. La *adjudicación*, en cambio, no constituye enajenación y por eso no le es aplicable el **art. 1464**.

NO CONFUNDIR

¿Se puede vender lo que no se puede enajenar?

Como en Chile rige la dualidad título y modo, la compraventa por sí sola no transfiere el dominio, así que en principio vender una cosa del **art. 1464** sería válido, porque la compraventa no es enajenación. Pero el **art. 1810** permite vender solo las cosas cuya enajenación no esté prohibida por la ley, extendiendo la prohibición del **art. 1464** también a la compraventa. La doctrina distingue: hay una verdadera *ley prohibitiva* (que no admite excepción alguna) en los números 1 y 2 del **art. 1464** (cosas inenajenables y derechos personalísimos), de modo que también su venta adolece de objeto ilícito; pero no la hay en los números 3 y 4 (cosas embargadas o litigiosas), porque el juez puede autorizar su enajenación o el acreedor consentirla, de modo que su venta, a diferencia de su enajenación, sería válida. Los partidarios de esta tesis agregan que no se divisa razón para prohibir la venta de las cosas embargadas o litigiosas, porque el impedimento para transferirlas puede cesar una vez alzada la prohibición: las partes podrían querer celebrar el contrato desde ya, a sabiendas de que la tradición solo podrá efectuarse una vez que desaparezca ese impedimento.

(i) Cosas que están fuera del comercio

Son las no susceptibles de propiedad o posesión privada, por naturaleza (el aire, la alta mar) o por destino (calles, plazas, el mar territorial y sus playas). Aquí surge una tensión con el **art. 1461**: si la comerciabilidad es un requisito del objeto, la falta de ella debería significar que el acto carece de objeto (inexistencia); pero el **art. 1464 N° 1** trata la enajenación de cosas inenajenables como un caso de objeto *ilícito*, sancionado con nulidad absoluta según el **art. 1682**. Buena parte de la doctrina de la inexistencia ve aquí un error del Código; otros distinguen entre la inenajenabilidad por naturaleza (que daría inexistencia) y la temporal, impuesta por el legislador para ciertos casos (como los peces en veda), que solo acarrearía nulidad absoluta. El texto expreso de la ley hace difícil sostener la primera tesis.

(ii) Derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona

Son los derechos **personalísimos**, como los reales de uso y habitación (**art. 819**) o el derecho a pedir alimentos (**art. 334**). No es una norma redundante respecto del número 1: estos derechos sí están dentro del comercio humano (son susceptibles de dominio o posesión), pero tienen la particularidad de ser inalienables.

(iii) Cosas embargadas por decreto judicial

El **embargo**, institución propia del juicio ejecutivo, es la aprehensión compulsiva de bienes del deudor por mandamiento judicial, entregados a un depositario, para asegurar el pago de la deuda; pero la doctrina lo entiende aquí en un sentido amplio, que comprende también las medidas precautorias de prohibición de enajenar y gravar, secuestro, retención, y la prohibición judicial de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados (**art. 296 C.P.C.**).

Respecto de las **partes** del juicio, el embargo produce efectos desde que se notifica judicialmente la resolución que lo ordena. Respecto de **terceros**, si recae sobre bienes muebles solo los afecta desde que toman conocimiento de él; si recae sobre inmuebles, solo desde que se inscribe en el conservador respectivo (**art. 453 C.P.C.**). Debe existir al momento mismo de la enajenación para que esta adolezca de objeto ilícito, y no hay objeto ilícito en la enajenación **forzada** de una cosa embargada que se realiza en otro juicio distinto de aquel en que se decretó el embargo (**art. 528 C.P.C.**): puede haber dos o más ejecuciones, y la enajenación que se haga en cualquiera de ellas es válida. El acreedor que embargó primero el mismo bien no sufre perjuicio: la ley le permite hacer valer sus derechos conforme a ese mismo art. 528 y, en general, mediante el procedimiento de las **tercerías**.

La violación de una **prohibición voluntaria** de no enajenar (pactada entre las partes) no constituye objeto ilícito, porque el **art. 1464 N° 3** exige que la medida se imponga por decreto judicial: su infracción se sanciona por las reglas de la responsabilidad contractual, no con nulidad. Las **prohibiciones legales** de enajenar, en cambio, sí producen nulidad por objeto ilícito si se contravienen: así, las leyes orgánicas de algunas instituciones (por ejemplo, el SERVIU) prohíben enajenar los bienes raíces sobre los que tengan operaciones pendientes mientras no se liquiden, prohibición que no puede violarse sin incurrir en nulidad por ilicitud del objeto.

Una cosa embargada puede enajenarse válidamente con **autorización del juez** que decretó la medida (dada con conocimiento de causa, y de todos los jueces si hubo más de un embargo) o con el **consentimiento del acreedor** en cuyo beneficio se decretó, que puede ser expreso o tácito y debe ser siempre previo a la enajenación, porque la nulidad absoluta que sanciona el objeto ilícito no admite ratificación posterior.

(iv) Especies cuya propiedad se litiga

Son los muebles o inmuebles sobre cuyo dominio discuten demandante y demandado en un juicio, lo que no debe confundirse con la *cesión de un derecho litigioso* (el evento incierto de la litis), plenamente válida y regulada en los **arts. 1911 y siguientes**. Para que operen los efectos del **art. 1464 N° 4** el tribunal debe decretar expresamente la prohibición de enajenar sobre la especie litigiosa, y pueden enajenarse válidamente con el permiso del juez que conoce el litigio, en términos similares a los de las cosas embargadas. Cuando la prohibición recae sobre un bien mueble, solo produce efecto respecto de los terceros que tuvieron conocimiento de ella al tiempo del contrato, pero el demandado es en todo caso responsable de fraude si enajena la especie litigiosa a sabiendas, estando vigente la prohibición. Parte de la doctrina, además, considera redundante este N°

4: dado el alcance amplio que la jurisprudencia le ha dado a la expresión *cosas embargadas* del N° 3 (que comprende también los bienes sobre los que pesa una prohibición judicial de enajenar), las especies litigiosas ya quedarían comprendidas ahí.

4.4. Condonación del dolo futuro

El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si este no se ha condonado expresamente; y la condonación del dolo futuro, en general, no vale (**art. 1465**). La primera regla exige que el perdón del dolo cometido por quien rinde cuentas sea expreso y explícito en el finiquito; la segunda, de alcance más general, se funda en que sería ilícito aceptar de antemano que una parte obre con dolo, y por eso en Chile no valen las cláusulas de irresponsabilidad que liberan a una parte de sus incumplimientos, en cuanto importan condonar un dolo futuro (extensible a la culpa grave, que el **art. 44** asimila al dolo). El objeto ilícito de la primera hipótesis no queda reducido a la sola rendición de cuentas: se extiende a todo finiquito contractual que adolezca del mismo vicio. Y, precisamente porque el pacto o la aprobación adolecen de objeto ilícito, quien aprobó la cuenta o suscribió el finiquito habiendo dolo no queda por ello impedido de reclamar después a su contraparte lo que esta le deba o los perjuicios que le haya causado: frente a su demanda, se excluye la excepción de cuenta aprobada o finiquito suscrito, porque uno y otro son inválidos en la parte que encubre el dolo no condonado expresamente.

4.5. Deudas contraídas en juego de azar

Hay objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar (**art. 1466**). Son **lícitos** los juegos en que predomina la fuerza o destreza corporal (como las carreras de caballos, si no contravienen la ley o los reglamentos de policía) y los de destreza intelectual (como el ajedrez): los primeros generan obligaciones civiles perfectas, exigibles judicialmente; los segundos no dan acción para exigir el pago, pero tampoco permiten repetir lo pagado, salvo que se haya ganado por dolo. Son **ilícitos** los juegos de azar propiamente tales, cuyo resultado depende única y principalmente de la suerte, salvo las excepciones que la propia ley autoriza, como la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción o los casinos de juego regulados por la Ley N° 19.995.

4.6. Venta de libros prohibidos, objetos inmorales e impresos abusivos de la libertad de prensa

Hay objeto ilícito en la venta de libros cuya circulación prohíbe la autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa (**art. 1466**, segunda parte). Esta última hipótesis se relaciona con las garantías constitucionales de *el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia* (**art. 19 N° 4 CPR**) y de *la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades* (**art. 19 N° 12 CPR**), desarrolladas en la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo (Ley de Prensa). De su infrac-

ción pueden derivar tres responsabilidades no excluyentes entre sí: **penal**, si la opinión configura un delito como injuria o calumnia; **civil**, por los daños causados al ofendido (que en injuria y calumnia comprende daño emergente, lucro cesante y daño moral, **art. 40 Ley de Prensa**); y una responsabilidad contravencional, el deber del medio de comunicación de difundir gratuitamente la aclaración o rectificación del ofendido.

4.7. Actos prohibidos por la ley

El **art. 1466** cierra con una regla general: hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes, coincidente con el **art. 1461**, que declara moralmente imposible el objeto prohibido por ellas. Concordada con el **art. 10**, la regla general es que todo acto prohibido por la ley es nulo, salvo que la propia ley establezca una sanción distinta, como ocurre con los usufructos sucesivos o alternativos, que el **art. 769** prohíbe sin declararlos nulos, entendiendo en su lugar que se constituyen usufructuarios sustitutos.

E. LA CAUSA

1. GENERALIDADES

Todo acto consciente de los seres racionales se ejecuta en procura de un fin, cuya consideración anticipada es causa del obrar. La pregunta de si ese fin debe erigirse en un requisito de eficacia y validez del acto jurídico es el primer problema que plantea la causa. Para los **causalistas**, el acto jurídico requiere, además de voluntad y objeto, una causa, que además debe ser lícita para que el acto sea válido. Para los **anticausalistas**, basta la voluntad y el objeto: la causa sería un requisito artificial y prescindible.

Una dificultad adicional es que *causa* admite varias acepciones. La **causa eficiente** es el antecedente que da vida a lo que antes no existía (las fuentes de las obligaciones: la causa eficiente de la obligación del vendedor es el propio contrato de compraventa). La **causa final** es el fin directo e inmediato que la parte se propone alcanzar, típico y constante en los actos de una misma especie, con independencia de los móviles individuales (en toda compraventa, la causa del comprador es incorporar la cosa a su patrimonio, y la del vendedor, procurarse dinero). La **causa ocasional** son los motivos individuales que llevaron a realizar el acto (el vendedor necesitaba dinero para pagar una deuda; el comprador quería hacer un regalo de matrimonio).

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NOCIÓN DE CAUSA

El Derecho Romano no formuló una teoría general de la causa, aunque exigió que todo enriquecimiento tuviera una justa causa, dando al empobrecido una acción de repetición (*condictio sine causa*). La teoría propiamente dicha nace en el **Derecho Canónico medieval**, que facultaba al juez para indagar los móviles de las partes aunque la convención pareciera formalmente exenta de vicios, cautelando que la voluntad no persiguiera un fin reprobable.

Quien le dio verdadero desarrollo fue el jurista francés **DOMAT** (1625-1697), autor de la teoría clásica, centrada en la causa de la *obligación* y no en los móviles del acto. **POTHIER** (1699-1772), padre espiritual del Código Civil francés, la perfeccionó en su *Tratado de las Obligaciones* (1761); sus ideas pasaron, con variaciones, al Código francés (que no definió la causa) y a los códigos que en él se inspiraron, entre ellos el chileno, que sí la definió.

3. DOCTRINAS ELABORADAS EN RELACIÓN CON LA CAUSA

Existen dos corrientes antagónicas. Los **causalistas** (CAPITANT, JOSSERAND y RIPERT en Francia; FERRARA, SANTORO PASSARELLI y BETTI en Italia) se dividen entre quienes siguen un criterio objetivo (la doctrina clásica y los italianos modernos) y quienes elaboran un criterio subjetivo (la teoría del móvil o motivo determinante). Los **anticausalistas** (PLANIO, GIORGI, LAURENT, DABIN) rechazan la causa por falsa e inútil: para PLANIO se confunde con el

objeto, para DABIN queda absorbida por el consentimiento. Con todo, la mayoría de los códigos actuales (el francés, el italiano, el español, entre otros) exigen expresamente una causa, expresión del principio de causalidad común a toda disciplina: ningún acto jurídico resulta del puro azar.

DATO DE GRADO

La causa está desapareciendo del derecho comparado

En el derecho comparado actual hay países que se han decantado por eliminar la exigencia de causa, como el Código Civil de Quebec y los códigos escandinavos. El caso más reciente es el francés: el 10 de enero de 2016 se aprobó una reforma al derecho de los contratos que eliminó las normas que exigían expresamente la causa. MAZEAUD sostiene que es incorrecto afirmar que la causa ha sido eliminada de forma absoluta: puede decirse que lo fue en términos generales, pero subsiste en ciertos casos.

3.1. Doctrina tradicional o clásica

Elaborada por DOMAT, se centra en la **causa de la obligación** que emana del contrato, preguntándose por qué el contratante la asumió, con un criterio **objetivo**. Distingue tres tipos de contratos. En los **bilaterales**, la causa de la obligación de una parte es la obligación correlativa de la otra (en la compraventa, la causa de la obligación del vendedor de entregar la cosa está en la obligación del comprador de pagar el precio, y viceversa). En los **reales**, que se perfeccionan con la entrega de la cosa, la causa de la obligación de restituir está en esa entrega previa. En los **gratuitos**, DOMAT sitúa la causa en el motivo racional y justo de la obligación (un servicio prestado, el placer de hacer el bien); POTHIER la identifica, después, con la *intención liberal*, el propósito de hacer una liberalidad.

3.2. Doctrina italiana

Coincide con la clásica en el criterio objetivo, pero centra su estudio en la **causa del acto o contrato**, no de la obligación: la causa es el *fin o función económico-social* perseguido por el contrato. La causa de los negocios onerosos es su función de producir un cambio de prestación y contraprestación; la de la compraventa, cambiar cosa por precio; la de la donación, producir un enriquecimiento del donatario.

3.3. Doctrina del móvil o motivo determinante

Llamada también de causa ocasional o impulsiva, estructura un concepto **subjetivo** de la causa del acto: el móvil o motivo determinante que impulsó a su autor o partes a celebrarlo. Por su propia naturaleza, no admite un concepto abstracto, sino que varía caso a caso.

3.4. Doctrina anticausalista

PLANIOL tilda a la doctrina clásica de *falsa e inútil a la vez*. Respecto de los contratos bilaterales, sería falsa porque las obligaciones recíprocas nacen al mismo tiempo, y mal puede una ser causa de la otra si la causa debe preceder a su efecto; e inútil, porque equivale a decir que la causa de una obligación es el objeto de la otra. Respecto de los reales, sería falsa porque la entrega de la cosa no es causa de la obligación sino requisito de perfeccionamiento del contrato; e inútil, porque sin la entrega simplemente no hay contrato ni obligación que buscarle causa. Respecto de los gratuitos, sería falsa porque confunde la causa con los motivos; e inútil, porque la falta de intención liberal equivaldría, derechamente, a la falta de consentimiento. A esto agrega que tampoco sería necesario exigir que la causa sea lícita, porque el cuestionamiento a la moralidad del acto ya está cubierto por el objeto: no puede celebrarse un acto jurídico con objeto ilícito.

4. LA TEORÍA DE LA CAUSA EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

El **art. 1445** exige, para que una persona se obligue a otra por acto o declaración de voluntad, que este tenga una causa lícita. El **art. 1467** agrega que no puede haber obligación sin una causa real y lícita, y la define, en su inciso segundo, como *el motivo que induce al acto o contrato*. Esta regulación plantea varios problemas de interpretación.

4.1. ¿Qué es lo que debe tener causa: el acto o la obligación?

Para algunos, al Código le interesa la causa de la **obligación**: el **art. 1467** habla de que no puede haber *obligación* sin causa, el **art. 1445** exige causa para que una persona *se obligue*, y el Código se dictó en pleno auge de la doctrina clásica, centrada en la obligación. Para otros, le interesa la causa del **acto o contrato**: el propio **art. 1445** exige causa para obligarse *por un acto o declaración de voluntad*, y la definición del **art. 1467** habla del motivo que induce *al acto o contrato*; a esto se agrega que el **art. 2057**, sobre sociedades nulas por ilicitud del objeto o la causa, confirma que es el contrato, no la obligación, el que tiene causa ilícita.

4.2. ¿Criterio objetivo o subjetivo?

A favor del criterio **objetivo** se argumenta que es el de la doctrina clásica, en la que se habría inspirado BELLO; que el **art. 1467** exige una causa *real*, lo que supone que puede no haberla, algo que el criterio subjetivo no admitiría; y que el *motivo* de la definición legal sería de orden jurídico o abstracto, no subjetivo. A favor del criterio **subjetivo**, que a diferencia del Código francés (que siguió la doctrina clásica sin definir la causa) el chileno la definió precisamente como el motivo que induce al acto, y que exigir una causa *real* faculta al juez para indagar el motivo que efectivamente determinó la celebración del acto, no uno abstracto.

4.3. Doctrina dual de la causa

Para LEÓN HURTADO y VIAL DEL RÍO, hace falta distinguir, porque el propio Código lo hace al menos implícitamente, entre la **causa del acto o contrato** (el motivo, en su sentido natural y obvio: los móviles psicológicos, individuales y subjetivos, que induce a su celebración) y la **causa de la obligación** (donde el legislador sigue la doctrina tradicional: abstracta e idéntica para cada categoría de contratos).

4.4. Doctrina unitaria de la causa

ALCALDE, apoyado en la doctrina italiana moderna, sostiene que la distinción entre causa del contrato y causa de la obligación carece de importancia práctica. Argumenta que las doctrinas tradicionales tienen un concepto de causa parcial, referido solo al contrato o a la obligación, que ignora otras instituciones que también se explican por la causa; que lo común a todas las situaciones en que se plantea el problema de la causa es la existencia de una *razón o justificación* de una atribución patrimonial, coincidente con el interés jurídicamente protegido en el caso concreto, lo que permite definir la causa como **aquel supuesto de hecho legalmente suficiente para justificar un determinado efecto jurídico**, distinto de la voluntad y el objeto (que son presupuestos del acto, pero no dicen relación con su justificación jurídica).

De ahí concluye que la ilicitud de la causa no se relaciona con los móviles personales de las partes, sino con una desviación del interés protegido por la norma, y que el concepto se proyecta más allá del contrato y su obligación, a materias como el pago, la adquisición de derechos sobre cosa propia, la condición suspensiva meramente potestativa o el fraude a la ley. De igual modo, precisa que ciertas instituciones tradicionalmente explicadas en función de la causa, como la *condición resolutoria tácita* y la *excepción de contrato no cumplido*, en realidad no se relacionan con este elemento del acto jurídico.

5. CAUSA REAL

La causa debe ser real: el **art. 1467** no exige que el autor o las partes la expresen. De ahí que se entienda que la ley **presume** que todo acto tiene una causa (los motivos que normalmente inducen a celebrar ese tipo de acto), de modo que la prueba de su ausencia corresponde a quien la alega. Son difíciles de encontrar, pero hay dos casos: la **simulación**, donde no hay un motivo real para el acto simulado (el único motivo es engañar a terceros, no hay ninguno para el contrato aparente); y la promesa de dar algo en pago de una **deuda que no existe**, ejemplo que da el propio **art. 1467** de una causa falsa, equivalente a la falta de causa real. Otro caso de causa falsa o errónea es el del heredero que paga un legado sin saber que el testamento en que se basaba fue revocado por uno posterior: no existía obligación de entregar el legado, porque este ya no existía. Si falta la causa, el acto es inexistente para quienes admiten esa sanción, o solo nulo absolutamente para quienes entienden que el Código no la reconoce.

6. LICITUD DE LA CAUSA

Además de real, la causa debe ser **lícita** (**art. 1467** inciso 1°): es ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público, como la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral (**art. 1467** incisos 2° y 3°). La causa ilícita produce **nulidad absoluta** (**art. 1682**), y quien a sabiendas dio o pagó por una causa ilícita no puede pedir la devolución de lo dado o pagado (**art. 1468**). El fraude a la ley, una particular clase de causa ilícita, se estudia en el capítulo de la ineficacia de los actos jurídicos.

7. ACTOS CAUSALES Y ACTOS ABSTRACTOS

7.1. Conceptos

Los actos **causales** son aquellos en cuyo perfeccionamiento debe concurrir la causa como elemento esencial: si falta o es ilícita, el acto adolece de nulidad absoluta (la compraventa, el arrendamiento, el mutuo, el comodato). Los **abstractos** son aquellos en cuyo perfeccionamiento la causa no aparece como elemento constitutivo, funcionando desvinculados de ella, de modo que si falta o es ilícita, el acto igual vale y produce sus efectos. La distinción no supone que existan actos sin causa (sería absurdo concebir un acto sin fin alguno): en los abstractos la causa simplemente no se toma en cuenta para su constitución, aunque exista.

7.2. La relación fundamental y subyacente del acto abstracto

Todo acto abstracto presupone una obligación o relación jurídica que tiende a satisfacer o reforzar, llamada **fundamental** (porque sustenta toda la situación) o **subyacente** (porque queda cubierta por el acto abstracto): la finalidad de una letra de cambio puede ser pagar el precio de una compraventa, siendo esa obligación de pagar el precio su relación subyacente. La falta o ilicitud de esa causa solo puede alegarse entre las partes de la relación subyacente y frente a terceros de mala fe, nunca frente a terceros de buena fe, para no vulnerar la seguridad jurídica que el acto abstracto busca resguardar (**art. 28 Ley N° 18.092**, sobre letras de cambio y pagarés).

7.3. Razón de ser de los actos abstractos

Existen por razones prácticas: dan seguridad a la adquisición de derechos y hacen expedita su circulación, evitando que el deudor invoque la falta o ilicitud de la causa para entorpecerla. El juez requerido para su cumplimiento solo debe considerar si el deudor se comprometió a pagar, sin indagar la causa. Al funcionar con la causa en blanco, además, facilitan los negocios: una misma letra de cambio puede servir para pagar una deuda, garantizarla, donar o prestar dinero.

7.4. Solo la ley puede establecer actos abstractos

A diferencia de otros derechos, donde se discute si los particulares pueden crear actos abstractos en virtud de la autonomía de la voluntad, en Chile solo el **legislador** puede hacerlo: la causa es requisito esencial del acto jurídico (**art. 1445** inciso 1°), de orden público, cuya omisión se sanciona con la inexistencia o, al menos, la nulidad absoluta (**art. 1682**). La desvinculación de la causa respecto del acto está, por eso, sustraída a la autonomía de la voluntad particular.

7.5. Actos abstractos en la legislación chilena

Se mencionan como actos abstractos, entre otros, la delegación, la estipulación a favor de tercero, la fianza y demás contratos de garantía por deuda ajena, y ciertos títulos de crédito como la letra de cambio.

8. RELACIÓN DE LA CAUSA CON EL ERROR Y CON LA FUERZA O EL DOLO

Existe cierta vinculación entre la causa y algunas hipótesis de error relevante: la razón por la que la víctima del error contrató es, precisamente, su creencia equivocada sobre la sustancia o cualidad de la cosa, o sobre la persona con quien contrataba. Distinto de ese **error-motivo** es el **error sobre los motivos** propiamente tal, esto es, la representación inexacta de las razones o móviles que inducen a contratar, que por regla general es irrelevante, salvo en los actos gratuitos o de beneficencia. VIAL DEL RÍO precisa que, en la mayoría de esos actos gratuitos que la doctrina permite impugnar, no hay realmente error sobre los motivos, sino sobre la persona: el motivo que induce al acto (gratitud, reconocimiento, admiración) existe de verdad, pero quien recibe la liberalidad no tiene las cualidades que su autor creía ver en él.

Cuando la fuerza o el dolo constituyen el motivo principal o determinante del acto, son también su causa, y como esa causa no se conforma con el derecho, resulta ilícita. Se plantea entonces por qué normas puede la víctima impugnar el acto, pregunta relevante porque la sanción de los vicios del consentimiento es la nulidad relativa, mientras que la de la causa ilícita es la nulidad absoluta. VIAL DEL RÍO estima que priman las normas sobre vicios del consentimiento, por ser especiales frente a las reglas generales de la causa.

F. LAS FORMALIDADES

1. CONCEPTO

Formalidades son ciertos requisitos que dicen relación con la forma o aspecto externo que deben revestir determinados actos jurídicos, exigidos por la ley para su existencia, su validez, su prueba u otro efecto determinado.

2. CLASES DE FORMALIDADES

Según el fin para el que se exigen, se distinguen cuatro especies, cuya inobservancia trae sanciones distintas: las **solemnidades**, las **formalidades habilitantes**, las **formalidades de prueba** y las **medidas de publicidad**. Pueden consistir en instrumentos públicos o privados, la presencia de funcionarios públicos o testigos, o medidas de publicidad como avisos en diarios o inscripciones en registros públicos.

2.1. Las solemnidades (formalidades propiamente tales)

(i) Solemnidades requeridas para la existencia del acto

Son los requisitos externos que la ley exige para la celebración de ciertos actos, convirtiéndose en el único medio a través del cual su autor o partes pueden manifestar su voluntad: constituyen, para la doctrina que las distingue, un requisito esencial de existencia, aunque algunos observan que no son independientes de la voluntad, sino simplemente la forma en que esta debe manifestarse en esos actos.

En el derecho primitivo casi todos los actos eran solemnes; hoy domina el **consensualismo**, aspecto de la autonomía de la voluntad según el cual, por regla general, basta la manifestación de voluntad de las partes, cualquiera sea su forma, para que el acto se constituya. En nuestro derecho los actos consensuales son la regla y los solemnes la excepción, reservada a actos de gran trascendencia para que las partes pongan especial atención en lo que realizan.

Es la ley la que da a un acto el carácter de solemne, pero las partes pueden hacer solemne uno que por ley no lo es, como cuando se pacta que una compraventa de cosas muebles se hará por escrito: en tal caso, cualquiera de las partes puede retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa, momento en el cual la formalidad creada por ellas queda suprimida (**art. 1802**). Un acto solemne por mandato de la ley no es igual a uno que lo es por voluntad de las partes: si en el primero faltan las solemnidades, el acto es inexistente o nulo absolutamente; en el segundo, puede producir efectos aun sin ellas si se ejecutan hechos que importen renunciarlas.

Las solemnidades legales son de **derecho estricto**, por constituir una excepción al derecho común, y por eso se interpretan restrictivamente: no hay más solemnidades ni actos necesariamente solem-

nes que los que la ley establece expresamente. Son ejemplos la escritura pública en la compraventa de bienes raíces, sin la cual el contrato no se reputa perfecto (**art. 1801** inciso 2°), o la exigencia de constar por escrito del contrato de promesa (**art. 1554 N° 1**).

DATO DE GRADO

¿Inexistencia o nulidad absoluta por falta de solemnidad?

Para quienes admiten la inexistencia, faltando la solemnidad de existencia no hay voluntad, porque esa solemnidad es precisamente el medio que la ley establece para manifestarla: se apoyan en el **art. 1701**, que dispone que la falta de instrumento público, cuando la ley lo exige como solemnidad, no puede suplirse por otra prueba, y que el acto se mirará *como no ejecutado o celebrado*. Para otro sector, la sanción es la **nulidad absoluta**: además de que el Código no reconocería la inexistencia, el **art. 1682** sanciona expresamente con esa nulidad la omisión de un requisito o solemnidad que la ley prescribe en consideración a la naturaleza del acto, y no a la calidad de las personas.

(ii) Solemnidades requeridas para la validez del acto

En otros casos la ley exige la solemnidad no como requisito de existencia, sino de **validez**: así ocurre con el número de testigos que exige el testamento solemne, cuya omisión no impide que el testamento exista, pero lo hace anulable, o con la insinuación de las donaciones. La sanción por su omisión es, sin discusión, la **nulidad absoluta**, porque su ausencia no impide que el acto exista, solo lo hace inválido.

2.2. Formalidades habilitantes

Son los requisitos que la ley, velando por los intereses de los incapaces, exige para la validez o eficacia de ciertos actos que los afectan, integrando su voluntad o el poder de sus representantes legales y removiendo así la incapacidad o la falta de poder. Se distinguen tres especies.

(i) La autorización.

Es el permiso que debe dar el representante legal de un incapaz, o la autoridad judicial, para que este celebre un acto, o el que debe dar una persona capaz a quien administra sus intereses. Los menores adultos, por ejemplo, deben actuar con autorización de quien ejerce la patria potestad, o de su guardador si están sometidos a guarda (**arts. 253, 254 y 439**). A veces la necesita el propio representante legal: el padre no puede enajenar ni hipotecar los bienes raíces del hijo sin autorización judicial dada con conocimiento de causa (**art. 255**).

(ii) La asistencia.

Es la concurrencia del representante legal al acto que celebra el incapaz, o de una persona capaz al acto que celebra quien administra sus intereses, colocándose jurídicamente al lado de quien actúa. Solo se diferencia de la autorización en que esta es un asentimiento previo, y la asistencia uno coetáneo al acto mismo (**art. 1749 inc. 7º**).

(iii) La homologación.

Es la aprobación por la autoridad judicial de actos ya concluidos por otros sujetos, previo control de su legitimidad: solo después de ese control y de la aprobación el acto adquiere eficacia. Un ejemplo es la partición en que tienen interés personas ausentes sin apoderado, o bajo tutela o curaduría, que debe someterse a aprobación judicial una vez terminada (**art. 1342**): mientras el laudo del partidor no es confirmado por resolución ejecutoriada, la partición no adquiere firmeza ni eficacia.

La omisión de una formalidad habilitante acarrea **nulidad relativa**, por tratarse de una formalidad exigida en consideración al estado o calidad de las personas que celebran el acto (**art. 1682**).

2.3. Las formalidades de prueba

Son las formas que sirven para probar la realización de un acto jurídico y su contenido: la forma *ad probationem*, que no cumple una función de existencia ni de validez, sino de prueba. Su omisión priva al acto de un determinado medio probatorio, pero no lo afecta en su existencia ni en su validez. Así, los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa de valor superior a dos unidades tributarias deben constar por escrito, y si no lo hacen, no pueden probarse por testigos (**art. 1709**), salvo las excepciones que la propia ley contempla (**art. 1711**).

2.4. Las medidas de publicidad

Tienen por objeto proteger a los terceros que pueden verse alcanzados por los efectos de un acto jurídico, y se clasifican en de simple noticia y sustanciales.

Las de **simple noticia** buscan llevar a conocimiento de los terceros en general las relaciones jurídicas que puedan interesarles, como la notificación por avisos de los decretos de interdicción del demente o del disipador (**arts. 447 y 461**). Su omisión solo genera **responsabilidad** (de naturaleza cuasidelictual, **art. 2314**) de quien debió cumplir el trámite y no lo hizo, quien debe indemnizar a quien sufrió un perjuicio por su infracción.

Las **sustanciales**, en cambio, buscan precaver a los *terceros interesados*, aquellos que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, de los actos que estas celebren, como la notificación al deudor de la cesión de un crédito. Su omisión tiene una sanción más severa: la **inoponibilidad**, es decir, la ineficacia del acto respecto de esos terceros.

G. LOS EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

1. GENERALIDADES

Los efectos de los actos jurídicos son los derechos y obligaciones que de él emanan: la forma en que la ley traduce en términos jurídicos el fin práctico que el autor o las partes persiguieron al celebrarlo. A partir del **art. 1444** es posible distinguir tres clases.

Son **esenciales** los que determina la ley como consecuencia obligada de la celebración del acto, de modo que las partes no pueden descartarlos ni sustraerse a ellos: en la compraventa, la obligación del vendedor de entregar la cosa y la del comprador de pagar el precio. Son **naturales** los que, estando establecidos por la ley, las partes pueden eliminar mediante una cláusula especial: la obligación del vendedor de sanear la evicción y los vicios redhibitorios. Son **accidentales** los que las partes, en virtud de la autonomía privada, pueden incorporar al acto sin que el legislador los prevea ni los prohíba: el pacto comisorio en la compraventa.

2. PERSONAS RESPECTO DE LAS CUALES SE PRODUCEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Por regla general, los actos jurídicos producen efectos entre las partes que los celebraron, sin afectar a terceros: es el **principio de la relatividad** o efectos relativos, que admite ciertas excepciones.

2.1. Concepto de parte

Son las personas que, personalmente o representadas, concurren a la formación del acto, constituyendo cada una un centro de intereses (que puede estar compuesto por varias personas). Respecto de ellas el acto produce todos sus efectos: *todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales* (**art. 1545**). Quien genera con su voluntad un acto unilateral se llama *autor*; quienes lo hacen en un acto bilateral, *partes*, aunque ambas expresiones suelen usarse indistintamente. Lo decisivo para calificar a alguien como parte es que haya concurrido con su voluntad a generar el acto, no la mera concurrencia a su celebración u otorgamiento: los testigos y el notario, por ejemplo, no son partes.

2.2. Concepto de tercero

Es un concepto negativo, definido por antítesis al de parte: en general, tercero es toda persona que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la generación del acto. Entre ellos se distingue a los **terceros absolutos**, extraños a la formación del acto y que no están ni estarán en relaciones jurídicas con las partes (respecto de quienes el acto no produce efectos, en el reverso exacto del **art. 1545**), y a los **terceros relativos**, que sí están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, sea por su propia voluntad o por disposición de la ley.

Los principales terceros relativos son: los **herederos, sucesores o causahabientes a título universal** (a quienes se transmiten todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante, o una cuota de ellos, únicamente por causa de muerte, **arts. 951 y 1097**), que representan al causante y continúan su personalidad, por lo que parte de la doctrina no los considera propiamente terceros, sino partes; y los **sucesores o causahabientes a título singular** (a quienes se transfieren derechos determinados, por causa de muerte como los legatarios, **arts. 951 y 1104**, o entre vivos mediante la tradición, **art. 671**), a quienes pueden afectar los efectos de actos relacionados con el bien o derecho transferido, como una hipoteca constituida antes de la transferencia.

También son terceros relativos los **acreedores de las partes**, que aunque son claramente terceros pueden verse afectados por los actos de su deudor, por ejemplo cuando este enajena uno de los pocos bienes de su patrimonio en perjuicio de su derecho de prenda general, razón por la cual la ley les otorga *derechos auxiliares* destinados a conservar o incrementar ese patrimonio, como las medidas cautelares, la acción pauliana, la acción subrogatoria o el beneficio de separación.

3. EL EFECTO RELATIVO DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y SUS EXCEPCIONES

3.1. Generalidades

Los actos jurídicos, por regla general, solo producen efectos entre las partes, sin aprovechar ni perjudicar a los terceros que no contribuyeron a generarlos: el efecto relativo es una expresión de la autonomía de la voluntad, pues solo se obliga quien manifiesta su voluntad. En su formulación actual, los contratos generan derechos y obligaciones únicamente para las partes contratantes, sin que los terceros puedan resultar acreedores o deudores de un contrato ajeno. Esta regla se ha matizado con excepciones legales al efecto relativo y con el reconocimiento del llamado efecto absoluto o expansivo de los contratos.

3.2. Excepciones al efecto relativo de los contratos

Ocurren cuando un tercero absoluto resulta obligado o favorecido por un contrato ajeno. El caso más citado es la **estipulación a favor de otro (art. 1449)**, donde son partes el estipulante y el promitente, y el beneficiario, sin ser parte, es el único que puede pedir el cumplimiento (aunque no la resolución): habría ahí un tercero que resulta acreedor de un contrato ajeno, aunque parte de la doctrina niega que sea una verdadera excepción, porque siempre se requiere la aceptación del beneficiario, momento en el que pasaría a ser parte. Tampoco lo es la **promesa de hecho ajeno**, porque para producir efectos respecto del tercero requiere también su aceptación, con lo que deja de ser un tercero absoluto.

Un caso de excepción real está en el **art. 1645**, sobre novación: cuando esta se produce entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, libera también a los codeudores solidarios o subsidiarios que no fueron parte de ella y que, por tanto, no consintieron en la novación.

3.3. El efecto absoluto, indirecto o erga omnes

Un contrato puede ser invocado por un tercero a su favor, o hecho valer en su contra, porque una vez perfeccionado se convierte en un **hecho social** que existe para todos, sin que esto implique que genere derechos u obligaciones para esos terceros: solo que puede traerse a colación o servir de base a una preferencia. No hay aquí una excepción al efecto relativo, sino la constatación de que el contrato, como hecho social, es *oponible* a terceros (no inoponible), aunque no les sea fuente de obligaciones: en una quiebra, por ejemplo, los demás acreedores no pueden desconocer un crédito verificado alegando que emana de un contrato que no les afecta directamente.

De este efecto expansivo derivan, entre otras, la **acción pauliana**, que permite al acreedor pedir la revocación de un contrato celebrado entre su deudor y un tercero en su perjuicio; la posibilidad de que un tercero oponga o se valga de un contrato celebrado entre otras personas, en materia de responsabilidad civil extracontractual, para determinar el legitimado pasivo de la acción de indemnización de perjuicios; y la teoría de la **interferencia en contratos ajenos**, reconocida por la Ley de Competencia Desleal (**art. 4 letra f**)), que sanciona la conducta que persigue inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir sus deberes contractuales con un competidor. Los sistemas jurídicos que más han desarrollado esta figura (el americano, el alemán y el francés) presentan diferencias entre sí, pero la doctrina mayoritaria exige, para que proceda esta responsabilidad, que el tercero conozca el contrato ajeno y que actúe con dolo, sea directo (quiso el daño) o eventual (previó el perjuicio y actuó de todos modos), dolo que debe probar quien demanda, conforme a la regla general del **art. 1459**.

H. LA INEXISTENCIA JURÍDICA

La **ineficacia** de los actos jurídicos es la reacción del ordenamiento que priva de efectos a un acto que no cumple los requisitos de eficacia y validez, o que por un hecho posterior pierde, reduce o ve perturbados los efectos propios de un acto válido. Cuando la causa que priva de efectos es un defecto intrínseco a la estructura del acto, hay invalidez o nulidad y, para parte de la doctrina, inexistencia. Cuando la causa es un hecho posterior y ajeno al acto, que existe y fue válidamente formado, se habla de ineficacia en sentido estricto, con hipótesis como la suspensión, la resolución, la revocación, la caducidad o la inoponibilidad, tratadas más adelante en este capítulo.

1. CONCEPTOS GENERALES

Pocas materias han generado tanto debate en la teoría del acto jurídico como si el Código Civil chileno acoge o no la **teoría de la inexistencia jurídica**, discusión vigente hasta hoy. En términos generales, la inexistencia es la sanción de los actos celebrados con omisión de un requisito necesario para su existencia en el mundo del Derecho: falta la voluntad, el objeto, la causa o las solemnidades exigidas para la existencia del acto. Se dice también que el acto inexistente carece de un elemento esencial, de un órgano vital, de modo que no corresponde a la definición que la ley da para él: no puede haber compraventa sin precio, ni sociedad sin que las partes pongan algo en común.

La inexistencia jurídica supone la existencia material o de hecho de un acto, pero carente de existencia para el Derecho. Por carecer de toda existencia jurídica, opera *ipso iure*, no es susceptible de saneamiento alguno, y la acción para constatarla sería imprescriptible.

2. ORIGEN DE LA TEORÍA DE LA INEXISTENCIA JURÍDICA

Fue formulada a principios del siglo XIX por el jurisconsulto alemán **ZACHARIAE** en sus comentarios al Código de Napoleón, a propósito del matrimonio. El ordenamiento francés tiene un axioma casi absoluto, *pas de nullité sans texte* (no hay nulidad sin texto): tratándose del matrimonio, no habría más nulidades que las expresamente señaladas por la ley. Pero la ley no establecía expresamente la nulidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que, siguiendo el axioma, implicaría que era válido, conclusión inaceptable para la época. Para resolver esa contradicción, se sostuvo que la ley supone necesariamente, para que el matrimonio *exista*, el acuerdo entre un hombre y una mujer, de modo que si el acuerdo es entre dos personas del mismo sexo, el matrimonio directamente no existe, sin que el legislador necesitara declarar su ineficacia. Más tarde la teoría se extendió a los actos patrimoniales.

3. DIFERENCIAS ENTRE LA INEXISTENCIA Y LA NULIDAD

Para quienes sostienen la distinción, sus diferencias son las siguientes:

(i) Requisitos que afectan.

La inexistencia se refiere a los actos carentes de un requisito de *existencia* (voluntad, objeto, causa, solemnidades); la nulidad, a los que no reúnen un requisito de *validez* (voluntad no viciada, capacidad, objeto lícito, causa lícita).

(ii) Producción de efectos.

El acto inexistente no produce efecto alguno; el nulo produce todos sus efectos mientras su vicio no se declare judicialmente.

(iii) Forma de operar.

La inexistencia opera *ipso iure*, de pleno derecho, sin perjuicio de que el juez pueda constatarla ante una controversia. La nulidad, en cambio, debe ser declarada por los tribunales, y solo en virtud de esa declaración puede pedirse volver al estado anterior a la celebración del acto.

(iv) Saneamiento por el tiempo.

El acto inexistente no puede sanearse por el transcurso del tiempo; el nulo sí, según sea nulidad absoluta o relativa.

(v) Ratificación.

El acto inexistente no puede ratificarse, porque la nada confirmada sigue siendo la nada. La nulidad relativa sí puede sanearse por ratificación de las partes (**art. 1684**); la absoluta no, pero por una razón distinta: por ser una institución de orden público, establecida en interés de la moral y la ley, no de las partes.

(vi) Quiénes pueden alegarla.

La nulidad relativa solo puede alegarla aquel en cuyo beneficio la establece la ley, o sus herederos o cesionarios (**art. 1684**); la absoluta, todo el que tenga interés en ello, salvo quien celebró el acto sabiendo o debiendo saber el vicio (**art. 1683**); la inexistencia, cualquiera, sin restricción.

(vii) Efectos de la declaración.

La nulidad declarada, sea absoluta o relativa, solo aprovecha a la parte en cuyo favor se decretó: si dos o más personas contrataron con un tercero, la nulidad declarada a favor de una no aprovecha a las otras (**art. 1690**). Esta regla no se extendería a la inexistencia, que una vez constatada judicialmente beneficiaría a todo interesado.

4. ¿DISTINGUE EL CÓDIGO CIVIL CHILENO LA INEXISTENCIA Y LA NULIDAD ABSOLUTA?

4.1. Doctrina que afirma que sí distingue

Sostiene, primero, que dos preceptos lo demuestran: el **art. 1444** dice que la falta de una cosa esencial hace que el acto *no produzca efecto alguno*, sin decir que sea nulo; y el **art. 1681** declara nulo el acto al que falta un requisito prescrito *para el valor*, no *para la existencia*. La distinción aparecería también en otras normas (**arts. 1701, 1801, 1802, 1809, 1814, 2027, 2055, 2057**): el **art. 1701**, por ejemplo, dice que la falta de instrumento público exigido como solemnidad hace que el acto se mire *como no ejecutado o celebrado*, no como nulo, porque lo que no existe no puede calificarse de válido ni de nulo, sino que es la nada.

Agrega que la sanción de nulidad absoluta a los actos de los absolutamente incapaces no refuta la tesis: según **CLARO SOLAR**, su incapacidad proviene de la falta de discernimiento para tener y manifestar una voluntad consciente, de modo que en rigor no consienten, pero como pueden *aparentar* consentir, la ley debió declarar expresamente la nulidad absoluta de sus actos. También responde al argumento de que el **art. 1682** no menciona expresamente la falta de objeto, causa o consentimiento entre las causales de nulidad absoluta: para esta doctrina, si no se admitiera la inexistencia, esos casos caerían en la nulidad relativa (la regla general), lo que sería una aberración.

Un antecedente moderno refuerza esta lectura: el antiguo **art. 6°** de la Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, declaraba expresamente que *no existe* la sociedad en cuya constitución se hubiese omitido el otorgamiento de la escritura social o la oportuna inscripción o publicación de su extracto, sancionando en cambio con nulidad absoluta las demás omisiones de ese instrumento: una distinción textual entre inexistencia y nulidad. La Ley N° 19.499, de 1997, eliminó esa referencia expresa a la inexistencia y unificó la sanción en la nulidad absoluta, pero agregó que la sociedad anónima que no conste de escritura pública, de instrumento reducido a escritura pública o de instrumento protocolizado es *nula de pleno derecho y no podrá ser saneada* (art. 6°A): una nulidad que opera sin necesidad de sentencia judicial y que es insubsanable, ajena por completo a la nulidad del Código Civil, que nunca opera *ipso iure*, y que por eso mismo se asemeja, en sus efectos, más a la inexistencia que a la nulidad ordinaria.

4.2. Doctrina que niega la distinción

Sostiene que el Código solo conoce la nulidad absoluta y la relativa, comprendiendo los actos inexistentes dentro de los nulos de nulidad absoluta. El axioma francés *pas de nullité sans texte* que dio origen a la teoría no tiene acogida en Chile, de modo que los problemas que la motivaron ya están resueltos por la nulidad absoluta. El **art. 1682** sanciona con esa nulidad la omisión de *algún requisito* exigido en consideración a la naturaleza del acto, fórmula lo bastante amplia para comprender tanto los de existencia como los de validez; y el propio **art. 1682** inciso 2° declara ex-

presamente nulos de nulidad absoluta los actos de los absolutamente incapaces, pese a que para esta doctrina en ellos falta lisa y llanamente la voluntad.

Añade que aunque el **art. 1682** no mencione la falta de objeto como causal de nulidad absoluta, sino solo el objeto ilícito, la sanción sería la misma: el propio **art. 1461** equipara el hecho físicamente imposible (que no puede existir, la falta de objeto más radical) con el moralmente imposible, y el Código trata expresamente como *objeto ilícito* (nulidad absoluta) la enajenación de cosas inenajenables, que en rigor carecerían de objeto (**arts. 1464 N° 1 y 1810**). Y como el **art. 10** dice que los actos prohibidos por la ley *son nulos y de ningún valor*, para el legislador expresiones como *nulidad*, *ningún valor* o *no producir efectos* significarían siempre lo mismo. A esto se suma que el Código de Procedimiento Civil, al enumerar taxativamente las excepciones que pueden oponerse en el juicio ejecutivo, menciona *la nulidad de la obligación* (**art. 464 N° 14 CPC**) y no la inexistencia, lo que debe entenderse en el sentido de que esta queda comprendida en aquella; y que, pese a la trascendencia que se le atribuye, no existe ninguna ley de la República que reconozca a la inexistencia como una sanción autónoma de ineficacia.

4.3. Análisis desde la historia fidedigna del establecimiento del Código

Ambas posturas cuentan con argumentos sólidos, lo que obliga a mirar la historia fidedigna del Código. El Mensaje señala que en materia de nulidad se siguió de cerca al Código francés, pero las notas de BELLO sobre el punto no citan el *Code* sino a DELVINCOURT, por lo que ese argumento no es decisivo.

En el Código francés existe una sola clase de nulidad (la *anulabilidad*, equivalente a nuestra nulidad relativa, causada por error, fuerza, dolo o lesión), saneable por ratificación y por el tiempo, y solo demandable por ciertas personas. Ante la ausencia de un régimen para casos más radicales, la doctrina francesa elaboró la *inexistencia* (sinónimo, para ella, de nulidad de pleno derecho, nulidad radical o nulidad absoluta), que opera de pleno derecho, es insubsanable y de acción imprescriptible, y que en Francia sanciona los actos contrarios al orden público y las buenas costumbres, los de causa ilícita y los de los absolutamente incapaces.

BELLO, sin embargo, se apartó del Code al regular expresamente dos clases de nulidad, absoluta y relativa, y asignó a la nulidad absoluta exactamente esas mismas causales que la doctrina francesa reserva a la inexistencia (**arts. 1461, 1467 y 1682**). La diferencia decisiva está en los **efectos**: mientras la inexistencia francesa es insubsanable, BELLO dispuso expresamente que la nulidad absoluta se sana por el transcurso de diez años (**art. 1683**). La historia de esa norma confirma que fue una decisión consciente: el Proyecto de 1842, siguiendo a Francia, decía que la nulidad absoluta no podía sanearse ni por el tiempo ni por ratificación; el Proyecto de 1853 agregó que no podía alegarse contra una posesión pacífica de treinta años; y el Proyecto Inédito, ya en la fórmula que llegó al Código, fijó derechamente el plazo de treinta años (reducido a diez por la Ley N° 16.952 de 1968) como límite para alegarla. La conclusión, para esta lectura, es que en Chile **nulidad absoluta e inexistencia son la misma institución**, que se rige en todo por el **art. 1683**.

4.4. Jurisprudencia sobre la materia

La jurisprudencia sobre este debate ha sido fluctuante. Entre los fallos que rechazan la teoría de la inexistencia como sanción autónoma se cuentan la Corte Suprema de 6 de noviembre de 1931 (G. 1931, 2º semestre, N° 42, pp. 222-229, voto de minoría), de 19 de agosto de 1942 (RDJ, t. XLIV, 2ª parte, secc. 1ª, pp. 76-86), de 31 de mayo de 2011 (rol 271-2010) y de 28 de noviembre de 2012 (rol 4537-10), además de la Corte de Valparaíso de 17 de septiembre de 1966 (RDJ, t. LXIII, pp. 67-101), la de San Miguel de 10 de junio de 1985 (GJ N° 60, 1985, pp. 73-82), y las de Santiago de 23 de marzo de 1990 (RDJ, t. LXXXVII, 1990, p. 69) y de 2 de mayo de 1997 (rol 2153-1995). Entre los que la acogen, la Corte Suprema de 4 de septiembre de 1991 (Fallos del Mes N° 397, p. 447), de 21 de junio de 1914 (RDJ, t. XVI, 2ª parte, secc. 1ª, pp. 1-11), de 11 de noviembre de 1922 (RDJ, t. XXI, 2ª parte, secc. 1ª, pp. 973-980), de 4 de abril de 1945 (RDJ, t. XLII, 2ª parte, secc. 1ª, pp. 558-559) y de 15 de septiembre de 1967 (RDJ, t. LXIV, 2ª parte, secc. 1ª, pp. 304-305), además de la Corte de Santiago de 4 de agosto de 1936 (RDJ, t. XXXIV, 1937, 2ª parte, secc. 2ª, pp. 70-80), la de Chillán de 27 de septiembre de 1945 (RDJ, t. XLIII, 1946, 2ª parte, secc. 2ª, pp. 38-42), la de San Miguel de 8 de mayo de 1981 (RDJ, t. LXXVIII, 1981, 2ª parte, secc. 2ª, pp. 93-95), la de Concepción de 11 de abril de 1995 (rol 315-1994) y la de Santiago de 18 de noviembre de 2011 (rol 5168-2010).

CORTE SUPREMA, RDJ, T. LI, SEGUNDA PARTE, SEC. 1ª, P. 483

En el Código Civil se confunden ambos efectos de la carencia de requisitos de existencia y de validez, de manera que no hay inconveniente para denominar nulidad absoluta a la inexistencia.

En general, la mayoría de los fallos de la Corte Suprema no reconoce a la inexistencia como una sanción autónoma con sus caracteres propios (operar de pleno derecho, ser insaneable, dar lugar a una acción imprescriptible); en los casos en que la reconoce, suele hacerlo en términos retóricos, aplicándole finalmente las mismas reglas de la nulidad absoluta, como refleja el fallo citado.

I. LA NULIDAD: ASPECTOS GENERALES

1. REGLAS DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE LA NULIDAD

El Código regula la nulidad de los actos y contratos en el Título XX de su Libro IV (**arts. 1681 a 1697**), sin perjuicio de reglas especiales en otras disposiciones. Sus normas se aplican a cualquier acto jurídico, unilateral o bilateral, salvo que una disposición expresa consulte otra sanción. Son de **orden público**, de aplicación estricta e inderogables por las partes, y se aplican también a las demás ramas del derecho privado a falta de norma especial, pero no al derecho público, que tiene sus propias reglas de nulidad en cada una de sus ramas (administrativa, procesal, etc.).

2. CONCEPTO GENERAL DE NULIDAD

Es la sanción legal establecida por la omisión de los requisitos y formalidades que se prescriben para el valor de un acto según su especie y la calidad o estado de las partes, tal como se desprende del **art. 1681** inciso 1º: *es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes.*

3. ESPECIES DE NULIDAD: ABSOLUTA Y RELATIVA

La nulidad puede ser absoluta o relativa (**art. 1681 inc. 2º**). Es **absoluta** la sanción a los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie; es **relativa** la que sanciona la prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de las partes. El diferente calificativo se explica porque el acto nulo absolutamente está viciado objetivamente, en sí mismo, por lo que su nulidad existe respecto de todos (*erga omnes*); el nulo relativamente nada tiene de reprochable en sí, y su vicio, subjetivo, solo existe en relación con determinadas personas.

4. TERMINOLOGÍA

La doctrina suele reservar *nulidad* para la absoluta, y *anulabilidad* o *rescisión* para la relativa, distinción que el propio título del Código recoge (*de la nulidad y la rescisión*), aunque no la mantiene con rigor. Parte de la doctrina sostiene que *nulidad relativa* y *rescisión* no son sinónimos, pese al **art. 1682** inciso final, por tres razones. Primero, la norma no dice que sean lo mismo, solo que la nulidad relativa *da derecho a la rescisión*, es decir, a pedir que el tribunal deje sin efecto el contrato. Segundo, *rescindir* significa, según la Real Academia Española, dejar sin efecto un contrato u obligación, efecto común a ambas nulidades; por eso, cuando el legislador habla del derecho a la

rescisión no necesariamente se refiere a la nulidad relativa, sino al derecho a pedir que el contrato quede sin efecto por el vicio que sea. De hecho, hay casos en que, tratándose de vicios de nulidad absoluta, el legislador también habla de rescisión: quienes hacen sinónimos ambos términos ven ahí un error del legislador, pero para esta doctrina simplemente se está usando la palabra para significar el derecho a pedir la nulidad que corresponda. Tercero, si nulidad relativa y rescisión fueran lo mismo, el art. 1682 inciso final terminaría diciendo que la nulidad relativa da derecho a pedir la nulidad relativa, lo que es absurdo. Para esta doctrina, la **rescisión** es entonces el efecto de la nulidad, el derecho a pedir que se deje sin efecto un acto, sea cual sea la causa que la origina.

5. ESPECIE DE NULIDAD QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL

El Código, tras señalar cuándo hay nulidad absoluta, agrega que *cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa* (**art. 1682** inciso final): la regla general es, por consiguiente, la **nulidad relativa**.

6. DIFERENCIAS ENTRE LA NULIDAD ABSOLUTA Y LA RELATIVA

Comparando los **arts. 1683 y 1684** surgen cuatro diferencias.

(i) Declaración de oficio.

La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el juez cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. La relativa solo puede declararse a petición de parte.

(ii) Personas que pueden pedirla.

La absoluta puede alegarla todo el que tenga interés en ello, y pedirla el ministerio público en el solo interés de la moral y la ley. La relativa solo puede alegarla aquel en cuyo beneficio la establece la ley, o sus herederos o cesionarios.

(iii) Saneamiento por el tiempo.

La absoluta se sana en **diez años** desde la celebración del acto. La relativa, en **cuatro años**, contados desde la celebración en caso de error o dolo, y desde que cesa la fuerza o la incapacidad, en esos casos.

(iv) Saneamiento por ratificación.

La absoluta no puede sanearse por la ratificación de las partes. La relativa sí, mediante la confirmación del acto rescindible por quien tiene derecho a alegarla, o sus herederos o cesionarios.

7. PRINCIPIOS APLICABLES A AMBAS CLASES DE NULIDAD

(i) De derecho estricto.

Las nulidades, por ser una sanción, no se aplican ni interpretan por analogía: solo existen las que la ley expresamente consagra, sea porque declara nulo un acto, sea porque lo prohíbe sin designar otra sanción para su contravención (**art. 10**).

(ii) Irrenunciable anticipadamente.

La nulidad protege intereses superiores de la colectividad, por lo que los actos y contratos que la ley declara inválidos no dejan de serlo por cláusulas en que se renuncie anticipadamente a la acción de nulidad (**art. 1469**).

(iii) Momento de la omisión.

La ausencia del requisito o el vicio debe existir al momento de la celebración del acto, no después.

(iv) Efecto solo entre partes.

Cuando dos o más personas contrataron con un tercero, la nulidad declarada a favor de una no aprovecha a las otras (**art. 1690**).

(v) Acción o excepción.

La nulidad puede hacerse valer en juicio tanto como acción como excepción.

(vi) Necesidad de sentencia judicial.

Ninguna nulidad, absoluta o relativa, produce sus efectos sino en virtud de sentencia judicial firme: mientras no se declara, el acto viciado surte todos sus efectos, amparado por una presunción de validez; declarada, la nulidad opera retroactivamente y aniquila esos efectos hacia el pasado. Parte de la doctrina discrepa respecto de la nulidad absoluta: por su gravedad (por ejemplo, actos contrarios a la ley o al orden público), sostienen que opera de pleno derecho, sin declaración judicial, y que lo que el **art. 1683** llama saneamiento en realidad es la caducidad de la acción para impugnar el acto, a los diez años de celebrado.

8. NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL DEL ACTO JURÍDICO

El vicio puede afectar al acto en su conjunto (nulidad **total**) o solo a una parte o cláusula, o a un elemento de una cláusula (nulidad **parcial**). Para fijar su extensión hay que determinar, en cada caso, la importancia de la disposición viciada respecto del resto sustancial del acto: si compromete su esencia, o si es un accidente de relativa importancia que las partes habrían aceptado igual sin ella. El **art. 1061**, que declara nula la disposición testamentaria a favor del notario, ilustra el caso:

esa nulidad parcial no compromete las disposiciones esenciales del testamento, como el nombramiento de herederos.

9. LA NULIDAD REFLEJA

Vinculado a este fenómeno está el de la **nulidad consecuencial o de resultado**: cuando la cláusula nula contiene la estipulación principal del acto, o cuando este no puede subsistir sin ella, su nulidad acarrea la de todo el acto. Es una aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal: la nulidad del acto principal acarrea la del accesorio, pero no a la inversa. Así, la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal (**art. 1536**), e igual ocurre en la fianza (**art. 2381 N° 3**).

Se presenta en los actos **solemnes**, cuando la ley exige el cumplimiento de una forma, típicamente el otorgamiento de escritura pública, como único medio idóneo de expresar la voluntad. Esa escritura, en cuanto instrumento, está a su vez sujeta a sus propios requisitos de validez; si se omite alguno de ellos, la nulidad del instrumento se traspasa (se refleja) al acto que contiene, que también resulta nulo. No debe confundirse este fenómeno con el caso, distinto, en que un mismo instrumento contiene varios actos independientes entre sí, como una compraventa y un mutuo pactados en la misma escritura: ahí la nulidad de uno de ellos no contamina al otro, pese a constar ambos en el mismo documento.

J. LA NULIDAD ABSOLUTA

1. CONCEPTO

Del **art. 1681** se desprende que la nulidad absoluta es la sanción a todo acto o contrato al que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, según su especie.

2. CAUSALES

Conforme al **art. 1682**, son causales de nulidad absoluta el objeto ilícito, la causa ilícita, la incapacidad absoluta, y la omisión de requisitos o formalidades que la ley prescribe para el valor de ciertos actos en consideración a su naturaleza. Para quienes no aceptan la teoría de la inexistencia, a estas se agregan la falta de voluntad, de objeto o de causa, el error esencial (aunque algunos lo sancionan con nulidad relativa) y la omisión de requisitos o formalidades exigidos para la *existencia* del acto en consideración a su naturaleza.

3. FUNDAMENTO Y CARACTERES

Se establece en interés de la moral y de la ley, para proteger la primera y obtener la observancia de la segunda, no en el de determinadas personas. De ese fundamento derivan sus principales caracteres: su declaración de oficio, quiénes pueden pedirla, y la imposibilidad de sanearla por ratificación.

4. DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA

Conforme al **art. 1683**, procede por tres vías.

a. De oficio por el juez, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato.

La nulidad aparece *de manifiesto* cuando basta leer el instrumento en que consta el acto, sin relacionarlo con otra prueba, para establecerla; y, desde luego, solo si existe un juicio en que ese acto o contrato se hace valer.

b. A petición de todo el que tenga interés en ello, excepto quien celebró el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

Puede pedirla cualquier parte o tercero con un interés, generalmente pecuniario, en que se reparen los perjuicios del acto viciado, interés que debe acreditar quien lo invoca. Por excepción, no puede alegarla quien celebró el acto *sabiendo* (con conocimiento real y efectivo) o *debiendo saber* (cuando las circunstancias no permiten considerar razonable su ignorancia) el vicio, porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo. La misma idea aparece en el **art. 1468**, que impide repetir lo dado

o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas: en ambos casos el conocimiento exigido es real y efectivo, no el conocimiento presunto de la ley. Se discute si esta inhabilidad afecta también al representado cuyo representante conocía el vicio. Para una opinión, no podría alegarla porque lo hecho por el representante se estima hecho por el representado (**art. 1448**); para la que hoy prevalece, sí puede pedirla, porque el dolo es personalísimo y el representante solo está autorizado para ejecutar actos lícitos, de modo que la prohibición alcanza a quien intervino directamente en el acto, no al representado, salvo que se compruebe la concurrencia inequívoca de su propia voluntad. También se discute si comprende a los herederos de quien celebró el acto con ese conocimiento: a favor de que sí pueden alegarla se sostiene que la inhabilidad es una regla de excepción y debe interpretarse restrictivamente, sin extenderse a quienes la ley no menciona literalmente; en contra, que los herederos no pueden adquirir por sucesión un derecho que su causante no tenía, y que si la ley ni siquiera permite alegar la nulidad a los herederos del incapaz cuyo dolo es imputable a él (**art. 1685**), con mayor razón debe negárselo a los herederos y cesionarios de las personas capaces.

CORTE SUPREMA, 29 DE ABRIL DE 2008, ROL N° 1.969-2006

A nadie le es lícito hacer valer un derecho civil o procesal en contradicción con su anterior conducta jurídica. Esta doctrina, conocida como de los **actos propios**, ha sido recogida en diversas disposiciones del Código Civil, entre ellas el propio **art. 1683**, y permite al sentenciador ponderar la actitud lógica del actor o de su contraparte: nadie puede contradecir lo dicho o hecho por él mismo, en perjuicio de un tercero.

c. Por el ministerio público, en el interés de la moral o de la ley.

Se trata del ministerio público que integran el fiscal de la Corte Suprema y los de las Cortes de Apelaciones (**art. 350 COT**), no el organismo homónimo del proceso penal.

5. LA NULIDAD ABSOLUTA NO PUEDE SANEARSE POR LA RATIFICACIÓN DE LAS PARTES

Así lo dispone expresamente el **art. 1683** parte final. La ratificación importaría dar por válido un acto que no lo es, renunciando a pedir su nulidad; su imposibilidad se explica porque la nulidad absoluta está establecida en el interés general, que no puede quedar supeditado a la voluntad particular.

6. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA POR EL TRANCURSO DEL TIEMPO

Conforme al **art. 1683**, la nulidad absoluta no puede alegarse transcurridos **diez años** desde la celebración del acto, plazo que responde a la necesidad de consolidar los derechos. El plazo se cuen-

ta desde la fecha de celebración del acto, porque desde entonces podía ejercerse la acción de nulidad, aplicando el mismo principio que rige la prescripción extintiva, contada desde que la obligación se hace exigible (**art. 2514** inc. final). Parte de la doctrina, como **BARAONA**, discute que se trate propiamente de un saneamiento (dogmáticamente el tiempo no puede volver legal lo que no lo fue) y lo entiende más bien como una **caducidad** de la facultad de impugnar el acto, que afecta a quienes podían hacerlo (el juez, las partes, los terceros interesados y el ministerio público), cuyo efecto es consolidar los desplazamientos patrimoniales, convirtiendo el título en justo para efectos de la prescripción adquisitiva (**art. 705**).

7. LA NULIDAD ABSOLUTA NO SE PRODUCE DE PLENO DERECHO

La doctrina tradicional, a partir de las normas que hablan de nulidad judicialmente *declarada* o *pronunciada* (**arts. 1683, 1687 y 1689 del Código Civil, y 37 de la Ley de Matrimonio Civil**), sostiene que la nulidad absoluta debe ser declarada por el juez, sin operar de pleno derecho: el acto nulo absolutamente produce efectos mientras no exista sentencia judicial. Para otros, como **BARAONA**, la función de esa sentencia es otra: hacer actuales el derecho a exigir y el deber de practicar la restitución.

K. LA NULIDAD RELATIVA

1. DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO

Es la sanción legal impuesta a los actos celebrados con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de las partes (**art. 1681**). No protege el interés de la moral y la ley, sino el de ciertas y determinadas personas en cuyo beneficio el legislador la establece.

2. CAUSALES

El **art. 1682** señala que cualquier otro vicio, distinto de los de nulidad absoluta, produce nulidad relativa. Son causales: los actos de los relativamente incapaces; el error sustancial; el error en una calidad accidental elevada a la categoría de esencial; el error relevante en la persona; la fuerza grave, injusta y determinante; el dolo determinante (y, en los actos bilaterales, además obra de una de las partes); la omisión de formalidades habilitantes exigidas en consideración al estado o calidad de las personas; y la lesión, en los casos que la ley expresamente sanciona con rescisión.

3. CARACTERÍSTICAS

De hallarse establecida en interés particular se desprende que: solo pueden alegarla aquellos en cuyo beneficio la establece la ley; puede sanearse por el transcurso del tiempo; y puede sanearse por la ratificación de las partes.

4. PERSONAS LEGITIMADAS PARA ALEGAR LA NULIDAD RELATIVA

4.1. Regla general

La nulidad relativa no puede ser declarada de oficio, ni pedirla el ministerio público en el solo interés de la ley, ni alegarla sino aquellos en cuyo beneficio la establecen las leyes, o sus herederos o cesionarios (**art. 1684**). Si hubo error, fuerza o dolo, solo puede pedir la rescisión quien lo sufrió, no la otra parte; si el contrato lo celebró un incapaz, solo él. Los **herederos** de quien tenía derecho a pedirla y falleció sin hacerlo pueden alegarla, porque suceden al causante en ese derecho; igualmente los **cesionarios** a quienes se transfirieron por acto entre vivos los derechos que emanan del acto o contrato nulo.

4.2. Situación excepcional del incapaz que no puede demandar la rescisión

El **art. 1685** priva al incapaz relativo del derecho a alegar la nulidad cuando, con **dolo**, se hizo pasar por capaz (por ejemplo, falsificando una partida de nacimiento) para inducir la celebración del

acto: en tal caso, ni él ni sus herederos o cesionarios pueden alegarla, porque el otro contratante no fue negligente y no puede presumirse su mala fe. La solución es distinta si el incapaz se limitó a *aseverar* ser mayor de edad o que no existía la causa de su incapacidad, sin desplegar maniobras dolosas: en ese caso sí puede pedir la nulidad después, porque la ley entiende que el otro contratante fue negligente al confiarse en meras aserciones.

5. LA NULIDAD RELATIVA PUEDE SANEARSE POR EL TRANCURSO DEL TIEMPO

El plazo para pedir la rescisión es de **cuatro años** (**art. 1684**), contados desde la celebración del acto en caso de error o dolo, y desde que cesa la fuerza o la incapacidad legal, en esos casos (**art. 1691**), salvo que leyes especiales fijen otro plazo. Transcurrido ese plazo sin que se alegue, el vicio desaparece y el acto queda completamente sano, como si siempre hubiese sido válido.

6. LA NULIDAD RELATIVA PUEDE SANEARSE POR LA RATIFICACIÓN O CONFIRMACIÓN DE LAS PARTES

6.1. Concepto

En el sentido que aquí interesa, **ratificación** equivale a confirmación del acto nulo relativamente: la renuncia al derecho de pedir la nulidad, sin importar una renovación del acto viciado. Se justifica porque la nulidad relativa protege un interés particular, renunciable conforme a la regla general del **art. 12**. Es un acto jurídico **unilateral** que solo puede realizar quien está legitimado para pedir la nulidad.

6.2. Clases

Puede ser **expresa**, cuando la parte formula una declaración explícita de validar el acto, o **tácita**, la ejecución voluntaria de la obligación contraída (**art. 1695**). Para esa ejecución sea voluntaria, la doctrina más acertada exige que el confirmante conozca el vicio de nulidad relativa, no solo que actúe sin coacción; la mayoría de la doctrina entiende que solo la ejecución de la obligación (no cualquier otro comportamiento, como pedir plazo para pagar) puede constituir ratificación tácita, y que no importa si el acto se ejecuta en su totalidad o solo parcialmente.

6.3. Características de la ratificación

Es un acto **unilateral**, que solo requiere la voluntad del confirmante; **accesorio y dependiente**, porque no subsiste sin el acto que convalida; **irrevocable**, pues quien confirma no puede después desconocer la confirmación y pedir la rescisión; y opera con **efecto retroactivo**, por una ficción legal que supone al acto siempre válido.

6.4. Requisitos de la ratificación

Solo opera respecto de un vicio de **nulidad relativa**. Debe emanar de la parte que tiene derecho a alegar la nulidad (**art. 1696**), y esa persona debe ser **capaz** de contratar (**art. 1697**), salvo que actúe representada o autorizada. Debe realizarse en **tiempo oportuno**, antes de la declaración de nulidad, y después de haber **cesado la causa de invalidez**, sin adolecer del mismo vicio que afecta al acto que se ratifica, con conocimiento de ese vicio y del derecho a pedir la nulidad, y con intención de confirmar. Si es expresa, debe hacerse con las mismas solemnidades a que está sujeto el acto o contrato que se ratifica (**art. 1694**).

L. LOS EFECTOS DE LA NULIDAD

1. CONCEPTOS GENERALES

La nulidad absoluta y la relativa se diferencian en quiénes pueden pedirlas, en si se declaran de oficio, y en su saneamiento, pero en cuanto a sus **efectos** no hay diferencia alguna: las normas que los regulan (**arts. 1687 y 1689**) se aplican a ambas por igual. Para que se produzcan es indispensable una **sentencia judicial firme** que declare la nulidad; antes de esa sentencia, el acto anulable produce todos sus efectos, aunque expuesto a ser invalidado.

2. EFECTOS DE LA NULIDAD RESPECTO DE LAS PARTES

La nulidad declarada da a las partes derecho a ser **restituidas al mismo estado en que se hallarían si el acto nulo no hubiese existido**, sin perjuicio de lo previsto sobre objeto o causa ilícita (**art. 1687**). Como la nulidad opera con efecto retroactivo, se entiende que el acto nunca existió; por eso el Código la incluye entre los modos de extinguir las obligaciones (**art. 1567 N° 8**). Las restituciones mutuas siguen las reglas generales de las prestaciones mutuas del título de la reivindicación (**arts. 904 a 915**): declarada nula una compraventa, el comprador restituye la cosa y el vendedor el precio, considerando la buena o mala fe de cada parte para la responsabilidad por pérdida, deterioro, frutos y mejoras.

La doctrina tradicional suele distinguir, para determinar estos efectos entre las partes, según el contrato no se haya cumplido por ninguna (caso en que las obligaciones simplemente se extinguen por la declaración de nulidad, **art. 1567 N° 8**, sin lugar a restituciones) o se haya cumplido por una o por ambas (caso en que rige el **art. 1687**). Para VIAL, esta distinción presenta imprecisiones que la hacen poco aconsejable: en los contratos reales, de los que nace la obligación de restituir, aplicarla llevaría a que, si se declara nulo un contrato real cuya cosa aún no se ha restituido, esa obligación se extinguiría sin más, resultado injusto y contrario al espíritu del art. 1687.

Esta regla tiene **cuatro excepciones**:

(i) El poseedor de buena fe.

No está obligado a restituir los frutos percibidos mientras estuvo de buena fe, que se presume hasta la contestación de la demanda (**art. 907**).

(ii) Objeto o causa ilícita a sabiendas.

No puede repetirse lo dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas (**art. 1468**), sanción a quien infringió la ley conscientemente.

(iii) El contrato con un incapaz.

Quien contrató con un incapaz sin los requisitos legales no puede pedir restitución de lo que gastó o pagó, sino en cuanto pruebe que el incapaz se hizo **más rico** con ello (**arts. 1687 inc. 2° y 1688**): porque las cosas pagadas o adquiridas con ellas le fueron necesarias, o porque, no siéndolo, subsisten y quiere retenerlas. Si el incapaz se hizo más rico, sí debe restituir según la regla general, porque de lo contrario habría enriquecimiento sin causa; esta protección opera solo cuando el contrato se anula por la incapacidad, no por otra causal.

(iv) El poseedor que adquiere por prescripción.

La tradición, aunque nula o anulada, constituye un título posesorio hábil para adquirir el dominio por prescripción extraordinaria.

3. EFECTOS DE LA NULIDAD RESPECTO DE TERCEROS

La nulidad judicialmente declarada, absoluta o relativa, da **acción reivindicatoria** contra terceros poseedores (**art. 1689**): el dueño de una cosa singular de que no está en posesión puede exigir que el poseedor se la restituya (**art. 889**). Como la nulidad opera retroactivamente, se reputa que el dominio nunca salió del tradente, de modo que nadie después de él pudo adquirirlo, ni transferir a un tercero más derechos de los que tenía. A diferencia de la **resolución**, que solo da acción reivindicatoria contra terceros poseedores de mala fe (**arts. 1490 y 1491**), la nulidad la da contra terceros poseedores de buena o mala fe, sin distinción. Si en vez de enajenarse la cosa se la gravó con hipoteca, servidumbre u otro derecho real, o se ejecutó algún acto que despoje al propietario de alguno de sus atributos, el verdadero dueño tiene también acción para hacer caducar esos gravámenes, por haber sido constituidos por quien no era dueño.

Existen tres excepciones en que la nulidad no da acción reivindicatoria contra terceros:

(i) La rescisión por lesión enorme.

No caducan las hipotecas u otros gravámenes constituidos sobre la cosa; el comprador que debe restituirla tiene que purificarla previamente de ellos (**art. 1895**), y la acción se extingue si la cosa fue enajenada (**art. 1893**).

(ii) El tercero que adquirió por prescripción.

Se desprende de los **arts. 682, 683 y 717**: los vicios del título de los antecesores no se transmiten al poseedor que adquirió por prescripción.

EJEMPLO

Por qué C se salva de la reivindicación

A vende un inmueble a B, quien de inmediato lo vende a C, con sus respectivas tradiciones. A los ocho años A demanda la nulidad del contrato con B por objeto ilícito (la acción está vigente, pues la nulidad absoluta se sana en diez) y entabla, a la vez, acción reivindicatoria contra C. El contrato entre A y B se anula, pero A no puede reivindicar de C: aunque la tradición no le dio el dominio (porque B no lo tenía), la ley le permitió ganarlo por prescripción ordinaria de cinco años dada su posesión regular, y la acción reivindicatoria se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho (**art. 2517**).

Si el poseedor se colocó por su propio acto en la imposibilidad de restituir la cosa (por ejemplo, enajenándola a un cuarto), rigen las reglas del título de la reivindicación sobre el poseedor que ha dejado de poseer (**arts. 898 y 900**): puede pedírsele la restitución de lo que recibió por la cosa, y si la enajenó a sabiendas de que era ajena, debe además resarcir todo perjuicio.

(iii) El heredero indigno que enajena bienes de la herencia.

Declarada judicialmente la indignidad, el heredero o legatario debe restituir la herencia o legado; pero si ya enajenó los bienes, la acción de los demás herederos solo procede contra los terceros de mala fe (**art. 974**).

4. ACCIONES A QUE DA ORIGEN LA NULIDAD

El acto nulo origina, en general, dos acciones: una **personal** de anulación, contra los contratantes, y otra **real**, reivindicatoria, contra el actual poseedor de la cosa. Aunque lógicamente debería entablarse primero la de nulidad y luego la reivindicatoria, la práctica permite deducirlas conjuntamente en un mismo juicio (**arts. 17 y 18 C.P.C.**), siendo la segunda una petición condicional a que se acoja la primera. Cierta doctrina agrega una tercera acción posible, de indemnización de perjuicios.

4.1. La acción de nulidad

Es **personal**: se dirige contra el otro contratante, o contra todos ellos si la entabla un tercero por nulidad absoluta. La **acción de nulidad absoluta** prescribe en diez años desde la celebración del acto; la de **nulidad relativa**, en cuatro años, contados desde la celebración salvo en los casos de fuerza o incapacidad legal, en que corren desde que cesa la violencia o la incapacidad (**art. 1691**).

La prescripción de la nulidad absoluta y de la relativa es **extintiva**: la acción se extingue por el simple transcurso del tiempo sin ejercerla. La de nulidad relativa es, además, una prescripción **de corto tiempo**, por lo que en principio corre contra toda persona, salvo que la ley establezca expre-

samente otra regla (**art. 2524**); la acción rescisoria es precisamente uno de esos pocos casos de excepción.

La prescripción de la acción rescisoria se **suspende**, único caso de suspensión en esta materia, a favor de los **herederos menores** de quien podía pedirla: a ellos el cuadrienio, o su residuo, les corre desde que llegan a la mayoría de edad, no desde la muerte del causante (**art. 1692**); si los herederos son mayores, no hay suspensión y gozan del cuadrienio completo o del residuo, según hubiera empezado a correr o no. En ningún caso, sin embargo, puede pedirse la rescisión pasados diez años desde la celebración del acto, aplicación del principio conforme al cual, transcurridos diez años, no se toman en cuenta las suspensiones establecidas a favor de ciertas personas (**art. 2520 inc. 2°**).

4.2. La acción reivindicatoria

Es de carácter **real**: se dirige contra quien posea la cosa, sea el propio contratante o un tercero (**art. 1689**), porque la nulidad retrotrae el dominio al tradente original. Se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho por parte de quien la resiste (**art. 2517**).

4.3. La acción de indemnización de perjuicios

Es un tema poco explorado por la doctrina nacional: no se trata de exigir las obligaciones del contrato nulo (que también son nulas), sino de determinar si nace otro tipo de responsabilidad de la celebración del acto o de la declaración de nulidad. El Código no tiene una regla general, pero sí disposiciones aisladas que la reconocen en casos puntuales: el **art. 1455** da acción a quien de buena fe contrató erradamente con una persona por error en esta; el **art. 1814** obliga a resarcir al comprador de buena fe cuando el vendedor sabía que la cosa vendida no existía en todo o en parte; y el **art. 1458** inciso 2° da acción de perjuicios por el dolo incidental, que no vicia el consentimiento (BARAONA sostiene que la palabra *solamente* de esa norma sugiere que también está disponible cuando el dolo sí es determinante y da derecho a la rescisión).

Para las demás causales, sin norma expresa, la doctrina distingue. La **fuerza** (siempre injusta, por definición) da derecho a indemnización como acto ilícito (**art. 2314**). En el **error sobre cualidades accidentales**, si ambas partes incurrieron en él las culpas se compensan y no procede indemnización, porque mal podría pedirla quien no se aseguró de la ausencia de error; pero si solo una lo padeció y la otra lo conocía sin advertirlo, hay reticencia que puede fundar una indemnización. En el **error sustancial o esencial**, la doctrina se divide: RODRÍGUEZ niega la indemnización, por entender que estas clases de error siempre las padecen ambas partes, de modo que también aquí las culpas se compensan; BARAONA la admite si solo una parte incurrió en el error, exigiendo que quien yerra no haya sido inducido dolosamente y que su error se explique por una negligencia inadmisibles, y que quien pide la indemnización esté de buena fe.

En la **incapacidad relativa**, procede si hubo inducción dolosa de la contraparte, pero no si el propio incapaz indujo con dolo a contratar (caso en que además pierde el derecho a la nulidad,

art. 1685); si el incapaz no obró con dolo, sí puede pedir la nulidad, y en tal caso la falta de diligencia de la contraparte, que no verificó adecuadamente sus condiciones, le impide a esta pedir indemnización: los casos posibles son solo dos, el menor de edad, donde basta identificarlo, y el pródigo interdicto, donde la consulta a los registros públicos es insoslayable. En la omisión de **formalidades habilitantes**, en principio no, salvo dolo de una parte. En la **falta de objeto**, BARAONA extiende por analogía el **art. 1814** a la falta o ilicitud de objeto o causa, mientras RODRÍGUEZ lo niega en toda nulidad absoluta por involucrar a ambas partes en la infracción de normas de orden público. En la **incapacidad absoluta**, el incapaz nunca resulta responsable, aunque sí puede serlo quien se aprovechó de él o fue negligente en advertir la incapacidad. Y en la **omisión de una solemnidad**, nadie puede alegar perjuicios, porque la ley se presume conocida por todos.

En síntesis, la indemnización es compatible con una demanda de nulidad, absoluta o relativa, exigiendo como mínimo que quien la pide esté de buena fe respecto del vicio, y que a la contraparte pueda atribuírsele culpa, sea por inducción dolosa, reticencia o negligencia. Sobre la **naturaleza de esta responsabilidad** la doctrina discute si es contractual (rechazada por la mayoría, porque la nulidad borra jurídicamente el contrato mismo), legal (RODRÍGUEZ) o extracontractual, con matices propios en la apreciación de la culpa, según la buena o mala fe de cada parte (posición de BARAONA y la mayoritaria).

5. LA CONVERSIÓN

Hay **conversión** cuando un acto inválido como tal se emplea para producir los efectos de otro acto cuyos requisitos esenciales sí reúne, porque hay razones para suponer que las partes, de haber sabido que el celebrado era nulo, habrían encaminado su voluntad al otro. Una letra de cambio que no cumple todos sus requisitos formales, por ejemplo, puede valer como reconocimiento abstracto de deuda; a la misma idea responde que la aceptación condicional se considere una nueva oferta (**art. 102 C. de Comercio**).

Distinta de esta conversión, basada en la voluntad hipotética de las partes, es la **conversión formal**, que opera automáticamente por disposición de la ley: el instrumento público defectuoso por incompetencia del funcionario o por un defecto de forma vale como instrumento privado si está firmado por las partes, salvo que se trate de un acto en que la ley exige el instrumento público como solemnidad insustituible por otra prueba (**art. 1701**).

CORTE SUPREMA, 3 DE DICIEMBRE DE 1921

Confirió valor de testamento verbal al dictado por la causante ante un notario público y tres testigos, sin que existieran al momento indicios de un fallecimiento inminente, pero que murió repentinamente antes de que el ministro de fe alcanzara a leer las disposiciones y ella a firmar el documento: se admitió la conversión de un testamento más solemne, frustrado por falta de firma, en uno menos solemne o privilegiado, el testamento verbal.

M. LA LESIÓN

1. CONCEPTO DOCTRINAL

En términos generales, la **lesión** es el perjuicio que experimenta una persona al ejecutar ciertos actos jurídicos, resultante de la desigualdad entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla: intereses excesivos en el préstamo, un precio exorbitante o irrisorio en la venta, una parte de las ganancias que no corresponde al aporte en la sociedad, o una indemnización desproporcionada al derecho renunciado en una transacción. Con mayor precisión, es el perjuicio pecuniario que sufre una parte en un **contrato oneroso conmutativo** (**arts. 1440 y 1441**), por la desproporción entre prestaciones que se miran como equivalentes. Por eso, doctrinalmente, no tiene cabida en los actos gratuitos (donde solo una parte sufre el gravamen) ni en los contratos aleatorios (donde el equivalente es una contingencia incierta).

Algunas legislaciones (el Código Civil alemán, **art. 138**; el Código Suizo de las Obligaciones, **art. 21**) exigen, además del desequilibrio objetivo, un componente subjetivo: que la lesión provenga de la explotación de la penuria, ligereza o inexperiencia del contratante lesionado. Otras se conforman con el solo desequilibrio objetivo.

2. LA LESIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO: ¿CONSTITUYE UN VICIO DEL CONSENTIMIENTO?

El **art. 1451** no menciona a la lesión entre los vicios del consentimiento, lo que ha generado discusión. Bajo un **criterio subjetivo**, la lesión sería un vicio del consentimiento: para algunos, uno autónomo (el apremio moral de la imperiosa necesidad de dinero que fuerza a un arbitrio ruinoso); para otros, un resultado específico del error, la fuerza o el dolo. Se le critica que introduce incertidumbre, al exigir determinar el efectivo valor de las prestaciones. Bajo un **criterio objetivo**, la lesión no tiene relación alguna con el consentimiento ni sus defectos, sino solo con una desigualdad de prestaciones que supera los márgenes tolerados por la ley. Un **criterio mixto**, en fin, la entiende como una desigualdad de prestaciones que, además, debe ser consecuencia de la necesidad, miseria, ligereza o inexperiencia de la víctima.

La doctrina nacional coincide, ampliamente, en que la lesión **no es un vicio del consentimiento**, salvo en el único caso de la aceptación de una herencia. Se apoya en que el **art. 1451** no la incluyó, a diferencia del Proyecto de 1853, que sí la trataba expresamente como vicio general del consentimiento en los contratos conmutativos (exigiendo que fuera *enorme*, esto es, que lo dado por una parte no llegara a la mitad de lo dado por la otra); en que BELLO se apartó en este punto de POTHIER; en que la lesión se establece en Chile con criterios puramente objetivos, y en que además se establece para contratos que ni siquiera son onerosos conmutativos, e incluso para actos que no son contratos; y en que opera únicamente en los casos que la ley expresamente señala, sin

que todos ellos se sancionen con nulidad relativa (la sanción propia de los vicios del consentimiento).

En el derecho comparado, italiano y alemán, la lesión sí constituye un vicio del consentimiento en general, pero siguiendo el criterio mixto: se exige no solo la desproporción de las prestaciones, sino también el componente subjetivo del estado de necesidad, ligereza o inexperiencia de la víctima. En esos ordenamientos, por eso, la lesión se acerca al error, la fuerza o el dolo, en cuanto supone el aprovechamiento de una situación de debilidad de la víctima por parte del otro contratante.

DATO DE GRADO

La tesis minoritaria de DUCCI: la lesión como error en la magnitud de las prestaciones

DUCCI sostiene que la lesión sí puede considerarse un vicio del consentimiento, incluido dentro del error sustancial: si la magnitud de las prestaciones es esencialmente distinta de lo creído, de forma que una no pueda mirarse como equivalente de la otra, habría error sobre la *calidad esencial* del objeto (**art. 1454**), entendido el objeto como la prestación (**art. 1460**). Invoca a su favor el **art. 1348**, que somete la partición a las reglas de los contratos y admite su rescisión por lesión, y el **art. 2458**, que en la transacción excluye de la nulidad solo el *error de cálculo*, lo que sugeriría que el error de magnitud (la lesión) sí formaría parte, como regla general, del error sustancial.

3. CASOS DE LESIÓN REGULADOS EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

El Código no regula la lesión de forma general y orgánica: no es una causal genérica de rescisión de los contratos onerosos conmutativos desproporcionados, sino que opera solo en los casos **taxativos** que la ley establece.

(i) Compraventa de bienes raíces.

Procede solo en las compraventas voluntarias de inmuebles que no sean pertenencias mineras (**arts. 1888, 1897** y **art. 77 Código de Minería**). El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa; el comprador, cuando el justo precio es inferior a la mitad del precio que paga, tomando el justo precio al tiempo del contrato (**art. 1889**). El comprador contra quien se pronuncia la rescisión puede, a su arbitrio, consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte; el vendedor, consentir en ella o restituir el exceso recibido sobre el justo precio aumentado en una décima (**art. 1890**): la sanción, en principio nulidad relativa, puede evitarla quien se benefició de la lesión. Lo particular no es solo esa posibilidad de enervar la nulidad ya pronunciada, sino que la propia ley reconoce como aceptable que el beneficiado por la lesión reciba, aun corrigiéndola, una prestación algo mayor a la estrictamente equivalente: por eso el margen del diez por ciento.

(ii) Permuta de bienes raíces.

Se le aplican las reglas de la compraventa que no se opongan a su naturaleza, incluida la lesión enorme (**art. 1900**), aunque no las de completar o restituir el precio, porque al intercambiarse dos especies o cuerpos ciertos no hay, propiamente, algo que completar.

(iii) Aceptación de una asignación hereditaria.

Puede rescindirse por lesión grave (la que disminuye el valor total de la asignación en más de la mitad) a causa de disposiciones testamentarias de que no se tenía noticia al aceptar (**art. 1234**). Es el único caso, excepcional, en que la lesión sí funciona como un verdadero vicio del consentimiento: recae sobre un acto unilateral y gratuito, exige un componente subjetivo (ignorar la disposición testamentaria, una variante del error) y el propio artículo la trata junto al dolo y la fuerza.

(iv) Partición de bienes.

Las particiones se anulan o rescinden como los contratos, y la rescisión por lesión se concede a quien fue perjudicado en más de la mitad de su cuota (**art. 1348**), aunque la partición puede ser un acto unilateral, bilateral o incluso un acto jurisdiccional (la hecha por un partidor). Los demás copartícipes pueden *atajar* la rescisión ofreciendo y asegurando el suplemento que falta a la cuota del perjudicado (**art. 1350**), incluso antes de que se falle la demanda.

(v) El mutuo.

El interés convencional no tiene más límite que el fijado por ley especial, salvo que exceda en una mitad al interés corriente al tiempo de la convención, caso en que el juez lo reduce a ese interés corriente (**art. 2206**; complementado por el **art. 8 de la Ley N° 18.010**, que tiene por no escrito el pacto que exceda el máximo convencional). Aquí, a diferencia de la compraventa, la sanción no es la nulidad relativa, sino la simple **reducción** del interés.

(vi) La anticresis.

Contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos (**arts. 2435 y 2436**): los intereses que estipulen las partes están sujetos, en caso de lesión enorme, a la misma reducción que en el mutuo (**art. 2443**).

(vii) La cláusula penal.

Cuando la obligación principal y la pena consisten ambas en una cantidad determinada del mismo género, la pena se rebaja en todo lo que exceda al duplo de la obligación, incluyéndola en él: así, si la obligación es de \$100 y la pena de \$300, la cláusula es lesiva en \$100, no en \$200 (se acepta que el duplo, \$200, ya incluye la obligación misma). En el mutuo, la pena se rebaja en lo que exceda al máximo convencional de interés, regla que en apariencia no cuadra con la del **art. 2206** (que ordena rebajar al interés corriente), pero que debe entenderse en el mismo sentido, sobre todo a la luz de la Ley N° 18.010. Y en las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado, queda a la prudencia del juez moderarla si parece enorme (**art. 1544**).

(viii) La hipoteca.

Un caso no siempre analizado como lesión: limitada la hipoteca a una suma determinada, esta nunca puede extenderse a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque se haya estipulado otra cosa, y el deudor tiene derecho a exigir su reducción a ese duplo, incluso tratándose de una cláusula de garantía general que cubre obligaciones indeterminadas (**art. 2431**).

EJEMPLO

Reducción de la hipoteca de garantía general al duplo

Un deudor tiene con un banco una deuda de \$30.000 recibidos en mutuo, más \$20.000 por sobregiros en cuenta corriente. Aunque la hipoteca de garantía general se haya estipulado sin límite, el deudor puede pedir que se limite a \$100.000, el duplo del importe conocido de la obligación principal (\$50.000).

4. SANCIÓN DE LA LESIÓN

No es siempre la misma. A veces es la **nulidad relativa o rescisión** del acto, evitable por el ganancioso completando o restituyendo la prestación deficiente en los términos que fija la ley, como en la compraventa; otras veces es solo la **reducción** de la estipulación lesiva a términos razonables, como en el mutuo o la cláusula penal. En síntesis: nulidad relativa, o reducción de la desproporción entre las prestaciones.

N. LA SIMULACIÓN

1. CONCEPTO

Hay simulación cuando la intención real de las partes de un contrato difiere de la voluntad declarada, sea porque no deseaban celebrar contrato alguno (**simulación absoluta**), sea porque deseaban celebrar uno distinto del declarado (**simulación relativa**). Avelino LEÓN la define como *aparentar una declaración de voluntad que no se desea, contando con la aquiescencia de la parte a quien esa declaración va dirigida*. El acto simulado, así, tiene una apariencia contraria a la realidad: o no existe en absoluto, o es distinto del que aparece.

Se diferencia de la **reserva mental**, en que el declarante, a sabiendas de que lo declarado no responde a su intención, guarda en secreto su verdadera voluntad: la simulación implica, a diferencia de ella, un *acuerdo* entre quien emite la declaración y su destinatario, que la reserva mental no tiene. Por necesitar ese acuerdo, la simulación solo cabe en los actos **bilaterales** y en los unilaterales **receptivos**, dirigidos a un destinatario determinado que debe conocer la declaración; la reserva mental, en cambio, al no requerir ninguna concurrencia ajena, es posible en cualquier acto jurídico.

2. LA SIMULACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

A diferencia de otros códigos civiles del siglo XX (el alemán de 1900, **art. 117**; el italiano de 1942, **arts. 1414 a 1417**; el etíope de 1960, **arts. 1991, 1994 y 2019**; el portugués de 1967, **arts. 240 a 243**; el boliviano de 1975, **arts. 543 a 545**; el peruano de 1984, **arts. 190 a 194**; y el paraguayo de 1985, **arts. 305 a 310**), el nuestro no regula la simulación ni emplea esa palabra en ninguna disposición. La doctrina y jurisprudencia nacionales, unánimes en reconocer en la simulación ilícita un obrar contrario a derecho, la han construido principalmente a partir del **art. 1707**: *las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efectos contra terceros; tampoco las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz*.

La simulación también interesa al derecho penal (**art. 471 N° 2 del Código Penal**, que castiga a quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado, exigiendo un perjuicio patrimonial efectivo y dolo directo; y el **art. 466**, que desde la Ley N° 20.720 de 2014 castiga a la *persona deudora*, definida en el **art. 2° N° 25** de esa misma ley, que se alza con sus bienes o que otorga contratos simulados en perjuicio de sus acreedores) y al derecho tributario, donde el **art. 4 quáter del Código Tributario** la reconoce como una hipótesis de elusión, aplicando los impuestos a los hechos efectivamente realizados, con independencia del acto simulado.

3. SIMULACIÓN LÍCITA

La simulación no es, en sí misma, un obrar contrario a derecho: solo lo es en la medida que se pretenda, con ella, perjudicar a terceros. La doctrina y la jurisprudencia distinguen así entre simulación lícita e ilícita.

Como sostiene ALCALDE, si bien es cierto que toda simulación, por el hecho de ser tal, persigue engañar a terceros, ello no la transforma necesariamente en ilícita o ilegítima, ya que las partes pueden obligarse como quieran y, en tal sentido, realizar en secreto aquello que también les sería permitido realizar públicamente. En esta línea, JOSSERAND advierte que el móvil que se persiga será decisivo para calificar el acto, pues habrá *mentiras jurídicas* condenables y a veces criminales, otras que serán solo pecados veniales y algunas, indiferentes a la moral y aun motivadas por exceso de delicadeza o de escrúpulos de conciencia.

CORTE SUPREMA, 30 DE MARZO DE 2015

La simulación tiene causa y es la que, también en doctrina, se denomina *causa simulandi*, entendiéndose por tal el interés que lleva a las partes a hacer un contrato simulado, el motivo que induce a dar apariencia a un negocio jurídico que no existe o presentarlo en forma distinta a la que corresponde: es el porqué del engaño.

La simulación lícita es, de hecho, muy habitual: ocurre en la inmensa mayoría de las compraventas de inmuebles del país, donde la escritura pública declara que el precio se paga al contado, mientras una *contraescritura privada* (las llamadas *instrucciones notariales*) deja los documentos representativos del precio en poder del notario, quien solo los entrega al vendedor una vez que el inmueble se inscribe a nombre del comprador. Lejos de perjudicar a terceros, esta práctica los protege y facilita la libre circulación de los bienes, y está amparada por el propio **art. 1707** en relación con los **arts. 1491 y 1876** (que hacen depender la resolución frente a terceros de que la condición conste en el título inscrito). Cumple así una **doble finalidad**: por un lado, al no figurar ningún saldo de precio pendiente en el título que se inscribe, ningún tercero queda expuesto a la resolución por la condición resolutoria tácita implícita en la compraventa; por el otro, el comprador tiene la tranquilidad de que el precio no se liberará al vendedor si, por cualquier motivo, el inmueble no llega a inscribirse a su nombre.

CORTE SUPREMA, RDJ, T. XXXVIII, SECC. 2ª, 1936, P. 17

La simulación, no mediando perjuicio de terceros, es perfectamente lícita en nuestro derecho: así lo demuestra el **art. 1707**, que da valor entre las partes a las escrituras privadas hechas para alterar lo pactado en una escritura pública.

CORTE SUPREMA, RDJ, T. LXXXVIII, SECC. 1ª, 1991, P. 14

Bien pueden las partes comparecientes en un instrumento público, compenetradas del alcance de sus palabras, convenir en cláusulas que no correspondan a la realidad, sin alterar con ello la validez del instrumento.

Para fijar los **efectos de la simulación lícita** hay que distinguir. Entre las **partes**, que no pretenden engañarse a sí mismas, rige su voluntad real por sobre la declarada: el acto simulado no existe entre ellas, y cualquiera puede demandar que se declare la vigencia de lo pactado en la contraescritura. Respecto de los **terceros de buena fe**, que ignoran la simulación, el **art. 1707** los protege haciéndoles inoponible la contraescritura, de modo que pueden invocar a su favor el acto público o simulado; pero también pueden, si les conviene, invocar el acto disimulado una vez que la simulación llega a su conocimiento (a los acreedores de un deudor que fingió vender bienes a un amigo les conviene, por ejemplo, hacer valer que esos bienes nunca salieron de su patrimonio). Cuando distintos terceros tienen intereses contrapuestos, la doctrina entiende que las consecuencias de la simulación alegada por unos no afectan a los que estaban de buena fe. Frente al **tercero de mala fe**, que conocía la simulación, las partes sí pueden hacerla valer, y ese tercero debe pasar por los efectos del acto disimulado.

4. LA SIMULACIÓN ILÍCITA

4.1. Requisitos

Es, según la Corte Suprema (fallo de 30 de marzo de 2015, reiterado en fallo de 30 de marzo de 2017), la que perjudica o tiene la intención de perjudicar a terceros, o viola o tiene la intención de violar la ley. Sus requisitos son: la **disconformidad** entre la voluntad real y la declarada; la **deliberación y conciencia** de esa disconformidad (lo que distingue la simulación del error, donde también hay disconformidad, pero sin esa conciencia); el **concierto entre las partes**, esto es, el acuerdo de que lo manifestado es solo apariencia, sea porque lo convenido es otra cosa o la nada misma; y, derivada de todo lo anterior, la **intención de engañar** a terceros.

4.2. Clases de simulación: absoluta y relativa

Hay **simulación absoluta** cuando realmente no se quiere celebrar ningún acto jurídico, y solo se finge uno: el deudor que finge vender bienes a un amigo para sustraerlos de sus acreedores. El acto tiene toda la apariencia de válido, pero en realidad no existió ninguno; establecida la simulación, el acto se desvanece y queda, para parte de la doctrina, inexistente, o absolutamente nulo para otra parte.

Hay **simulación relativa** cuando aparentemente se celebra un acto, pero en realidad se quiere celebrar otro. Existen entonces dos actos: el *ostensible o simulado*, que las partes fingen realizar, y el *oculto o disimulado*, el que efectivamente quieren y que queda en secreto, plasmado en la contra-declaración. La diferencia entre ambos puede residir en la **naturaleza** del acto (una donación disimulada bajo una compraventa aparente), en el **objeto** (declarar un precio de un millón cuando en realidad es de dos, o contratar en el acto ostensible a una empleada de casa particular cuando en el acto secreto se pacta un objeto ilícito), o en los **sujetos**: A finge vender a B, pero en realidad vende a C, en lo que se llama *interposición ficticia de persona* (C, el contratante efectivo, es el *interponente*; B, quien aparece en su lugar, el *interpuesto*, prestanombre o testaferro). El acto simulado se desvanece por carecer de causa real o tener una falsa; el disimulado, si reúne todos sus requisitos de existencia y validez, produce válidamente sus efectos, y si no, es nulo.

4.3. Sanción civil a la simulación ilícita

Los terceros perjudicados por la simulación ilícita están legitimados para pedir la ineficacia del acto simulado y que se declare la voluntad real de las partes. La doctrina entiende que la simulación absoluta importa **falta de causa real**, y la relativa, **causa u objeto ilícito**, de modo que el acto simulado adolece de **nulidad absoluta** (**arts. 1467 y 1681**). Parte de la doctrina postula, además, una acción autónoma de simulación, destinada solo a establecer la voluntad real de las partes, que en la práctica suele ejercerse subsidiariamente a la nulidad absoluta.

Esta regla cede cuando el legislador establece una sanción especial, distinta de la nulidad, conforme al **art. 10**. Es el caso del **art. 1768**: el cónyuge que dolosamente oculta o distrae una cosa de la sociedad conyugal pierde su porción en ella y debe restituirla doblada. Hay **distracción** cuando el cónyuge sustrae un bien social para apropiárselo exclusivamente, en perjuicio del otro, de sus herederos o de los acreedores sociales; y **ocultación** cuando, con el mismo objeto, esconde o hace desaparecer el bien, o silencia o niega su existencia pese a conocerla o tenerlo en su poder. Es una sanción que la jurisprudencia ha aplicado a las compraventas simuladas que un cónyuge celebra para defraudar los derechos del otro en la liquidación de la sociedad conyugal (RDJ, t. 55, sec. 1ª, p. 188).

4.4. Consideraciones probatorias

Como la simulación es prácticamente imposible de acreditar por prueba directa (nadie deja testimonios accesibles de sus propias maniobras), cobra especial relevancia la **prueba de presunciones**. Ya en 1918 la Corte Suprema resolvió que los terceros pueden valerse de todos los medios que la ley permite para acreditar el fraude, incluidas las presunciones.

C. DE CONCEPCIÓN, 29 DE AGOSTO DE 1997 (CONFIRMADA POR LA CORTE SUPREMA, 20 DE OCTUBRE DE 1997)

La simulación, como divergencia psicológica que es de la intención de los declarantes, se sustrae a la prueba directa: se induce, se infiere del ambiente en que ha nacido el contrato, de las relaciones entre las partes, del contenido de aquel y de las circunstancias que lo acompañan, siendo por ende una prueba indirecta, de indicios y de conjeturas, que es lo que verdaderamente hiere a fondo la simulación, porque la combate en su propio terreno.

CORTE SUPREMA, FALLOS DE 30 DE MARZO DE 2015 Y 30 DE MARZO DE 2017

La generalidad de la doctrina y jurisprudencia ha deducido dos consecuencias probatorias: que la valoración de los distintos medios de prueba debe efectuarse algo alejada de la rigurosidad que en algunos ordenamientos impone la tarifa legal, quedando siempre márgenes de apreciación prudencial que el tribunal debe emplear particularmente en esta materia; y que, tratándose de simulación, la prueba de presunciones se eleva a una consideración primordial y de decisiva influencia, como única actitud equitativa para conceder al demandante una opción real de éxito.

O. LA INOPONIBILIDAD

1. CONCEPTO

La inoponibilidad es la sanción legal que consiste en el impedimento de hacer valer, frente a ciertos terceros, un derecho nacido de un acto jurídico válido, o de uno nulo, revocado o resuelto: esos terceros pueden oponerse a que les alcancen los efectos, favorables o desfavorables, de ese acto o de su ineficacia. Quienes pueden alegarla son, por lo general, los **terceros relativos** (los que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes), y no los **terceros absolutos**, completamente extraños al acto, salvo excepciones puntuales como la venta de cosa ajena.

El Código no regula la inoponibilidad de forma orgánica, y en su texto original ni siquiera empleaba esa palabra, aunque contempla numerosas hipótesis con fórmulas como *no valdrán respecto de* o *no producirán efectos contra terceros*. Leyes posteriores sí incorporaron el término expresamente, como en los actuales **arts. 225 inciso final, 246 y 1757 inciso segundo**.

2. INOPONIBILIDADES DE UN DERECHO NACIDO DE UN ACTO JURÍDICO VÁLIDO

Los múltiples casos que la ley contempla se agrupan en dos grandes categorías: de **forma**, cuando la formalidad omitida no se exige para la constitución del acto sino para que sus efectos puedan oponerse a terceros; y de **fondo**, cuando los efectos del acto hieren injustamente los derechos de terceros.

2.1. Inoponibilidades de forma

(i) Por omisión de formalidades de publicidad.

Destinadas a que los terceros conozcan un acto o un hecho jurídicamente relevante. Casos: las contraescrituras públicas que alteran una escritura pública no producen efectos contra terceros si no se toma razón de su contenido al margen de la escritura matriz y del traslado en cuya virtud obró el tercero (**art. 1707** inciso 2º; el inciso 1º, sobre contraescrituras *privadas*, nunca produce efectos contra terceros, precisamente por ser privada. Algunos autores clasifican este último caso como una *inoponibilidad por clandestinidad*, de fondo, por tratarse de actos celebrados ocultamente que los terceros no pudieron conocer; pero esa clasificación es discutible, porque exigiría acreditar un ánimo de ocultamiento o mala fe de los otorgantes que la norma no pide: en ambos incisos el **art. 1707** se refiere a cuestiones estrictamente formales, propias del título que regula los instrumentos y su valor probatorio); la cesión de un crédito personal no produce efecto contra el deudor ni terceros mientras no se notifica al deudor o este la acepta (**art. 1902**); la sentencia que declara una prescripción no vale contra terceros sin su competente inscripción (**art. 2513**); y la interdicción por disipación no es oponible a terceros mientras la sentencia no se inscriba en el Registro de

Interdicciones (**art. 447**), como tampoco lo son los nuevos acuerdos sobre patria potestad o cuidado personal mientras no se subinscriban (**arts. 246 y 225** inciso final).

(ii) Por falta de fecha cierta.

La fecha de un instrumento privado, susceptible de ser alterada por las partes, no hace fe contra terceros mientras no ocurra un hecho que se la dé con certeza: el fallecimiento de alguno de sus firmantes, su copia en un registro público, su presentación en juicio, o que un funcionario competente tome razón de él o lo inventaríe (**art. 1703**); también desde su protocolización (**art. 419 COT**).

2.2. Inoponibilidades de fondo

(i) Por falta de concurrencia.

El acto no puede oponerse a quien no concurrió a él como parte. El caso típico es la venta de cosa ajena, válida pero inoponible al verdadero dueño (**art. 1815**), igual que el arrendamiento (**art. 1916**) o la prenda (**art. 2390**) de cosa ajena. Otro caso: el marido que, sin la autorización de su mujer, da en arriendo por más de cinco años los bienes raíces urbanos sociales o de ella (ocho, si son rústicos), solo obliga el contrato por ese plazo legal, y esa inoponibilidad puede hacerla valer la mujer, sus herederos o cesionarios (**arts. 1749, 1756 y 1757**).

(ii) Por falta de poder de representación, o por exceder sus límites.

Los actos ejecutados por quien carece de poder para representar a otro, o que se excede de su encargo, le son inoponibles: las obligaciones que contrae el socio administrador excediendo sus facultades son inoponibles a la sociedad (**art. 2079**), y lo mismo ocurre, en su caso arquetípico, con el mandatario que obra sin poder o extralimitándose (**arts. 2160 y 2154**), materia que se profundiza al estudiar la representación.

(iii) Por fraude.

Son inoponibles los actos ejecutados en fraude de los derechos de terceros. A diferencia del dolo, vicio del consentimiento que opera entre las partes para obtenerlo mediante engaño, el fraude es una maniobra de mala fe dirigida a perjudicar a terceros. En esta causal se funda la **acción pauliana**, que permite a los acreedores perjudicados pedir la rescisión de los actos de su deudor cumpliendo los requisitos legales (**art. 2468**), y la inoponibilidad de la renuncia del usufructo hecha en fraude de los acreedores del usufructuario (**art. 803**); en la misma línea, tanto la antigua Ley de Quiebras como la actual Ley de Reorganización y Liquidación contemplan acciones revocatorias especiales fundadas en la misma idea. Cabe preguntarse si, más allá de estos casos especialmente reglados, el ordenamiento sanciona de modo general el acto fraudulento, en particular el **fraude a la ley**, figura que se analiza a continuación.

(iv) Por lesión de derechos adquiridos.

Los efectos de un acto no pueden oponerse a terceros que adquirieron derechos sobre las mismas cosas. Si el decreto de posesión definitiva de los bienes de un desaparecido se rescinde por su reaparición, subsisten las enajenaciones, hipotecas y demás derechos reales legalmente constituidos sobre ellos por terceros (**art. 94 N° 4**).

(v) Por lesión de las asignaciones forzosas.

Si el testador nada asigna a quienes la ley obliga a favorecer (como sus hijos), el testamento no es nulo, pero les es inoponible en cuanto los perjudica, y ellos pueden pedir su reforma (**art. 1216**).

3. INOPONIBILIDADES DE UN DERECHO NACIDO DE LA NULIDAD O RESOLUCIÓN DE UN ACTO JURÍDICO

Hay casos excepcionales en que la nulidad de un acto no puede hacerse valer contra terceros, que tienen derecho a que el acto se mire, respecto de ellos, como perfectamente válido: la nulidad de una sociedad de hecho es inoponible a los terceros de buena fe (**art. 2058**), como lo es, en materia mercantil, la nulidad de una sociedad colectiva por falta de solemnidades frente a los terceros interesados en su existencia (**art. 356 inc. 3° C. de Comercio**). Del mismo modo, aunque la **resolución** opera por regla general con efecto retroactivo, la judicialmente declarada es inoponible a los terceros de buena fe (**arts. 1490 y 1491**), y en la donación, la resolución, rescisión o revocación son, salvo excepciones expresas, inoponibles a los terceros poseedores de los bienes donados (**art. 1432**).

4. MANERAS DE HACER VALER LA INOPONIBILIDAD

El juez no puede declararla de oficio: debe alegarla quien está favorecido por ella. Generalmente se hace valer como **excepción**, opuesta por el tercero contra quien se pretende hacer valer el acto; en contados casos, como **acción**, según ocurre con la acción pauliana.

5. DIFERENCIAS ENTRE LA NULIDAD Y LA INOPONIBILIDAD

La **nulidad** ataca la validez del acto mismo, privándolo de eficacia tanto respecto de las partes como de los terceros; la **inoponibilidad** deja el acto válido, y solo priva de efectos a ciertos terceros de buena fe. La nulidad protege a las partes del acto; la inoponibilidad, a esos terceros. Y mientras la nulidad, de orden público, no puede renunciarse anticipadamente, la inoponibilidad, sanción de orden privado establecida a favor de los terceros, sí puede serlo.

P. EL FRAUDE A LA LEY

1. CONCEPTO

El fraude a la ley, con raíces en el Derecho Romano pero desarrollado sobre todo desde el siglo XIX, es una hipótesis especial de ineficacia: sanciona actos que, aunque en apariencia lícitos, tienen por real finalidad eludir la aplicación de una ley. El autor se vale del negocio jurídico como medio para eludir una norma imperativa.

EJEMPLO

Los casos clásicos del fraude a la ley

En el *Caso Bauffremont*, una condesa belga obtuvo en Francia (país que no admitía el divorcio) la separación personal de su marido; se trasladó a Alemania, que sí lo permitía, se naturalizó alemana y volvió a casarse. La Corte de Casación francesa declaró nulo el segundo matrimonio y fraudulento el cambio de nacionalidad, por entender que su único fin fue sustraerse de la ley francesa. En el *Caso Fritz Mandel*, un austriaco nacionalizado argentino, con domicilio y bienes en Argentina, al ser diagnosticado de una enfermedad grave regresó a Austria, recuperó su nacionalidad de origen y testó de un modo contrario a lo que exigía la ley argentina: los tribunales resolvieron que la sucesión debía regirse igualmente por la ley argentina, porque el cambio de nacionalidad y domicilio se hizo en fraude a sus normas imperativas.

Para **COVIELLO**, el acto es contrario a la ley cuando la voluntad del particular se enfrenta directa y abiertamente con ella, y está en fraude de la ley cuando, respetándola aparentemente, la viola en su espíritu aunque respete su letra. Para **LARENZ**, hay negocio en fraude cuando las partes buscan la finalidad de un negocio prohibido valiéndose de otro que no lo está. En Chile, **VIAL** lo describe como procedimientos en sí lícitos, o maniobras jurídicas con apariencia de legalidad, que permiten realizar lo que la ley prohíbe o dejar de hacer lo que ordena. **ALCALDE**, más recientemente, lo resume así: el acto o conducta fraudulenta tiene la apariencia de la licitud, aunque sus resultados sean, en definitiva, antijurídicos, y constituye una infracción encubierta, pero infracción al fin y al cabo, del ordenamiento.

2. EL FRAUDE A LA LEY EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL

A diferencia de códigos más modernos (como el argentino de 2014, cuyo **art. 12** lo regula expresamente), el nuestro no contempla un reconocimiento general del fraude a la ley. Sin perjuicio de ello, no hay controversia en que el Código de BELLO se inspira en el principio *fraus omnia corrumpit* (el fraude todo lo corrompe). Como expresa DOMÍNGUEZ, a esa conclusión se puede lle-

gar tanto desde la moral como desde el texto positivo de la ley: desde el iusnaturalismo, el valor de un acto es inseparable de su fin desde el instante en que este se establece, si es ilícito. Un fin lícito no legitima un acto ilícito, el fin no justifica los medios; pero un fin ilícito vicia el acto intrínsecamente lícito, y nadie puede aprovecharse de la bondad propia de un acto para usarlo con un fin diverso al que le es propio. Ya el **Mensaje** del propio Código alude, en su primer párrafo, a *los abusos que introduce la mala fe, fecunda en arbitrios para eludir precauciones legales*. Desde el texto positivo, el principio aparece de forma constante en normas puntuales: el **art. 11**, que manda aplicar la ley aunque se alegue ausencia de fraude en el caso concreto; el **art. 219**, sobre el fraude de falso parto; el **art. 497 N° 12**, que inhabilita para ser guardador a quien por fraude fue condenado a indemnizar a su pupilo; el **art. 539 N° 2**, que establece como causal de remoción del guardador el fraude en el ejercicio de su cargo, reiterada en el **art. 541**; el **art. 555**, que a propósito de las asociaciones alude al *delito de fraude*; el **art. 706**, que exige para la posesión de buena fe la convicción de haber adquirido el dominio por medios exentos de fraude; el **art. 803**, sobre la renuncia fraudulenta del usufructo; el **art. 1578 N° 3**, que anula el pago hecho al deudor insolvente en fraude de sus acreedores; y el **art. 2317**, que hace solidaria la responsabilidad de quienes cometen un fraude en conjunto, entre otras.

Normas más recientes sí lo reconocen expresamente: el **art. 83 de la Ley de Matrimonio Civil** (2004) desconoce valor a las sentencias de divorcio obtenidas en fraude a la ley chilena (pensada, precisamente, para casos como el *Caso Bauffremont*): se entiende que hay fraude cuando el divorcio se declaró bajo una jurisdicción distinta de la chilena pese a que los cónyuges tuvieron domicilio en Chile durante cualquiera de los tres años anteriores a la sentencia que se pretende ejecutar (si ambos aceptan que su convivencia cesó al menos ese lapso), o durante cualquiera de los cinco años anteriores (si discrepan sobre el plazo de cese). Y el **art. 4 ter del Código Tributario** (2014) sanciona, bajo el nombre de *abuso de formas jurídicas*, los actos que evitan el hecho gravado sin producir efectos jurídicos o económicos relevantes distintos de los tributarios.

EJEMPLO

Interposición de un tercero para burlar la prohibición de compraventa entre cónyuges

Como señala **VODANOVIC**, hay fraude a la ley cuando, para eludir la prohibición del **art. 1796** de vender entre cónyuges no separados judicialmente, uno de ellos vende un bien a un tercero, quien acto seguido lo vende al otro cónyuge: ambas compraventas, aisladamente consideradas, son perfectamente válidas, pero combinadas persiguen precisamente el resultado que la ley prohíbe, por lo que son susceptibles de anularse. La Corte Suprema así lo ha reconocido.

3. REQUISITOS PARA QUE UN OBRAR SEA EN FRAUDE A LA LEY

(i) Los actos deben ser, en sí mismos, lícitos.

El conjunto de actuaciones debe ajustarse, al menos en apariencia, al ordenamiento. FERRARA identifica tres métodos habituales: el empleo de un negocio distinto o una combinación de actos; la modificación de las condiciones de hecho; y la interposición de personas.

(ii) Debe existir una ley defraudada.

Los actos no contravienen la ley abiertamente, sino que frustran de modo indirecto la finalidad de una norma prohibitiva o imperativa, alcanzando un resultado práctico idéntico o equivalente al que ella reprueba. La doctrina civil suele citar como ejemplos la separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal como forma de evadir el derecho de prenda general de los acreedores, o la constitución de sociedades para realizar actividades que a sus socios, como personas naturales, no les sería lícito ejecutar.

(iii) Un elemento intencional.

Se discute si es indispensable un obrar malicioso o si basta un criterio objetivo; una posición intermedia exige, al menos, algún grado de culpabilidad (dolo directo, eventual, o incluso simple culpa), sin llegar a exigir una intención manifiesta de burlar la ley.

4. FRAUDE A LA LEY Y FIGURAS AFINES

4.1. Fraude a la ley y simulación

Comparten semejanzas: ambos buscan crear una apariencia de legitimidad con un efecto engañoso, y ambos pretenden eludir una disposición legal. Pero para la mayoría de la doctrina son figuras autónomas: la simulación es solo una apariencia, un velo sobre la realidad; el fraude a la ley, en cambio, consiste en actos reales, efectivamente queridos y realizados, combinados de tal modo que, siendo lícitos en sí, permiten burlar la ley. DOMÍNGUEZ agrega que la simulación no es de por sí ilícita (existe la simulación lícita), mientras que el negocio fraudulento, que busca sustraer a su autor del alcance de una norma obligatoria, nunca es neutro ante el derecho. ALCALDE matiza esta distinción mayoritaria: aunque las diferencias propuestas entre fraude a la ley y simulación son correctas desde una perspectiva científica o académica, no gozan de la misma consistencia si se atiende a la realidad de los hechos, porque el acto en fraude a la ley también persigue un fin distinto del que naturalmente le corresponde, creando una apariencia tras la cual se esconde una infracción legal, del mismo modo en que el acto simulado no manifiesta el verdadero querer interno de las partes.

4.2. Fraude a la ley y abuso del derecho (en su variante de abuso de formas jurídicas)

El abuso del derecho es una manifestación del principio de la buena fe como límite al ejercicio de los derechos subjetivos: quien lo traspassa obra de modo abusivo e ilícito. FERREIRA explica que la buena fe indica un límite, algo que no debe sobrepasarse sin provocar consecuencias negativas,

representado por el respeto a los demás y el cumplimiento de las normas que la buena fe impone; DIEZ-PICAZO agrega que el ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe no solo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva o función económica o social para la cual fue atribuido a su titular, sino también cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal según las reglas que la conciencia social impone en el tráfico jurídico; y BARROS, en Chile, la resume como aquel núcleo de sentido que subyace a las normas atributivas de derechos, mostrándose en los límites que la norma no expresa pero da por supuestos. Existe un amplio catálogo de conductas que la doctrina califica como abuso del derecho: el ejercicio de un derecho con el solo propósito de causar daño, la desproporción extrema entre el interés del titular y el efecto negativo que produce en otro, la conducta contraria a los actos propios, el ejercicio de un derecho adquirido de mala fe, y la desviación del fin de un derecho potestativo. Se exige siempre, según la doctrina mayoritaria, algún elemento subjetivo (dolo o culpa). Una variante suya, de especial relevancia tributaria, es el *abuso de formas jurídicas*, hoy reconocido en el **art. 4 ter del Código Tributario**. La doctrina discute si fraude a la ley y abuso del derecho son figuras similares, si están en relación de género a especie, o si son institutos distintos. El abuso del derecho, en sus hipótesis ordinarias, consiste en el ejercicio indebido de un derecho subjetivo concreto que perjudica a quien debe soportarlo; en el abuso de formas jurídicas, en cambio, al igual que en el fraude a la ley, lo que se abusa no es un derecho subjetivo frente a otra persona determinada, sino algo más genérico, la autonomía privada misma. En esa línea, BARROS los acerca al señalar que existe *abuso de la autonomía privada* cuando, para evitar la aplicación de una norma de orden público, se realizan actos formalmente lícitos que conducen al efecto económico que la ley pretendía impedir, siendo el fraude a la ley un tipo de esa desviación del fin en el ejercicio de una potestad.

5. SANCIÓN AL FRAUDE A LA LEY

La causal particular de ineficacia varía según la hipótesis legal: algunas normas declaran el acto fraudulento **inoponible** (**arts. 803 y 1792-24**), otras derechamente lo declaran **nulo** (**art. 1578 N° 3**), y otras reconocen la **indemnización de perjuicios** como respuesta (**arts. 1662 y 2317**). A falta de una sanción común, la doctrina discute la que corresponde a los casos no normados expresamente: para DOMÍNGUEZ, la **inoponibilidad**, porque esa sanción restituye la vigencia de la norma eludida sin ir más allá, dejando el acto válido pero sin efecto frente a quien puede alegarla; para otros, la **nulidad absoluta**, por asimilar el acto a uno prohibido por la ley o de causa ilícita, en la línea del **art. 1344 del Código italiano**, que declara ilícita la causa del contrato que sirve para eludir una norma imperativa.

En la práctica, conviene distinguir. Si se concibe la causa con criterio objetivo, el acto que tuvo por causa eludir una ley imperativa cae dentro de la **nulidad absoluta** por causa ilícita, conforme al **art. 10**. Tratándose específicamente del **fraude a los acreedores**, el espíritu general de la legislación (**arts. 803, 1792-24 y, en especial, 2468**, que consagra la acción pauliana) apunta a la **inoponibilidad** para los actos anteriores a la apertura de un concurso; solo una vez abierto este, y por el

efecto de desasimiento que traspasa la administración de los bienes del deudor a un tercero, los actos de enajenación quedan derechamente prohibidos por la ley y su sanción es la nulidad (**arts. 1578 N° 3 y 2467**). En cualquier caso, tanto en el fraude a la ley como en el fraude a los acreedores, siempre puede exigirse la responsabilidad civil del autor del fraude y la indemnización de los perjuicios causados (**arts. 1662 y 2317**).

Q. OTRAS CAUSALES DE INEFICACIA

Estas causales son objeto de un estudio más profundo en otros ramos del derecho civil, por lo que aquí solo se las presenta brevemente. La ineficacia puede darse en relación con las partes o con los terceros, y puede ser originaria o sucesiva.

1. LA SUSPENSIÓN

Hay suspensión cuando los efectos del acto quedan subordinados a la ocurrencia de un hecho que todavía no se ha verificado: una condición suspensiva fijada por las partes, o una condición legal (*condictio iuris*), un hecho que la propia ley exige como supuesto para que el acto produzca efectos. La muerte del testador es una condición legal para el testamento, que permanece inmóvil hasta entonces; el matrimonio lo es para las capitulaciones matrimoniales, que solo valen entre las partes y respecto de terceros desde su celebración y su subinscripción dentro de los treinta días siguientes (**art. 1716** inciso 1°). La suspensión es transitoria mientras la condición pueda todavía cumplirse, pero puede volverse definitiva si ya es seguro que no se cumplirá, como cuando uno de los esposos muere antes del matrimonio proyectado.

2. LA RESOLUCIÓN

Es la ineficacia de un acto por un hecho posterior a su celebración que hace cesar los efectos ya producidos. Puede deberse a un hecho futuro e incierto al que las partes subordinan la extinción de un derecho (**condición resolutoria ordinaria**: un padre presta en comodato una casa a su hijo hasta que este se traslade a Europa), o al incumplimiento de una de las partes de un contrato bilateral (**condición resolutoria tácita**), que faculta a la parte diligente para pedir, a su arbitrio, la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios en ambos casos (**art. 1489**).

3. LA RESCILIACIÓN

Es un modo de extinguir las obligaciones que se produce cuando las partes, capaces de disponer libremente de lo suyo, acuerdan dejar sin efecto el contrato del que emanan (**art. 1567** inciso 1°). Por su propia naturaleza, no puede afectar a los terceros: el acuerdo les es inoponible, *res inter alios acta*.

4. LA REVOCACIÓN

Es una declaración de voluntad unilateral que retracta un acto jurídico precedente, incluso bilateral, cuando la ley lo permite: el testamento es esencialmente revocable, aunque no todo acto unilateral lo es (la ratificación del mandante al obrar extralimitado de su mandatario, una vez conocida

por sus destinatarios, es irrevocable). Los contratos son, por regla general, irrevocables: solo pueden dejarse sin efecto por mutuo consentimiento de ambas partes (mutuo disenso), salvo que la ley autorice expresamente su término por la voluntad de una sola, como ocurre con la revocación del mandato por el mandante (**art. 2163**).

5. EL DESISTIMIENTO UNILATERAL

Es el término de la relación contractual decidido por una parte y comunicado a la otra, ejercitable solo por excepción, cuando la ley lo establece o las partes lo pactan, típicamente en contratos de tiempo indeterminado o de ejecución continuada, como el desahucio en el arrendamiento o el contrato de trabajo. Suele exigirse un aviso previo con cierta anticipación, y a veces se pacta una multa o arras penitenciales como contraprestación. Se distingue de la revocación en que esta busca, primero, borrar el acto jurídico originario, desapareciendo sus efectos mediatamente (como la revocación de una donación por ingratitud del donatario); el desistimiento, en cambio, no cuestiona el acto, sino que disuelve la relación de inmediato y solo hacia el futuro (*ex nunc*), sin retroactividad (*ex tunc*).

6. LA CADUCIDAD

El término admite varios significados: la pérdida de un derecho por no haberse ejercido dentro del plazo fijado por la ley o las partes (lo que los franceses llaman *forclusion* y los italianos, *decadenza*); la extinción de una relación jurídica por hechos sobrevinientes, con o sin efecto retroactivo según el caso (*déchéance* en Francia, *caducità* en Italia); y, más específicamente, la ineficacia de un acto que se produce por el solo ministerio de la ley a causa de un hecho sobreviniente, como los testamentos privilegiados, que caducan sin necesidad de revocación en los casos que la ley prevé (**art. 1212** inciso 2°): el testamento verbal otorgado a bordo de un buque de guerra caduca si el testador sobrevive al peligro (**art. 1053**), y las donaciones revocables caducan por la sola muerte del donatario antes que el donante (**art. 1143**).

Boetsch cierra este catálogo en la caducidad; las tres causales que siguen (terminación, renuncia y muerte) no están tratadas en este tramo del libro. Se incluyen aquí porque forman parte de la clasificación de causales de ineficacia de **BOZZO E IBARRA**, quienes las tratan junto con las anteriores en su cuadro comparativo de ineficacia jurídica.

7. LA TERMINACIÓN

A diferencia de la resolución, la terminación no opera retroactivamente: solo priva de efectos al acto hacia el futuro, dejando intactos los ya producidos. Es la ineficacia propia de los contratos de **tracto sucesivo** (el arrendamiento, la sociedad), donde retrotraer lo ya cumplido, como los meses

de arriendo ya gozados o el tiempo ya trabajado en común, sería impracticable o derechamente injusto.

8. LA RENUNCIA

Es la dejación unilateral de un derecho por su titular, admitida excepcionalmente en ciertos actos, como el mandato o la sociedad (**art. 2163**). Por regla general, solo produce efectos una vez que la otra parte está en condiciones razonables de resguardar sus propios intereses frente al término de la relación: quien renuncia intempestivamente, sin dar tiempo a la contraparte para adoptar los resguardos necesarios, puede quedar obligado a indemnizar los perjuicios que esa renuncia le cause.

9. LA MUERTE

La muerte de una de las partes puede volver ineficaces los actos y contratos celebrados en consideración a su persona (*intuito personae*), como el mandato, que expira por la muerte del mandante o del mandatario (**art. 2163**), la sociedad, que se disuelve por la muerte de cualquiera de los socios salvo pacto en contrario, o el comodato, cuando se prestó en atención a la persona del comodatario.

R. LA REPRESENTACIÓN

1. CONCEPTO

Los actos jurídicos pueden celebrarse directamente por su autor o por medio de otra persona dotada de poder: la **representación**, definida como la relación jurídica en cuya virtud una persona (el representante) tiene el poder de concluir actos jurídicos en lugar e interés de otra (el representado), de modo que, obrando dentro de los límites de ese poder, los efectos del acto se producen inmediatamente y únicamente en el representado. El acto se celebra por el representante, pero sus efectos se radican directamente en la esfera del representado. El **art. 1448** dispone que lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.

2. UTILIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

Es de gran utilidad práctica: es el único medio de suplir la falta de voluntad de los absolutamente incapaces, cuyos representantes legales actúan en su reemplazo; en los incapaces relativos, sus representantes sustituyen su voluntad o cooperan con ella, autorizándolos a actuar por sí mismos. También es muy útil la representación voluntaria, cuando una persona capaz está impedida de concurrir a un acto por enfermedad, distancia, o necesita de alguien calificado que actúe por ella, como el abogado en un pleito.

Por regla general, todo lo que puede hacerse personalmente puede hacerse por representante. Solo por excepción, y cuando la ley lo dice expresamente, un acto debe ejecutarse personalmente: la facultad de testar es indelegable (**art. 1004**), y la ratificación ante el Oficial del Registro Civil del matrimonio contraído ante un ministro de culto no puede hacerse por mandatario (**art. 15 inc. 2º Ley de Registro Civil**, en relación con el **art. 20 de la Ley de Matrimonio Civil**).

3. PODER DE REPRESENTACIÓN

3.1. Conceptos generales

El representante debe tener **poder de representación**, la autorización para concertar negocios por cuenta de otro, obligando exclusiva y directamente al representado. El acto por el cual se atribuye ese poder se llama **apoderamiento**.

3.2. Clases de representación

Según el **art. 1448**, el poder puede emanar de la ley o de la voluntad del interesado.

(i) Representación legal.

Supone que una persona está en la imposibilidad jurídica de ejercer por sí sola la autonomía privada. El **art. 43** cita como representantes legales al padre o madre, al adoptante y al tutor o curador, enumeración no taxativa: también lo es el juez en las ventas forzadas (**art. 671**) o el partidor en las enajenaciones que se hacen en una partición (**art. 659 C.P.C.**).

(ii) Representación voluntaria.

Surge exclusivamente de un acto voluntario del interesado, que otorga poder a otra persona para actuar en su nombre, con la más amplia libertad para decidir si actúa personalmente y a quién elige como representante, que puede incluso ser una persona incapaz.

3.3. Mandato y representación voluntaria

El mandato es el contrato en que una persona (el mandante) confía la gestión de uno o más negocios a otra (el mandatario), que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (**art. 2116**). Aunque relacionados, mandato y apoderamiento son conceptos distintos: el mandato es una relación contractual, mientras que el apoderamiento es un acto jurídico **unilateral** por el que una persona confiere a otra la facultad de representarla. La representación es, además, independiente del mandato: puede haber mandato sin representación (si el mandatario obra a su propio nombre) y representación sin mandato (en la representación legal, o en la agencia oficiosa). De esta independencia se siguen dos precisiones: la representación voluntaria no supone necesariamente un mandato, porque el poder de representar puede existir antes de que el mandato se perfeccione, aunque otorgarlo ya implica ofrecer, al menos tácitamente, la celebración de uno; pero, aun pudiendo el apoderamiento preceder al mandato como acto separado, no puede concebirse el *ejercicio* del poder desligado del cumplimiento del mandato mismo. Como esa facultad de representar no requiere mención especial para entenderse conferida, se concluye que la representación es de la **naturaleza** del mandato, aunque no de su esencia.

NO CONFUNDIR

Representar no es de la esencia del mandato

La potestad de representar no es un elemento esencial del mandato: es perfectamente posible que el mandatario no represente al mandante, cuando contrata a su propio nombre aunque sea en interés de este (**art. 2151**). Para representar, es indispensable que actúe en nombre del mandante conforme al **art. 1448**; si obra a nombre propio, no obliga al mandante frente a terceros, aunque en sus relaciones internas con él sigue rigiéndose por las reglas del mandato.

4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN

4.1. Teoría de la ficción

Supone que el representado ha manifestado su voluntad por mediación del representante, un mero vehículo de aquella. Ha sido abandonada: es incapaz de explicar la representación legal del demente o el impúber, a quienes la ley da curador o tutor precisamente porque carecen de voluntad que pudiera transmitirse.

4.2. Teoría del nuntius o mensajero

Sostiene que el representante es solo un mensajero que transmite mecánicamente la voluntad del representado, de modo que el contrato se celebra real y efectivamente entre este y el tercero. Tampoco es satisfactoria: niega al representante su calidad de tal, y mal puede transmitir una voluntad inexistente, como la del impúber o el demente.

4.3. Teoría de la cooperación de voluntades

Explica la representación por la cooperación de las voluntades del representante y el representado, que concurren juntas a la formación del acto. Ha sido repudiada por la maraña de distinciones a que da origen y porque, igual que las anteriores, no explica la representación legal: no cabe cooperación de voluntad alguna entre el demente o el impúber, que carecen de ella, y su curador o tutor.

4.4. Teoría de la representación modalidad del acto jurídico

Es la voluntad del **representante**, sustituyéndose a la del representado, la que participa real y directamente en la formación del acto. La representación sería una **modalidad** del acto jurídico: una modificación introducida por la ley o las partes en sus consecuencias naturales, que normalmente afectan a quien celebra el acto, pero que en este caso se desvían hacia el representado. ALESSANDRI sostiene que el tenor del **art. 1448** encaja perfectamente en esta teoría, porque es el representante quien *ejecuta* el acto, atribuyéndosele los mismos efectos que si lo hubiese ejecutado el representado, lo que confirman otras normas donde la ley exige la voluntad del representante (**arts. 672, 673, 678 y 721**).

CORTE SUPREMA, 9 DE ENERO DE 2017

Sobre la base de una concepción objetiva de la obligación, se ha propuesto que la voluntad que contrata es la del representante, y que al acto celebrado con el tercero le es agregada una modalidad. Lo normal es que la voluntad actúe al servicio del patrimonio de quien la ostenta, pero por esa modalidad introducida en la celebración del acto, la voluntad del representante ha sido puesta al servicio de un patrimonio ajeno, el del representado; así, los efectos del acto no se radicarán en el patrimonio del representante, sino en el del representado. Sin estar exenta de críticas, esta doctrina, llamada de la representación modalidad de los actos jurídicos, es en la actualidad la que parece disfrutar de mayores preferencias. La Corte traza esta línea jurisprudencial hasta sus propios fallos anteriores en el mismo sentido: Corte de Temuco, 29 de marzo de 1939 (RDJ, t. 40, p. 304); Corte de Santiago, 29 de agosto de 1945 (RDJ, t. 43, secc. 2ª, p. 65); y Corte Suprema, 5 de junio de 1951 (RDJ, t. 48, p. 171).

Existe hoy consenso doctrinal y jurisprudencial en que esta es la teoría que rige en el derecho chileno.

5. INFLUENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL REPRESENTANTE O DEL REPRESENTADO

5.1. En relación a la capacidad

En la **representación legal**, el representante debe ser capaz; el representado, normalmente, es incapaz (por eso necesita representante). En la **representación voluntaria**, el representado debe ser capaz, porque la capacidad es requisito de la eficacia del apoderamiento; el representante, en cambio, puede ser incapaz relativo, pues el **art. 2128** permite al menor adulto ser mandatario incluso sin autorización de su representante legal, aunque las obligaciones que ese mandatario incapaz contraiga con el mandante o con terceros sigan las reglas generales de capacidad.

5.2. En relación con las formalidades habilitantes

Si se enajena un bien raíz del hijo de familia por medio de un mandatario del padre, la autorización judicial exigida por la ley sigue siendo necesaria en todo caso. Pero si es el propio hijo de familia quien actúa como mandatario de un tercero capaz, dueño del inmueble, no requiere esa autorización, porque no está enajenando un bien propio. Lo mismo se aplica a las demás formalidades habilitantes.

5.3. En relación con los vicios del consentimiento

Bajo la teoría de la modalidad: el **error del representante** vicia el consentimiento solo si es también relevante para el representado (si A da poder a B para comprarle un reloj, siéndole indiferente el material, y B lo compra creyendo que era de oro cuando en realidad es de bronce, ese error sustancial de B no invalida el contrato, porque no es relevante para A, la parte a quien afectan sus resultados); la **fuerza o el dolo determinante** ejercido sobre el representante vicia el consentimiento y permite rescindir; y el **error relevante, la fuerza o el dolo sufridos por el representado** hacen anulable el poder mismo, y con él, el acto representativo.

5.4. En relación a la buena o mala fe

La mala fe del representante afecta al representado. Y si la mala fe está en el representado, este debe soportar sus consecuencias aunque el representante haya actuado de buena fe: no podría valerse de un tercero para beneficiarse y eludir las sanciones que la ley impone a la mala fe.

5.5. En relación al principio *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*

Si el representado sabía o debía saber el vicio, o contrató a sabiendas del objeto o causa ilícita, no puede alegar la nulidad ni repetir lo pagado. La Corte Suprema ha resuelto, en cambio, que el representado **sí** puede demandar la nulidad aunque el representante conociera el vicio, porque el dolo, que la ley castiga negando la acción, es un acto personalísimo del representante.

6. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE EXISTA REPRESENTACIÓN Y PRODUZCA PLENAMENTE SUS EFECTOS

6.1. Declaración de voluntad del representante

Es el representante quien contrata y declara su propia voluntad. En la **representación legal**, el representante debe ser capaz (de lo contrario sus actos son nulos) y no es necesario que el representado lo sea. En la **convencional**, se exige que el representado sea capaz tanto para el mandato como para el acto celebrado a su nombre, aunque el Código admite que el mandatario mismo sea un incapaz relativo, como el menor adulto (**arts. 1581 y 2128**), porque el acto no compromete su propio patrimonio sino el del representado.

6.2. Existencia al contratar de la *contemplatio domini*

El representante debe manifestar de modo inequívoco su intención de obrar en nombre y por cuenta de otro, y quien contrata con él debe participar de esa intención (aunque sea tácitamente, sin necesidad de que se mencione el nombre del representado): el negocio se contempla para el *dominus*, el representado, no para sí. Así lo exige el **art. 1448** (*a nombre de otra*) y lo confirma el **art. 2151**:

si el mandatario obra a su propio nombre, no obliga frente a terceros al mandante. Faltando la *contemplatio domini*, el acto surte efectos para el representante, no para el representado.

6.3. Existencia de poder, y obrar dentro de sus límites

El representante debe tener poder, legal o voluntario (**art. 1448**), y obrar dentro de sus límites; si los excede, carece de poder y el acto es inoponible al representado. Hay, con todo, dos casos en que los efectos del acto se radican igualmente en otra persona pese a la falta o exceso de poder: la **agencia oficiosa**, cuando el interesado no ratifica pero el negocio le resultó útil (**art. 2290**); y la **ratificación** posterior del interesado, que equivale a un poder retroactivo. El poder de representación se extingue por revocación (acto unilateral del poderdante), por la muerte del representado o del representante, y por la incapacidad legal sobreviniente de este último.

7. EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN

Son los mismos para la representación legal y la voluntaria (**art. 1448**): los derechos y obligaciones del acto se radican en el representado, como si él mismo hubiese contratado.

8. SANCIÓN DE LOS ACTOS EJECUTADOS SIN PODER O CON EXTRALIMITACIÓN

(i) La inoponibilidad como sanción general, y sus excepciones.

El **art. 2160** dispone que el mandante debe cumplir las obligaciones contraídas a su nombre *dentro de los límites* del mandato: fuera de ellos, el acto es **inoponible** al representado, salvo que este lo ratifique expresa o tácitamente. Una excepción está en el **art. 2173**: si el mandato expiró por una causa ignorada del mandatario, lo obrado por este es válido y obliga al mandante frente a terceros de buena fe; y si el mandatario, sabiendo de la causa de expiración, contrató igual con terceros de buena fe, el mandante queda obligado también, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizado por el mandatario.

(ii) Responsabilidad del representante-mandatario que se extralimitó.

Frente al **mandante**, el mandatario extralimitado responde contractualmente por incumplir su deber de ceñirse a los términos del mandato (**art. 2131**), en la medida que ese exceso le haya causado un perjuicio efectivo: si el mandante no resultó obligado frente a terceros, en principio no hay perjuicio que reclamar; pero puede haberlo aunque el mandante no quede obligado, como cuando el mandatario, además de extralimitarse, ni siquiera ejecutó el negocio encomendado (se le encargó vender un predio y lo hipotecó en su lugar). Si el mandante ratifica los contratos del mandatario, se entiende que renuncia a la acción de perjuicios en su contra, aunque esos contratos le resulten dañosos, porque asumió voluntariamente cumplirlos. Y la responsabilidad del mandatario cesa si se excedió del mandato por una necesidad imperiosa, caso en que pasa a actuar como agente oficioso

(**art. 2122**). Frente a los **terceros**, en cambio, el **art. 2154** dice que en principio no responde, salvo que no les haya dado suficiente conocimiento de sus poderes (caso en que responde extracontractualmente, por su falta de diligencia) o que se haya obligado personalmente ante ellos.

9. LA RATIFICACIÓN

Cuando quien se dice representante no lo es, o el representante verdadero se extralimita, el representado no queda afectado por el contrato, salvo que voluntariamente lo apruebe: esa aprobación es la **ratificación**, distinta de la ratificación que sanea la nulidad relativa. Es un acto jurídico **unilateral**, procedente tanto en la representación legal como en la voluntaria, que puede ser expresa o tácita (esta última, cualquier hecho inequívoco del representado que manifieste su voluntad de aceptar lo obrado en su nombre, como exigir los derechos que el contrato le otorga). Es **recepticia** (produce efectos una vez conocida por representante y tercero), debe emanar del representado, sus herederos o representantes legales (con capacidad suficiente), puede hacerse en cualquier momento, incluso después de la muerte de cualquiera de las partes o del propio representante, es **irrevocable** una vez producida (la Corte Suprema ha resuelto que no cabe la revocación unilateral de la ratificación que ya produjo efectos respecto de terceros), y opera con **efecto retroactivo** a la fecha del contrato celebrado por el representante.

Se discute si, cuando el acto que se ratifica es solemne, la ratificación debe cumplir esas mismas solemnidades. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria lo afirman: si el acto es solemne, la ratificación también debe serlo, y si no lo es, la ratificación no requiere ninguna. Esta conclusión es, sin embargo, discutible: las solemnidades son de derecho estricto, y ninguna norma exige que esta ratificación se sujete a las del acto que ratifica, a diferencia de la ratificación del acto relativamente nulo, donde el **art. 1694** sí lo exige expresamente. Ambas ratificaciones, además, no son asimilables: en la del acto relativamente nulo, quien ratifica es quien ejecutó el acto, aunque con su voluntad viciada; en la del acto inoponible por extralimitación, el acto lo ejecutó el representante, no el representado, cuya voluntad recién concurre con la ratificación. Por eso no se ve la necesidad jurídica, más allá de su evidente utilidad práctica, de exigir aquí la misma solemnidad: el acto que se ratifica ya reunió, entre representante y tercero, las voluntades y solemnidades que la ley exigía.

10. OTRAS HIPÓTESIS EN QUE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS ALCANZAN A LOS TERCEROS

10.1. Estipulación para otro

El estipulante hace prometer al promitente una prestación a favor de un tercero, el beneficiario, quien es el único que puede demandar lo estipulado; mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, el contrato es revocable por las partes que concurrieron a él, entendiéndose por aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato (**art. 1449**). El ejemplo

típico es el seguro de vida, donde el asegurador se compromete a pagar, a la muerte del asegurado, una suma a su cónyuge o hijos.

10.2. Promesa de hecho ajeno

Uno de los contratantes se compromete a que un tercero, de quien no es representante, dará, hará o no hará algo: ese tercero no contrae obligación alguna sino en virtud de su propia ratificación, y si no ratifica, el otro contratante tiene acción de perjuicios contra quien hizo la promesa (**art. 1450**). Por ejemplo, el vendedor de una casa se compromete frente al comprador a que el vecino derribará los árboles que malogran la vista del inmueble. A diferencia de la estipulación para otro, esta no es una excepción al efecto relativo de los contratos: el tercero solo se obliga si ratifica, y en tal caso la obligación nace de su propia voluntad, no del contrato ajeno.

S. LA CONDICIÓN

RAMOS define las modalidades como elementos establecidos por la ley, el testamento o la voluntad de las partes con el objeto de alterar los efectos normales de un negocio jurídico; para **ABELLIUK**, son las cláusulas que las partes introducen para modificar esos efectos normales en cuanto a su existencia, exigibilidad o extinción. La **condición**, el **plazo** y el **modo** son las principales, pero no las únicas: también lo son la solidaridad, las obligaciones alternativas o facultativas, y la representación, en cuanto todas alteran lo que sería el efecto normal del acto.

Las modalidades son, por regla general, **elementos accidentales** del acto (**art. 1444**), aunque excepcionalmente pueden ser de la naturaleza (la condición resolutoria tácita) o incluso de la esencia (la condición o el plazo en el contrato de promesa, **art. 1554 N° 3**). Son **excepcionales**, porque la regla general es que los actos sean puros y simples: por eso quien las alega debe probarlas, se interpretan restrictivamente y no se presumen, salvo la condición resolutoria tácita, que la ley presume envuelta en todo contrato bilateral (**art. 1489**). Y requieren una **fuerza** que las cree (el testamento, la convención o la ley), pues la sentencia judicial normalmente no crea modalidades, salvo autorización legal expresa, como la que faculta al juez para fijar un plazo al poseedor vencido que debe restituir la cosa reivindicada (**art. 904**).

Los actos **patrimoniales** admiten modalidades por regla general, salvo excepciones puntuales como la aceptación o repudiación de una herencia (que no puede sujetarse a condición ni a plazo, **art. 1227**) o la legítima rigorosa (que no admite condición, plazo, modo ni gravamen alguno, **art. 1192**). Los actos de **familia**, en cambio, no admiten modalidades, porque sus efectos los fija la ley de forma imperativa: el matrimonio se define como un contrato que une a los cónyuges *actual e indisolublemente* (**art. 102**), lo que excluye toda condición, plazo o término a su respecto. El Código trata las modalidades a propósito de las asignaciones testamentarias condicionales, a día y modales (Libro III), y de las obligaciones condicionales, modales y a plazo (Libro IV).

1. CONCEPTO

Es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho (**arts. 1070 y 1463**). Que sea **futuro** significa que debe realizarse después de celebrado el acto: si se subordina el acto a un hecho presente o pasado, no hay condición, sino que el acto es puro y simple (si el hecho existe) o no vale (si no existe), según el **art. 1071** en relación con el **1493**. Que sea **incierto** significa que puede o no suceder, lo que la distingue del plazo: la muerte de una persona nunca es, por sí sola, una condición, porque tarde o temprano ocurrirá, aunque combinada con otra circunstancia sí puede serlo (donar una suma si el beneficiario no muere antes de los noventa años).

2. CLASIFICACIONES

2.1. Positivas y negativas

Según la naturaleza del hecho: la condición **positiva** consiste en que algo acontezca; la **negativa**, en que algo no acontezca (**art. 1474**), sin que influya la forma gramatical en que se exprese: *te doy un millón si te casas* es tan positiva como *te doy un millón si no permaneces soltero*, del mismo modo que *te doy un millón si no tienes más hijos* es tan negativa como *te doy un millón si te quedas con el único hijo que tienes*.

2.2. Posibles e imposibles

Es **físicamente imposible** la condición contraria a las leyes de la naturaleza física, y **moralmente imposible** la prohibida por las leyes o contraria a las buenas costumbres o al orden público; se miran también como imposibles las concebidas en términos ininteligibles, llamadas *intelectualmente imposibles* (**art. 1475**). Ejemplo clásico, de raíz romana, de condición físicamente imposible: *te doy mi fundo si tomas una estrella con la mano*; de condición moralmente imposible: *te pago veinte millones si das muerte a X*.

2.3. Suspensiva y resolutoria

Según su efecto: es **suspensiva** si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y **resolutoria**, si por su cumplimiento se extingue un derecho ya nacido (**art. 1479**). Ejemplo de la primera: una aseguradora se compromete a indemnizar al dueño de un inmueble si este es destruido o deteriorado por un incendio. Ejemplo de la segunda: vendo mi casa, pero si el comprador se va a Europa me la revende; arriendo mi departamento, pero si el arrendatario se casa, el contrato termina. En la suspensiva, el acto existe antes del cumplimiento, pero su eficacia queda en suspenso; en la resolutoria, el acto produce desde ya todos sus efectos, y solo existe incertidumbre sobre si esos efectos se extinguirán.

2.4. Potestativa, casual o mixta

Según su causa generadora: **potestativa**, la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor (*si me voy a Europa, te arriendo mi casa*); **casual**, la que depende de la voluntad de un tercero (*si Pedro deja el empleo, te lo reservo a ti*) o de un acaso (*si llueve en diciembre, te regalo un paraguas*); **mixta**, la que depende en parte de la voluntad del acreedor o deudor y en parte de un tercero o de un acaso (*si me caso con María, te donaré mi auto*, mixta porque depende de mi voluntad y de la de María) (**art. 1477**). La potestativa y la casual están bien definidas por el propio artículo, pero no así la mixta, que omite mencionar la voluntad del deudor junto a la del acreedor; por eso la doctrina la reformula como la que depende en parte de la voluntad del acreedor o del deudor, y en parte de la de un tercero o de un acaso. La potestativa puede ser **pura o meramente potestativa** (depende de la mera voluntad de una persona, sin motivo serio: *te daré algo si quiero*) o **simple-**

mente potestativa (un hecho voluntario que ordinariamente no se realiza ni se omite sin motivo, como hacer un viaje).

DATO DE GRADO

La única condición inválida: la suspensiva puramente potestativa del deudor

Todas las condiciones potestativas son válidas, salvo la **suspensiva** puramente potestativa que depende de la mera voluntad del **deudor**. La jurisprudencia explica la diferencia: la condición *resolutoria* puramente potestativa del deudor es válida, porque la obligación ya nació y la condición solo afecta su extinción; pero la *suspensiva* puramente potestativa del deudor es nula, porque en ese caso el deudor nunca manifestó inalterablemente su voluntad de obligarse, y falta entonces la voluntad seria que la existencia del acto jurídico requiere.

3. ESTADOS EN QUE PUEDEN HALLARSE LAS CONDICIONES

Toda condición puede estar **pendiente** (todavía no se sabe si se realizará), **cumplida** (el hecho se verificó) o **fallida** (ya es seguro, fuera de duda, que no se realizará).

3.1. Efectos de la condición suspensiva

(i) Pendiente.

El derecho todavía no existe: no puede exigirse el cumplimiento de la obligación, y si el deudor paga igualmente, puede repetir lo pagado mientras la condición no se cumpla (**art. 1485**). Existe, con todo, un **derecho eventual** que permite al acreedor solicitar providencias conservativas (**arts. 761, 1078 y 1492**) y que se transmite a sus herederos si el acreedor muere mientras la condición está pendiente (salvo en las asignaciones testamentarias y las donaciones entre vivos, **art. 1492**).

(ii) Cumplida.

El derecho adquiere consistencia, y la ley le da **efecto retroactivo**: se considera que el acto produjo sus efectos desde su celebración, como si siempre hubiese sido puro y simple, porque el único motivo que impedía sus efectos inmediatos era la incertidumbre, y esta ya desapareció.

(iii) Fallida.

Se desvanece la expectativa del acreedor condicional: el acto se borra por completo, hacia el futuro y hacia el pasado, como si jamás hubiese existido.

3.2. Efectos de la condición resolutoria

(i) Pendiente.

El acto produce provisionalmente todos sus efectos, como si fuera puro y simple; la incertidumbre solo recae sobre la perduración o extinción de esos efectos. Por ejemplo, dono una casa a Manuel, pero si muere antes que yo, la donación queda sin efecto: Manuel disfruta la casa desde luego y mientras viva, pero si muere antes que yo, sus herederos deberán restituírmela.

(ii) Cumplida.

El derecho se resuelve o extingue, también con **fuerza retroactiva**: deja de existir no solo hacia el futuro, sino como si nunca hubiese existido, debiendo restituirse lo recibido bajo esa condición (**art. 1487**).

(iii) Fallida.

El derecho se consolida definitivamente, y el acto se mira como puro y simple desde su celebración. Por ejemplo, dono un millón de pesos a Juan Antonio con la condición de que me lo devuelva si se casa con María: si ella muere, ya es indudable que el hecho no podrá verificarse, y el derecho de Juan Antonio se consolida definitivamente.

T. EL PLAZO

1. CONCEPTO

El Código lo define como *la época que se fija para el cumplimiento de la obligación* (**art. 1494**); doctrinalmente, es un hecho futuro y **cierto** del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho: futuro, porque debe ocurrir después de celebrado el acto, y cierto, porque necesariamente ha de llegar.

2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL PLAZO Y LA CONDICIÓN

Ambos son modalidades, ambos son hechos futuros, y ambos permiten impetrar medidas conservativas. Se diferencian en que el plazo es cierto e inevitable, mientras la condición es incierta; en que el plazo no afecta la **existencia** del derecho, sino su ejercicio o exigibilidad, mientras la condición sí afecta su existencia; en que lo pagado antes de cumplirse un plazo suspensivo no se puede repetir (**art. 1495**), a diferencia de lo pagado antes de una condición suspensiva (**art. 1485**); y en que el plazo puede tener origen convencional, legal o judicial, mientras la condición solo nace de la voluntad de las partes o de la ley.

3. CLASIFICACIONES

3.1. Plazo expreso y tácito

Es **expreso** el que las partes estipulan, y **tácito**, el indispensable para cumplir la obligación según su propia naturaleza (**art. 1494**): la obligación de entregar algo en un lugar determinado supone tácitamente el tiempo necesario para trasladarse hasta allá.

3.2. Plazo determinado e indeterminado

Es **determinado** cuando se sabe con anticipación el día exacto en que ocurrirá el hecho futuro (una fecha del calendario), e **indeterminado** cuando, aunque se sabe que el hecho ocurrirá, se ignora cuándo (la muerte de una persona).

3.3. Plazo convencional, legal y judicial

Según lo fijen las partes, la ley o el juez; por regla general su fijación es obra de las partes. El plazo **legal** es frecuente en materia procesal y más escaso en materia civil, donde aparece sobre todo en los plazos de prescripción. El plazo **judicial** es todavía más excepcional: el juez solo puede fijarlo en los casos que la ley expresamente designa, como el plazo para que el poseedor vencido restituya la cosa reivindicada (**art. 904**), para que el mutuario pague cuando *le sea posible*

(**art. 2201**), o para ampliar o restringir el plazo legal de inventariar los bienes del pupilo (**art. 378**); fuera de esos casos, solo puede interpretar un plazo estipulado en términos vagos u oscuros (**art. 1494** inciso 2°).

3.4. Plazo suspensivo y extintivo

El **suspensivo o inicial** es aquel desde el cual comienza a producir efectos el acto (el precio se paga seis meses después de la compraventa); el **extintivo o final** es aquel hasta el cual duran esos efectos (un arrendamiento por un año, que cesa al cumplirse el plazo).

4. EFECTOS DEL PLAZO

4.1. Efectos del plazo suspensivo

El derecho existe desde el comienzo: el plazo suspende su **ejercicio**, no su nacimiento, lo que explica por qué lo pagado antes de su cumplimiento no está sujeto a restitución (**art. 1495**), a diferencia de la condición suspensiva. Permite también impetrar medidas conservativas, y su vencimiento hace exigible el derecho, sin que produzca nunca efecto retroactivo: por eso no da derecho a los frutos o intereses devengados antes de su cumplimiento.

4.2. Efectos del plazo extintivo

Pone fin a los efectos del acto y extingue el derecho, pero, a diferencia de la condición resolutoria, solo hacia el futuro: no afecta los efectos ya producidos en el pasado.

U. EL MODO

1. CONCEPTO

Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esa aplicación es un **modo**, y no una condición suspensiva (**art. 1089**). Más precisamente, es una carga ligada a una disposición a título gratuito e impuesta al beneficiario: *te instituyo heredero con la obligación de que construyas tres escuelas en zonas fronterizas*. Esa carga no es una contrapartida por lo recibido, sino una restricción de sus efectos para satisfacer los fines del instituyente.

Se distingue de la condición suspensiva en que no suspende la adquisición del derecho: como dice el aforismo, *la condición suspende pero no obliga; el modo no suspende, pero obliga*. Si se dona dinero *si* el donatario erige una estatua, hay condición suspensiva: es libre de no erigirla, pero entonces no recibe el dinero. Si se dona el dinero *con la obligación* de erigir la estatua, hay modo: el donatario recibe el dinero de inmediato, pero queda obligado a construirla.

2. EFECTOS DEL MODO

No afecta la existencia del derecho, que existe desde el comienzo; solo afecta la manera de ejercerlo: el modo no suspende la adquisición de la cosa asignada (**art. 1089** parte final).

3. CUMPLIMIENTO DEL MODO

La persona favorecida con el modo puede exigir judicialmente su cumplimiento (**art. 1094**): si se asigna una suma a Primus con la obligación de dar una pensión periódica a un pariente del testador, ese pariente puede recurrir a los tribunales para que Primus cumpla el modo. Su incumplimiento, sin embargo, no produce por sí solo la resolución del derecho, a menos que exista **cláusula resolutoria**, que impone la obligación de restituir la cosa y sus frutos si el modo no se cumple, y que nunca se presume: no se entiende que la asignación la envuelve si el testador no la expresa (**art. 1090**). Si el modo es en beneficio exclusivo del propio asignatario (*dejo a Manuel diez millones de pesos para que adquiera una biblioteca jurídica*), no le impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria (**art. 1092**): en ese caso es, más bien, un simple consejo sin fuerza obligatoria.